석사학위논문

기본권에 비추어 본 취업규칙 제도의 헌법적 고찰

A Study On the Rules of Employment In View of Constitutional Basic Rights

한국방송통신대학교 대학원

법 학 과

정 인 탁

2017년

기본권에 비추어 본 취업규칙 제도의 헌법적 고찰

A Study On the Rules of Employment In View of Constitutional Basic Rights

지도교수 강 경 선

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

한국방송통신대학교 대학원

법 학 과

정 인 탁

2017년 12월

정 인 탁의

석사학위 논문을 인준함

심사위원장 이 원 희 (인)

심사위원 조 경 배 (인)

심사위원 강 경 선 (인)

한국방송통신대학교 대학원

2017년 12월

논 문 요 약

기본권에 비추어 본 취업규칙 제도의 헌법적 고찰

정 인 탁

한국방송통신대학교 대학원

법 학 과

(지도교수 강 경 선)

이 논문은 우리 사회의 노동 분야 연구가 주로 노동실체법 위주의 노동법학에만 치중되어 진행되고 있다는 점에 착안해 앞으로는 노동 분야의 연구와 노동 문제 역시 헌법적 규범으로 풀어낼 필요가 있다는 점을 개진하며 시작했고, 이를 토대로 하여 최근 우리 사회가 마주했던 노동 문제들 중 가장 이슈였던 '양대 지침' 중 취업규칙 제도와 관련된 문제들을 헌법학에 기대어 점검하며 연구한 내용이다. 특히 대다수 노동자들이 직접적으로 적용 받고 있는 취업규칙 제도는 불이익한 변경 요건에 대해 섣불리 완화시킬 경우 노동자들의 노동기본권이 어렵지 않게 침해될 수 있다는 점에서 문제점을 고찰하고 제도적 대안을 모색해 제시하는 것을 목표로 한다.

취업규칙 제도를 규율하고 있는 「근로기준법」은 국민의 기본권 보장을 본질적 징표로 하는「헌법」과 노동 문제에 대해 「헌법」상의 기본권 보장 실현을 위한 노동기본권의 기본적 법규라 할 수 있다. 노동기본권은 1919년 바이마르 헌법의 기본권 구조에 뿌리를 두고 있으며, 건국헌법 입법 당시 일본의 제국 헌법과 독일 바이마르 헌법을 참조하였던 우리 「헌법」도 제32조와 제33조에 걸쳐 노동기본권이 우리 국민의 기본적 권리임을 명시하고 있다. 제32조에서는 실질적 보장 측면에서의 자유권적 성격과 사회권적 성격을 두루 갖춘 사회적 기본권으로서 근로기회청구권과 국가의 고용증진의무, 해고 자유의 제한, 적정임금의 보장, 노동조건 기준의 법정 주의 등을 요구하고 있으며, 제33조에서는 이른바 '노동3권'이라 불리는 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 그 내용으로 하여 현실적이고 구체적인 권리로써 보장해야 함을 명백히 하고 있다.

이처럼 명백히 「헌법」상 보장된 국민의 기본권에 근거를 둔 제도임에도 불구하고 정부는 국민적 이해와 사회적 합의를 통한 법률의 개정도 아닌 단순히 '행정 지침'에 불과한 '양대 지침'으로 노동 시장을 규율하려 하는 움직임을 보인 바 있다. 이에 국가인권위원회의 상임위원회는 '양대 지침'은 법규적 효력도 없는 단순한 안내서에 불과한 것인데도 불구하고 고용노동부가 이를 적극적으로 홍보하고 소속기관에 시달해 활용하게 한 것에 대해, 정부의 지침이 국민의 권리를 사실상 규율하는 결과가 있을 수 있음을 우려하고 국민의 노동의 권리가 약화되지 않도록 조치할 필요가 있다고 판단하여 우려의 의견표명을 했다.

따라서 본고의 논의는 우리 노동현실 속의 자본과 노동이 균형을 잃어 자본의 측면으로 균형점이 치우쳐져 있는 상황 속에서, 「헌법」의 이념과 기본권의 객관적 가치 측면으로 현실의 노동 문제에 접근해 자본과 노동의 불균형이 수정되어야 함을 시사한다. 또 그로부터 자본과 노동의 균형점이 보다 중앙에 가깝게 위치하게 되어야 함을 강조한다.

주제어 : 헌법, 사회적기본권, 노동기본권, 취업규칙제도, 사회통념상 합리성

- 목 차 -

제1장 서론 ····· 1

제1절 연구의 필요성과 목적 ····· 1

제2절 연구의 범위와 방법 ····· 5

제2장 '노동'의 헌법적 가치 ····· 6

제1절 기본권으로서 노동의 보장과 변천의 개괄적 검토 ····· 6

Ⅰ. 근대적 기본권의 발달과 노동인권의 충돌 ····· 6

Ⅱ. 노동인권의 보장과 현대적 기본권으로의 전환 ····· 8

Ⅲ. 우리 헌정사 속의 기본권과 노동인권 ····· 10

제2절 헌법적 가치로서 사회적 기본권과 노동기본권 ····· 12

Ⅰ. 사회적 기본권의 법적 성격에 관한 논의 ····· 12

Ⅱ. 노동기본권의 본질과 가치 ····· 16

1. 노동의 권리 ····· 19

2. 노동3권 ····· 22

제3절 소결 ····· 32

제3장 헌법적 이념에 기초한 취업규칙제도 ····· 35

제1절 노동기본권과 취업규칙의 상관관계 ····· 35

제2절 취업규칙의 의의와 효력 ····· 40

Ⅰ. 취업규칙의 개념 ····· 40

Ⅱ. 법적성질에 대한 입장의 대립 ····· 43

1. 법규범설 ····· 44

2. 계약설 ····· 45

3. 판단 ····· 47

Ⅲ. 효력과 효력발생시기 ····· 48
제3절 취업규칙 변경절차의 법적 구조 ····· 51
Ⅰ. 의견청취 대상과 동의주체 ····· 51
Ⅱ. 의무적 사항으로서 의견청취 ····· 54
Ⅲ. 불이익한 변경시의 동의 문제 ····· 56
1. 불이익함의 판단 기준 ····· 56
2. 절차적 요소로서 집단적 동의 ····· 59
3. 묵시적 동의와 소급적 동의의 효력 ····· 62
4. 단체협약의 변경으로 인한 취업규칙의 불이익한 변경 ····· 65
5. 동의절차 위반의 효과 ····· 68
Ⅳ. 불이익한 변경의 예외로서 사회통념상 합리성의 판단 ····· 70
제4절 소결 ····· 77

제4장 취업규칙과 관련된 행정지침의 쟁점과 문제 ····· 79
제1절 취업규칙제도와 관련된 사회적 이슈의 점검 ····· 79
Ⅰ. 취업규칙의 불이익 변경 요건 완화 시도 ····· 79
Ⅱ. ‘지침’이 차용했던 사회통념상 합리성론 ····· 81
제2절 기본권 침해와 위헌성 측면에서 ‘지침’의 문제점 ····· 84
Ⅰ. ‘지침’의 내용 측면에서 기본권 침해 소지 검토 ····· 84
Ⅱ. 행정입법 측면에서 ‘지침’의 기본권 침해 판단 ····· 86
Ⅲ. ‘지침’의 위헌성 여부 ····· 90
제3절 소결 ····· 93
제4절 제언 ····· 95

제5장 결론 ····· 100

참고문헌 ····· 102
ABSTRACT ····· 109
감사의 글 ····· 112

- 표 목차 -

<표 1> 판례가 제시하고 있는 사회통념상 합리성의 판단 기준 ····· 71
<표 2> 일본 최고재판소의 사회통념상 합리성 판단 기준 ····· 73

- 그림 목차 -

<그림 1> 양대 지침에 대한 임금 노동자의 우려도 비교 ····· 3
<그림 2> 노동조합 조직률 변화 추이 ····· 35
<그림 3> 지침으로 인해 사용자가 임의대로 취업규칙을 변경할 수 있다는 우려도 ····· 84
<그림 4> 시간의 흐름에 따른 관심도 변화 ····· 91
<그림 5> 일자리 질적 수준별 고용구조 추이 ····· 96

제1장 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

4차 산업시대를 목전에 두고 있는 현대사회는 산업구조 고도화를 거치며 비약적으로 발전해 어느 특정 분야 하나 빼놓을 수 없을 만큼 각 분야에 걸쳐 굉장히 다변화되고 복잡해졌다. 또한 저출산 문제가 심화되고 고령화 사회로 진입하게 되면서 인구구조가 변동됨에 따라 산업현장에서 마주하는 노동환경은 이전과는 다르게 크게 변동되고 있다. 이와 같은 노동환경의 급격한 변화는 정부와 사용자 단체, 노동계 등 각계의 다각적 논의를 불러오기에 충분하였고 정부는 2014년 초부터 노동개혁 정책이라는 미명하에 노사정위원회를 소집하며 사회적 대화와 타협을 추진하였으나, 수차례에 걸친 노사정 협상 과정에서 합의를 도출해내지 못하고 진통하다 2015년 09월 15일 마침내 사회적 대타협에 이르게 되는 유의미한 결과물을 도출해 냈다.[1)]

그러나 합의 내용에 대해 정부와 노동계 사이에서 이견이 있었음에도 불구하고 정부의 일방통행식 노동개혁 행보 끝에 2016년 01월 한국노총이 공식적으로 합의 파기 선언을 함에 이르는 결과를 낳게 되었고, 이처럼 파국에 이르게 된 경위는 정부의 이른바 '양대 지침'[2)] 일방적 발표가 무엇보다도 결정적인 빌미가 되었다. 그 결과 정부의 '양대 지침' 정책은 각계의 비판 대상[3)]이 되었고, 그럼에도 불구하고 고용노동부(이하 '노동부'라 한다.)는 2017년 05월 신정부 출범에 따른 대통령의 공약사항 이

---

1)대타협의 기재 내용에 대한 평가가 아닌 정부와 사용자 단체, 노동계가 대화와 타협을 거쳐 대타협을 이뤄냈다는 일련의 과정에 한정하여 의미를 부여한 것이다. 대타협의 내용을 살펴 평가하자면 "헌법상의 노동기본권을 유린하는 것"이고 "열심히 일하는 절대 다수 노동자의 삶을 위협하는 위험천만한 합의"라는 평가가 존재한다. 이에 대한 더 자세한 내용은 (국회의원 300인 모니터링 뉴스, 2015. 09. 15.자, "9 13 노사정 합의는 노동기본권을 유린하는 위험천만한 합의" 제목의 기사, http://news300.kr/)

2)고용노동부가 2016. 01. 22. 발표한 '공정인사지침'(일반해고 확대), '취업규칙 해석 및 운영지침'(취업규칙 불이익변경 요건 완화)을 말한다.

3)노사정이 중장기적으로 진지하게 논의해야 할 과제임에도 고용노동부가 일방적으로 지침의 제·개정을 추진한 것에 대해 노사정 합의 정신을 훼손하고 있다는 평가를 받고 있다. 고영국(2015), <노사정위 '2대 지침' 논의의 주요 쟁점과 제언>, 민주정책연구원 이슈브리핑, 2015-35호, 1면; 장홍근(2017), 「노동개혁 정책과 평가」, "[구조개혁 정책세미나] 지난 4년간의 구조개혁, 성과와 반성", 한국개발연구원 (KDI), 2017. 04. 04., 7-8면.

행과 2017년 08월 신정부와 생각의 틀을 같이하는 고용노동부장관(이하 '노동부장관'이라 한다.)의 취임에 따른 결과물로서 2017년 09월 25일 '양대 지침'을 폐기하게 되었음을 공식적으로 발표하기에 이르게 되기까지 '양대 지침' 정책의 입장을 고수하며 유지하였던 바 있다. 이제는 지나간 일련의 일들과 과정을 교훈삼아 원칙에서 벗어난 개혁은 개악으로 치부될 수밖에 없다는 점을 인지해야만 한다. 현재 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서는 사회공동체가 추구하는 기본적 이념과 존중되어야 할 가치에 대해서 국가의 최고법규범인 헌법에 명시하고 하위입법에서 갖추어야할 기본적 원리를 밝히고 있다. 이러한 원리에 기초하여 본다면, 노동개혁은 「대한민국헌법」(이하 '「헌법」'이라 한다.) 제32조와 제33조에 반하지 아니하여야하고 노동법상 공서와 기본 원칙에 부합할 것과 책임과 부담에 상응하는 권한으로 보상하여야 한다는 점에[4] 주목할 필요가 있다.

이제까지의 노동 분야의 연구는 노동법학 측면에서의 접근이 다수였으며 헌법학에서는 자유, 결사, 재산 또는 문화 등과 같은 주제에 치중되어 연구가 활발히 진행되었고, 그에 반해 노동이라는 분야 연구는 상대적으로 다루어지지 않고 있다. 하지만 앞으로는 노동 분야 역시 국가의 의무, 인간의 존엄성 및 자유와 재산에 관한 헌법적 규범으로 풀어내야 한다.[5] 그것은 국가의 최고 법규범으로서 모든 법의 모법이자 가장 근간이 되며 주권자인 국민에 의해 제정된 「헌법」으로부터 노동법의 정당화 근거를 논증하고자 하는 것이므로 어쩌면 너무나도 당연한 움직임이다.

국민의 기본권 보장을 본질적 징표로 하는「헌법」과 노동 문제에 대해 「헌법」상의 기본권 보장 실현을 위한 「근로기준법」은 노동기본권에 대한 기본적 법규라 할 수 있다. 노동기본권은 1919년 바이마르 헌법의 기본권 구조에 뿌리를 두고 있으며, 건국헌법 입법 당시 일본의 제국 헌법과 독일 바이마르 헌법을 참조하였던 우리 「헌법」에서도 제32조와 제33조에 걸쳐 노동기본권이 우리 국민의 기본적 권리임을 명시하고 있다.[6] 이를 살펴보면 제32조에서는 자유권적 성격과 사회권적 성격을 두

---

4)강성태(2015), 「915노사정 대타협과 법적 쟁점」, 노동법 3개 학회 공동 토론회, 2015. 10. 14.., 32면.
5)강희원(2000), 「노동3권의 법적 성격과 노동단체법」, 헌법실무연구회 월례발표회, 2000. 04. 07., 14면.
6)시행 1988.2.25. 헌법 제10호, 1987.10.29., 전부개정 기준,; 건국헌법(시행 1948.7.17. 헌법 제1호, 1948.7.17., 제정) 당시에는 제17조와 제18조에서 규정하고 있었고 건국헌법 제정 당시에는 근로권과 노동3권 뿐 아니라 노동자의 이익배분균점권도 그 내용에 포함하여 노사관계를 통한 사회적 복지국

루 갖춘 사회적 기본권으로서 근로기회청구권과 국가의 고용증진의무, 해고 자유의 제한, 적정임금의 보장, 노동조건 기준의 법정 주의 등 실질적 보장을 요구하고 있으며, 제33조에서는 이른바 '노동3권'이라 불리는 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 그 내용으로 하여 현실적이고 구체적인 권리로써 보장해야 함을 명백히 하고 있다.

이처럼 명백히 「헌법」상 보장된 국민의 기본권임에도 불구하고 정부는 국민적 이해와 사회적 합의를 통한 법률의 개정도 아닌 단순히 '행정 지침'에 불과한 '양대 지침'으로 노동 시장을 규율하려 하는 움직임을 보였던 것이다. 이에 국가인권위원회는 '양대 지침'은 법규적 효력도 없는 단순한 안내서에 불과한 것인데도 불구하고 노동부가 이를 적극적으로 홍보하고 소속기관에 시달해 활용하게 한 것에 대하여 국민의 권리를 사실상 규율하는 결과가 있을 수 있음을 우려하고 국민의 노동의 권리가 약화되지 않도록 조치할 필요가 있다고 판단하여 상임위원회가 우려의 의견표명[7]을 한 바 있다.

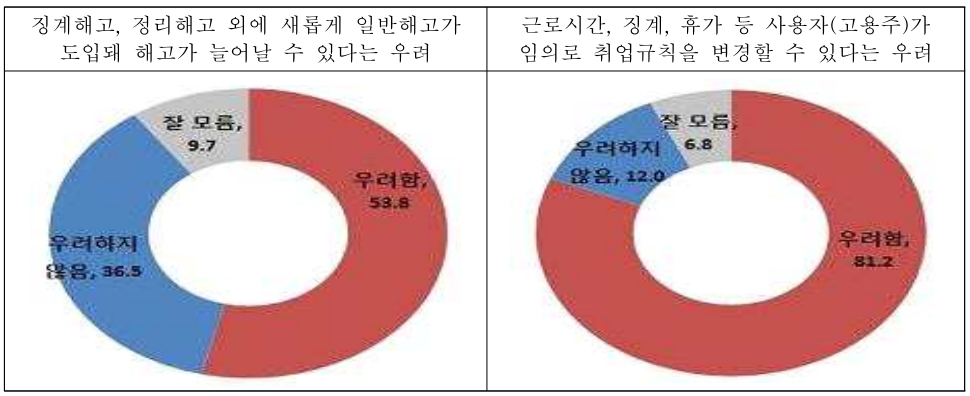
이렇듯 '양대 지침'이 근래 들어 기본권과 노동 분야에 있어 가장 큰 이슈였다는 점을 들어 논의의 대상으로 삼고자 하였다. 다만, 본고에서는 연구범위의 한계를 감안해 2015년 09월 대타협 당시 임금 노동자를 대상으로 진행되었던 여론조사결과[8]

가를 지향하는 현대적 의미의 기본권 보장 내용도 담고 있었다.

7)이에 대한 더 자세한 논의는 국가인권위원회(2016), 상임위원회 결정례 : 고용노동부 「공정인사지침」 및 「취업규칙 해석 및 운영지침」에 대한 의견표명, (2016. 08. 25.)을 참조할 것.

8)본 자료는 '노사정합의에 대한 임금 노동자 여론조사보고서'로써 민주노총의 의뢰로 한길리서치가 수행하였고 표본오차는 95% 신뢰수준에 오차범위는 ±3.5%p이며 2015. 09. 19.~23. 조사 후 작성됐다.

<그림 1> 양대 지침에 대한 임금 노동자의 우려도 비교.



출처 : 노사정합의에 대한 임금 노동자 여론조사보고서(2015. 09.) 참조하여 재정리.

의 내용을 기준으로 하여 정부의 '양대 지침' 정책 중 '취업규칙 해석 및 운영지침' 정책이 "우려스럽다"고 응답한 정도가 '공정인사지침' 정책보다 약 27.4% 가량 더 높았다는 점과 정부 기관의 평가[9]에 주목해, "취업규칙 제도"에 주제를 한정하여 다루고자 하며 노동기본권에 기초한 헌법적 이념과 가치관으로 현실의 노동 문제를 조망하는 방식을 사용해 사안에 접근하고 그로부터 노동기본권의 향상 방안에 대해 논의하고자 한다.

또한 본고에서는 인용문에서의 표현을 제외하고는 '근로'라는 표현 대신 '노동'이라는 용어의 표현을 주로 사용하고자 함을 미리 밝혀둔다. 근로라는 표현은 아마도 우리 「헌법」 제32조 제2항에서 '근로의 의무'를 규정하고 있기에 따르게 된 용어라고 보인다. 이에 우리 사회 전반에서 만연하게 사용되고 있는 '근로'라는 용어는 어쩔 수 없다하더라도, 본고에서는 「헌법」상 권리인 노동기본권에 대해서 주로 논하는 만큼 '근로'가 아닌 '노동'이라는 용어로 표현하는 편이 더 부합한다고 보인다. 이는 부지런히 일하는 행위와 그 행위를 행하는 자에게만 기본권으로서의 보호가치를 발하는 것이 아닌, 모든 노동이 그 자체로서 우리 「헌법」이 보장하고자 하는 노동기본권에 부합하는 것이고 그 보호가치 역시 충분하다고 판단되기 때문이다. 이는 아마도 우리 사회에서 '노동법'이 '근로법'으로 '노동문제'가 '근로문제'로 표현되지 아니하는 이유와도 같게 볼 수 있지 않을까 생각한다.[10]

---

9)국회의 입법조사처는 취업규칙 불이익 변경요건과 관련된 사항이 일반해고 가이드라인과 함께 노동시장 구조개선에 있어 가장 첨예하게 대립하는 쟁점 중 하나라 평가하며 국회 입법 과정에서도 제·개정 과정에 가장 어려움이 따를 것이라 판단하고 우려하고 있다. 전형진(2015), <노사정 대타협 논의의 주요쟁점>, 국회입법조사처 이슈와 논점, 제978호, 2-3면.

10)관계된 의견으로 성낙인 교수도, "오늘날 헌법이념을 구체화한 관련 법률에서는 근로라는 표현보다 노동이라는 표현이 일반화 되어 있음에 비추어 헌법상 근로라는 용례를 노동으로 바꾸는 것이 일반적인 용례에 오히려 부합한다."고 판단한 바 있다. 성낙인(2017), 『헌법학』, 법문사, 1422면.

제2절 연구의 범위와 방법

본 연구는 '제1장 서론'에서 제기한 문제의식을 바탕으로 하여, '제2장 '노동'의 헌법적 가치'부분에서 기본권의 의의와 역사적 배경에 대한 이론을 살펴 형성사를 확인하고, 헌법이 수용하고 있는 기본권의 이념에 대해 개괄적인 시각으로 연구를 진행하고자 한다. 또한 우리 「헌법」이 보장하고 있는 여러 가지의 기본권 중에서도 본고의 논의에 가장 적합한 사회권적 기본권과 그 일부분인 노동기본권을 중심으로 학설과 판례, 결정례 등의 입장을 살펴 기본권에 대한 헌법적 함의를 확인해 취업규칙제도와 관련된 노동 문제의 판단 근거로 삼고자 한다.

다음으로 '제3장 헌법적 이념에 기초한 취업규칙제도'에서는 「헌법」상의 노동기본권 조항의 요청에 대한 응답으로서 노동기본권의 실현과 실질적 보호를 목적으로 제정된 「근로기준법」의 개별 조항을 검토하여 현행 취업규칙 제도가 가지고 있는 각론적 의미를 파악하고자 하며, 이전부터 노동법학계에서 구구한 논의가 이어졌던 취업규칙의 법적 성질과 효력, 법적 구조에 대해 학설과 판례, 행정해석 등의 입장을 확인하고 노동기본권의 본질에 비추어 점검하고자 한다.

한편, '제4장 취업규칙과 관련된 행정지침의 쟁점과 문제'에 이르러서는 최근 진행되었던 바 있었던 노동부의 '취업규칙 해석 및 운영 지침'과 같은 행정기관의 작용으로 인해 우리 「헌법」이 법률로써 국민에 대해 보장하고 있는 노동기본권이 제한될 수 있는가 하는 점에 대해서 기본권 침해의 소지 검토와 위헌성 등의 한계점을 확인하고 그로인한 문제를 진단해보기로 한다. 또한 그에 비추어 취업규칙의 불이익한 변경 요건 완화와 관련된 논의에 대해서도 제도적 대안을 모색해 제시하는 것을 목표로 하겠다.

제2장 ‘노동’의 헌법적 가치

오늘날에 이르러 우리가 살아가고 있는 현대 사회에서는 이 사회를 지탱하고 있는 노동자들의 지위와 권리가 신자유주의의 물결 속에 나날이 왜소화 되어가는 현상이 어느 한 분야를 주로 꼽을 수도 없이 여러 분야에 걸쳐서 빈번하게 발생하고 있으며, 이 같은 현상은 내적 · 외적의 사회적이고 경제적인 요인들에 의해 노동자들의 지위와 권리를 더욱더 연약하게 만들고 있는 측면이 있다.

이럴 때일수록 노동자들의 실질적 권리인 노동기본권은 헌법적 의미에 보다 가깝게 읽혀지고 풀이되어야 할 필요성이 제기되는데, 그것이야말로 궁극적으로는 우리나라의 노동 현실에 있어 비로소 국민의 기본적 가치의 보장으로 하나하나 고루 투영되는 계기가 되어줄 것이라 기대할 수 있기 때문이다.[11] 이 같은 점에 기초해서 볼 때, 최근 이슈가 되었던 취업규칙 제도와 관련된 문제 역시 우리 「헌법」이 담아내고 있는 노동에 대한 이념적 의미에 보다 가깝게 이해되고 해석되어 문제를 해결해야할 필요성이 발생하게 되는데, 이를 위해서 먼저 기본권의 형성과정과 노동의 헌법적 가치를 확인해 노동기본권에 대한 헌법적 함의를 구체화하여 취업규칙제도와 관련된 노동 문제의 판단 근거로 삼고자 한다.

제1절 기본권으로서 노동의 보장과 변천의 개괄적 검토

Ⅰ. 근대적 기본권의 발달과 노동인권의 충돌

오늘날 기본권 보장은 사실상 노동자들의 권리투쟁으로부터 시작되어 실질적인 보장으로까지 귀결되었다고 본다하더라도 과언이 아니다. 기본권의 역사를 돌이켜본다면 기본권이 인권사상에 기초하고 있다는 것을 알 수 있는데, 인권사상은 인류의 역사만큼이나 오래 된 것이므로 막상 그 뿌리를 정확히 밝혀낸다는 것은 결코 쉬운 일

11)김진곤(2012), 「노동복지의 헌법적 기초로서 노동기본권 -근로의 권리와 노동3권을 중심으로-」, 『헌법학연구』 제18권 제3호, 한국헌법학회, 78면.

이 아니며, 누구도 기본권의 정확한 기원이 이때라고 집어 말하기는 힘들다는 문제가 있다.[12] 우리가 가늠해볼 수 있는 범위 내에서 근대적 인권의 헌법적 수용에 대해 논하자면 시기적으로 영국의 사례를 먼저 접하게 된다. 하지만 영국의 권리장전 사례는 영국인의 기존의 자유와 권리를 재확인한 것에 불과한 것이거나 절차적 보장에 역점을 두었을 뿐 실질적으로는 천부인권의 불가침을 선언한 것이 아니라는 견해가[13] 우세하다.

이 같은 연유로 기본권은 실질적으로 근대자연법론과 사회계약론, 계몽주의 사상에 기초해 천부적 인권설이 제기되기 시작한 18세기에 접어 들어서서야 비로소 급진적으로 발전하기 시작하였으며, 이러한 기본권의 초기 발전은 미국의 독립혁명의 결과물인 '버지니아권리장전'[14]과 프랑스의 시민혁명의 결과인 '인간과 시민의 권리선언'[15]으로 인해 최초로 구현된 근대 시민국가와 보다 밀접한 관련이[16] 있다고 보는 주장이 오히려 설득력이 있다고 본다.

이 시기 근대적 기본권 시대[17] 국가들의 헌법은 인류의 자유를 향한 열망에 따라

---

12)허 영(2017), 『한국헌법론』, 박영사, 213면.; 권영성(2011), 『헌법학원론』, 법문사, 288면.

13)권영성, 앞의 책, 289면.

14)1776년 채택된 미국의 버지니아권리장전은 전형적인 인권선언으로 평가되는데 국민주권 원리와 함께 생명권·자유권·재산권·저항권 등을 규정해 인권을 천부적 자연권으로서 인정하였으며 이는 자연법사상이 자연권적 권리로 변모되어 가고 있음을 나타낸다. 미국의 독립선언문 전반부에서도 "우리는 다음과 같은 사실을 자명한 진리로 확신한다. 모든 인간은 태어나면서부터 평등하고, 창조주로부터 불가양의 권리를 부여받았으며, 그 권리 중에는 생명의 자유와 행복을 추구할 권리가 포함되어 있다." 고 명시하며 인권의 자연법적 기초를 부여하고 천부적 권리로서 생명·자유·행복추구권을 선언함으로서 근대국가 헌법 중에서는 최초로 인권을 헌법에 수용하여 직접적으로 기본권이 보장될 수 있도록 하였다는 평가를 받고 있으며 현재까지도 유효한 헌법으로써 작용하고 있다.

15)프랑스의 인권 선언은 프랑스 혁명이 한창 진행되던 1789년 국민의회가 「인간과 시민의 권리선언」이란 이름으로 선포한 것을 말하며, 전문에서 "모든 사회 구성원에게 항상 제시되어 언제나 자신들의 권리와 의무를 떠올리게 하는데 목적이 있고 시민의 요구가 원칙에 입각해 제기됨으로써 체제가 유지되고 만인이 행복을 누릴 수 있도록 기여하는데 목적이 있다."고 밝히고 있다. 이러한 프랑스의 인권 선언은 혁명헌법의 탄생으로 이어졌으며 또 세계 각국의 헌법과 정치에 상당한 영향력을 미치며 기본권 역사에 있어서는 기념비적 가치를 인정받았고, 오늘날까지 헌법적 규범과 기본원리로서 정립되어 있다.

16)김철수 교수도 "영국에 있어서는 인권이 자연권으로 인정되었다기보다는 실정권으로 인정되었다. 이것이 Locke나 Montesquieu의 이론에 따라 자연권으로 규정된 것은 미국의 인권선언에서 비롯되었다."는 견해를 밝힌 바 있다., 김철수(2007),『헌법학개론』, 박영사, 337-338면.

17)근대적 기본권 시대의 전체적인 특징을 정리하자면 국민주권원리의 선언, 자유권 중심의 기본권 보장, 형식적 측면에서의 법치주의의 시작, 대의제원리의 도입, 권력분립의 원리 중시, 성문헌법주의를 꼽을 수 있다. 강경선(2017), 『헌법 전문 주해』, 에피스테메, 29면.

쟁취하게 된 권리인 만큼 자유권의 성격이 무엇보다 강했으며, 기본권의 목적은 인권이고 국가권력은 단지 수단일 뿐이라는 자유주의적 이념을 헌법상에 명시해 두었다는 특징을 지니고 있다.

이처럼 자유권이 헌법적으로 수용됨에 따라서 시민들은 사유재산을 절대적으로 보장받기 시작했으며, 그 결과 민주주의와 자본주의경제가 눈부시게 발전하게 되는 계기가 되기도 했다. 하지만 그 이면에서 나타난 부의 편재 등 자본주의경제 모순과 폐해로 인해 빈곤이 급격하게 확대되고 실업률이 급증하게 됨으로써 노동자들은 항상 실업의 불안에 시달리게 되었으며, 그로부터 노 · 사 간의 대립이 격화되어 가는 등의 문제가 발생하게 됨에 따라 사회적 갈등의 심화로 이어지는 문제가 발생했다.

그와 같은 당시 근대 시민국가의 사회적 분위기 속에서 정의사회 구현의 요청과 사회복지국가의 이념이 정책적 가치로 부각되기 시작하면서 자유권의 전성기는 서서히 저물어 가게 됐고 국가의 급부나 수익을 요구할 수 있는 사회적 기본권에 대한 논의가 본격적으로 대두되기 시작했으며, 바로 이 시기가 노동의 권리라는 개념이 보다 적극적으로 논의되기[18] 시작한 시점이라고도 짚어 볼 수 있다.

Ⅱ. 노동인권의 보장과 현대적 기본권으로의 전환

18세기의 근대적 기본권 구조를 자유권적 기본권의 시대로 표현할 수 있다면, 20세기에 들어서서는 인간다운 생활의 최저선 만큼은 보장받기 위해 사회권의 보장을 요구하는 움직임이 전개됨에 따라 사회적 기본권을 보장하는 현대적 기본권 구조로의 변경을 겪게 된다.[19] 이는 이전까지의 근대적 기본권 시대는 인간의 자유와 권리 보장을 목적으로 하는 자유권 중심의 전개였다고 평가할 수 있다면, 현대적 기본권 시대에서는 경제적 약자 등 국민의 자유와 평등을 실질화 하여 인간다운 생활을 보장하기 위한 사회권이 그 중심에 서있는 것이다.[20]

---

18)김형배(2016), 『새로 쓴 노동법』, 박영사, 105면.

19)이 같은 현대적 기본권 시대의 특징은 냉전체제로 인한 국민주권원리와 인민주권원리의 대립과 공존, 실질적이고 절차적인 법치주의의 발달, 자유권의 실질적 보장과 노동기본권과 사회보장 측면의 사회권 강조, 행정국가와 적극국가의 요청, 헌법재판제도의 발달과 사법국가화 경향, 정당제도의 발달, 국제평화주의의 모색 등으로 정리해볼 수 있겠다. 강경선, 앞의 책, 에피스테메, 31면.

이처럼 변화된 기본권 구조는 자유권의 생활권화 현상으로서 자유권의 의미와 기능이 단순한 방어권으로서가 아니라 생활권적인 시각에서 이해하려는 경향으로 점차 변화된 것이라 표현할 수 있다.[21] 이 같은 변화는 자유권을 실질적으로 보장하기 위해서는 사회권이 필요하고 동시에 사회권이 보다 잘 보장되기 위해서는 그 기초로 자유권이 보장되어야 하는 것이므로,[22] 사회권은 확대된 자유권이자 성숙된 자유권이라 말할 수 있는 것으로,[23] 이는 산업사회로의 발달로 인해 사회적 기본권의 중요성이 점차 증대되면서 발생하게 된 자연적인 현상이라고 정리된다.

이 같은 시대적 배경 속에서 등장하게 된 독일의 바이마르 헌법(1919년)은 사회주의적 이념을 수용하여 헌법적으로 표현함으로서 탄생한 20세기 현대적 기본권 구조의 전형이라고 평가할 수 있다. 바이마르 헌법은 사회권을 헌법에 명문으로 규정하여 도입하였고 소유권에 공공복리에 이바지해야하는 의무를 지웠다. 또 노동자와 사회적 약자를 위한 각종 기본권을 구비하였고, 주권행사의 강화와 함께 기본권에 대한 국가의 보호의무가 일반화되는 등 사회적 기본권과 사회국가원리 등을 반영하였으며, '기본권'이라는 표현을 처음으로 사용하게 되면서 바이마르 헌법은 현대적 기본권을 헌법에 수용한 최초의 헌법이자 진보적 헌법이라 평가 받고 있다.[24]

이후 바이마르 헌법이 각국의 헌법 형성사에 영향을 미치게 됨에 따라서 20세기는 사회적 기본권이 헌법상 주요한 보장 가치로 귀결되는 흐름을 보이게 되었고, 시대의 흐름과 요구에 따라 기본권의 효력은 더욱 강화되며 헌법과 기본권의 우위로부터 기본권의 전 사회에 대한 방사적 효력을 인정하기에 이르렀다. 그로 인해 기본권은 국가권력에 대해서만이 아니라 제3자적 일반 사적 영역에까지 수평적 효력을 미치게 된 측면이 있다. 하지만 회사의 사적 자치원리와 기본권의 수평적 효력은 현실에서 노동기본권이 여실히 보여주고 있는 바와 같이 갈등이 심한 상황에[25] 처하여 있다.

---

20)김철수(2016), 『헌법과 법률이 지배하는 사회』, 진원사, 13면.
21)허 영, 앞의 책, 219면.
22)강경선(2017), 『헌법의 기초』, KNOU PRESS, 319면.
23)_____, 앞의 책, KNOU PRESS, 333면.
24)바이마르 헌법의 주된 내용으로는 국민주권의 승인, 사회적 기본권 전면 긍정, 광범위한 사회화정책 등을 담았고 그로인해 자본주의체제에서 탄생한 가장 진보적인 헌법으로 평가 받는다. 이상영 · 이재승(2005), 『법사상사』, 한국방송통신대학교출판부, 266면.
25)강경선, 앞의 책, 에피스테메, 35면.

Ⅲ. 우리 헌정사 속의 기본권과 노동인권

우리 「헌법」에서는 기본권이라는 용어 자체를 직접적인 표현으로 언급하고 있지는 않다. 다만 「헌법」상 개별 조항을 살펴보면 제2장 '국민의 권리와 의무'에 기본권이 속해있고, 그 중 제10조 '인간의 존엄성과 기본인권보장' 조항을 시작으로 제36조에 걸쳐 개별적 기본권으로서 기본적 권리를 나열하여 그 가치를 확인하고 보장하고 있음을 알 수 있다. 또, 그러한 기본권 조항들을 통해 우리 「헌법」이 인간을 모든 것의 중심에 두려고 하는 헌법질서 이념을 표방하고 있음을 유추할 수 있고, 이는 헌재가 보는 인간의 존엄과 가치에 대한 판단의 입장과도 크게 다르지 않다.

> "…헌법 제10조에서는 "모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다"라고 하여 모든 기본권의 종국적 목적이자 기본이념이라 할 수 있는 인간의 존엄과 가치를 규정하고 있는바, 이는 인간의 본질적이고도 고유한 가치로서 모든 경우에 최대한 존중되어야 한다.…"[26]

이에 기초하여 인간의 존엄과 가치의 측면으로 본 우리나라 노동입법상의 법체계는 「헌법」상의 노동기본권 보장을 정점으로 하는 구조를 지니고 있다. 이것은 본래 노동법이란 노동기본권의 전개로서의 법체계이며[27] 이는 국가의 최고 법규범인 「헌법」상의 노동이념과 가치를 반영하려하는 움직임을 노동입법으로 표현해낸 것이므로 너무나도 당연한 것이다. 하지만 노동입법의 전개과정 등의 변천사 속에서 우리 노동법은 당시 정치 · 경제적 상황에 따른 영향을 받아 그 내용이 변경되는 등의 방식으로 개정이 진행되어 왔던 측면이 있다. 특히 「헌법」의 전문개정의 시기에는 「헌법」상의 노동기본권 조항과 더불어 노동관계법제 역시 크게 변동 되는 것을 겪을 수밖에 없었던 역사적 사실이 있다.[28]

이 같은 점에 있어서 우리 헌정사를 돌이켜보면 1948년 당시의 우리 건국헌법은 일제의 식민지였던 역사적 사실과 해방 이후의 미군정 등을 시대적 배경으로 하고

---

26)헌재 2001.7.19. 선고 2000헌마546 결정.
27)신인령(1999), 『노동인권과 노동법』, 도서출판 녹두, 239면.
28)_____, 앞의 책, 105면.

있던 탓에 일본의 제국 헌법과 독일의 바이마르 헌법의 영향을 주로 받아 현대적 기본권 구조를 표방하고 있었던 것을 알 수 있고, 그로 인해 헌법 제정 당시부터 이미 사회복지국가 헌법의 기틀을 일정부분 이미 마련해두고 있었던 것으로 이해된다.[29]

하지만 당시의 건국헌법은 기본권을 헌법의 내용으로 수용하여 보장하고 있다는 점에 있어서는 의의가 있지만, 다른 한편에서는 우리의 인권 투쟁의 산물로써 얻어진 것이 아닌 연합군과 미군정 당국의 영향이 컸으므로 건국헌법에 보장되어있는 기본권은 실질적으로는 다분히 선언적 의미 이상을 갖기는 어려웠다.[30]

또한 건국헌법의 제17조와 제18조에서 노동기본권의 보장을 명시하고 있었음에도 불구하고 그에 따른 후속조치로서의 입법이 진행되지 않고 있다가 노동자들의 실업과 생활고가 가중되고 노동운동의 탄압으로 노동자들의 노동쟁의가 격화되어 더 이상 적극적 노동정책의 실시를 미룰 수 없는 상황에 이르게 되자 건국헌법 제정으로부터 5년이 지난 1953년에 이르러서야 노동기본권의 보장을 실체화하는 노동입법을 실시하기에 이르렀다. 이러한 배경을 가진 당시의 「근로기준법」은 건국헌법상의 노동기본권을 실체화하기 위한 노동입법의 일환으로서 헌법상 권리인 인간다운 생활을 위한 최저 근로조건의 법정과 이에 미달하는 근로조건의 무효, 해고의 제한, 남녀의 균등한 처우, 퇴직금제도, 취업규칙 제도 등을 규정해두고 근로감독관제도와 벌금부과제도를 통하여 동 법의 강행성을 담보하게 되기 시작하면서 노동인권의 신장을 도모하게 되었던바 있다.[31]

그러나 당시 헌법상의 기본권은 각각에 마다 법률유보조항을 두어 법률로써 기본권을 제약할 수 있는 체제를 갖추고 있었던 만큼,[32] 여전히 기본권을 천부인권으로서의 기본권이 아닌 실정헌법상의 권리로 여겨지고 있었고, 1960년 개헌에 이르러서야 개별적 법률유보조항을 삭제하고 자유권의 자연권적 성격을 강조하게 되기 시작했다.[33] 그 후에도 우리 헌법은 몇 회의 개헌을 거치게 되었는데 그에 맞추어 우리 국민의 기본권 역시 진보와 쇠퇴하기를 반복하였고, 그에 따라 노동기본권을 기초로

---

29)강경선, 앞의 책, KNOU PRESS, 40면.
30)허 영, 앞의 책, 223면.
31)신인령, 앞의 책, 107면.
32)김철수, 앞의 책, 박영사, 343면.
33)강경선 · 서경석 · 이경주(2005), 『헌법Ⅰ』, 한국방송통신대학교출판부, 86-88면.

하고 있는 노동 인권 역시 신장과 퇴보를 반복하게 되었던 사실이 있다.

1987년 현행 「헌법」에 들어서게 되서야 비로소 국민의 기본권을 강화하기 위해 새로운 유형의 기본권을 신설하고 절차적 보장을 확대하였는데, 특히 신체의 자유에 관한 적법절차가 강화됐으며 생존권적 기본권 측면에서도 노동3권과 사회적 약자에 대한 권리가 신장되는 계기가 된다. 또한 기본권의 실효적 보장기구로서 헌법재판소(이하 '헌재'라 한다.) 설치를 규정하게 됨으로써, '제3공화국' 이후 군사정권하에서 실효성을 발휘하지 못했던 기본권 규정이 '제6공화국'에 들어서야 비로소 적용되기 시작했다는 평가를 받게 되었고,[34] 이로 인해서 현행 「헌법」은 우리 헌정사상 가장 진보적이고 자유주의적 헌법이라고[35] 평가 된다.

제2절 헌법적 가치로서 사회적 기본권과 노동기본권

Ⅰ. 사회적 기본권의 법적 성격에 관한 논의

앞서 확인한 바와 같이 사회적 기본권은 산업혁명 이후에 직면하게 된 자본주의 경제체제의 모순과 사회적 갈등 심화 등으로 나타나게 된 일련의 사회현상에 대한 반성적 극복으로 탄생하게 되었고, 궁핍으로부터의 자유와 실질적인 자유 실현을 위해 궁리된 기본권이다.[36] 이 같은 발생사적, 이념적, 현실적 차이로 인해 자유권적 기본권과 사회적 기본권은 그 효력이 다소 상이하다고는 하지만 그렇다고 이를 양자로 구분시켜서만 볼 것이 아닌, 사회적 기본권을 자유권적 측면과 생존권적 측면을 두루 갖추고 있는 복합 · 다측면적 구조의 기본권이라고 이해하려는 것이 필요하다.

이는 다시 사회적기본권이란 자유권적 기본권의 성숙단계에서 요청되는 기본권이라고 표현할 수 있으므로, 자유권적 기본권이 그저 형식적인 보장에 그치는 것이 아

34)김철수, 앞의 책, 박영사, 346면.

35)"제5공화국 전(全)대통령시대의 인권상황에 대한 반성에서 출발한 우리의 현행헌법은 우리 헌정사상 인권의 헌법적 수용의 측면에서 가장 진보적이고 자유주의적 내용을 담고 있다고 할 것."이라고 표현하고 있다. 허 영, 앞의 책, 223면.

36)최규환(2014), 「사회적 기본권의 사법심사 가능성」, 박사학위논문, 고려대학교, 24면.

니고 실질적인 측면에서의 보장까지 추구되는 것으로 이해되어야 하는 것이라면 필연적으로 사회권적 기본권까지 요청되는 것으로 이해되어야 한다.[37] 또 한편으로 사회적 기본권 중에서도 노동3권과 교육 받을 권리, 환경파괴에 따른 생명 · 건강의 침해 등 일정 한 부분에 있어서는 국가적 침해행위에 대해 배제를 요구하는 자유권적 기본권 측면으로서의 효력 역시 직접적으로 가진다.[38]

전통적 측면에서의 사회적 기본권은 인간의 경제적인 궁핍상황의 극복은 국가의 정책적인 배려를 통해 해결해야한다는 명제에서부터 출발한다. 이는 본질적으로 경제적 · 사회적 약자를 위한 권리로서의 속성을 띄며 복지국가 · 급부국가의 모습으로서 나타나고 있는 것이다. 또한 사회적 기본권은 개념적 징표로 '이념'으로서 '인간다운 생활의 보장'과 '내용'으로서 '국가적 급부와 배려' 그리고 '실현형태'로서의 '헌법적 보장'을 들고 있으며,[39] 주로 그 보호의 대상은 산업사회의 진전에 따라 대량으로 배출된 춥고 배고픈 무산대중으로 한다.[40]

이러한 점에 비추어 볼 때 사회적 기본권은 '국민이 인간다운 생활과 생존을 확보하기 위해 국가에 급부와 배려를 요구할 수 있는 권리'로 풀이된다. 이는 국가에 사실적 급부를 청구하는 일종의 급부권으로도[41] 해석되며, 우리 헌재 결정례도 사회적 기본권을 급부와 배려를 요구할 수 있는 권리로 보고 있는 등 입장의 차이가 없다.

> "…헌법 제32조 및 제33조에 각 규정된 근로기본권은 근로자의 근로조건을 개선함으로써 그들의 경제적·사회적 지위의 향상을 기하기 위한 것으로서 자유권적 기본권으로서의 성격보다는 생존권 내지 사회권적 기본권으로서의 측면이 보다 강한 것으로서 그 권리의 실질적 보장을 위해서는 국가의 적극적인 개입과 뒷바침이 요구되는 기본권이다.…"[42]

이 같은 급부권이 법과 제도를 통해 현실적인 권능으로 실현되려면 보다 적극적인 국가적 개입과 뒷받침이 요구되는데, 우리 「헌법」은 국내적인 생존권의 보장을 위

---

37)강경선, 앞의 책, KNOU PRESS, 334-335면.
38)권영성, 앞의 책, 649면.
39)_____, 앞의 책, 644면.
40)성낙인, 앞의 책, 1381면.
41)이준일(2004), 「사회적 기본권」, 『헌법학연구』 제10권 제1호, 한국헌법학회, 454면.
42)헌재 1991.7.22. 선고 89헌가106 결정.

하여 제119조 제2항에서 “국가는 균형 있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다.”라고 규정하며 생존권 측면에서 인간다운 생활을 할 권리인 사회적 기본권의 실현은 사실상 국가의 책무임을 에둘러 표현하고 있다는 점도 주목할 가치가 있다.[43]

반면 재판상의 규범으로서 사회적 기본권을 바라보는 헌재의 시각은 사회적 기본권이 「헌법」에 보장되어있다는 사실만으로는 그 내용을 명확하게 확정하기가 상대적으로 어렵고 불완전하다는 특징이 있으므로, 이러한 점을 극복하고 법률적 권리로서 인정받기 위해서는 반드시 하위 입법을 통해 구체적인 형성이 뒷받침 되어야한다는 것이 우리 헌재가 취하고 있는 결정례의 일관된 입장이다.[44] 또한 이러한 경우에도 무조건적인 최우선의 배려로 국가의 입법과정이나 정책결정과정에서 반영해야할 의무를 가지고 있는 것이 아닌 적절한 고려를 요청하는 것이며, 국가의 모든 의사결정과정에서 사회적 기본권이 담고 있는 국가목표를 고려해야 할 국가 의무를 의미한다고 판시한 바 있다.[45]

이는 결국 사회적 기본권의 보장은 국가의 한정된 자원을 배분하는 문제와 결부되고 그로 인하여 사법부를 통한 권리 구제에 한계를 둘 수밖에는 없다는 점과 국가의 재정적 상황과 경제적 여건에 전적으로 의존할 수밖에 없는 현실 등을 들어 입법자의 재량을 보다 광범위하게 인정하고 있는 것으로 보인다.[46]

> “…인간다운 생활을 할 권리가 최소한의 물질적인 생활의 유지에 필요한 급부 이상을 요구할 수 있는 구체적인 권리를 직접 발생케 한다고는 볼 수 없고 이러한 구체적 권리는 국가가 재정형편 등 여러 가지 상황을 종합적으로 감안하여 법률을 통하여 구체화 할 때에 비로소 인정되는 법률적 차원의 권리로서 입법자에

---

43)김철수(2012), 『헌법정치의 이상과 현실』, 소명출판, 107면.

44)헌재는 결정례에서 꾸준히 추상적 권리설에 무게를 싣고 있다. 헌재 2005.7.21. 선고 2004헌바2 결정.; 2004.10.28. 선고 2002헌마328 결정.; 2003.5.15. 선고 2002헌마90 결정.; 2000.6.1. 선고 98헌마216 결정.; 1999.12.23. 선고 98헌바33 결정.; 1995.7.21. 선고 93헌가14 결정 참조.

45)헌재 2002.12.18. 선고 2002헌마52 결정.

46)홍석한(2015), 「사회적 기본권의 법적 성격에 대한 고찰」, 『법학연구』 제23권 제4호, 경상대학교 법학연구소, 417-418면.

게 광범위한 입법재량권이 인정되므로 인간다운 생활을 할 권리를 침해하였다고 할 수 없다.…"[47]

하지만 학자들은 사회권도 「헌법」에 명문으로 규정된 이상 국민의 권리로 봐야 한다고 주장한다. 개개인의 국민은 국가의 구체적 행위로 건강하고 문화적인 최저한도의 생활이 침해당할 경우 헌법소원과 소송을 통해 침해행위 배제를 주장하는 것은 당연한 것이고 이러한 점에서 침해배제 청구권으로서 구체적 권리를 가지고 있는 재판규범이라는 것이다. 또, 사회권적 기본권에 대한 입법조치가 없으면 행정권을 전혀 구속할 수 없다는 설을 부정하며 입헌주의 원칙에 따라 입법권과 사법권에 대한 구속을 통해 입법을 행하게 하여 행정권 구속력을 강화하는 방안을 제시했다.[48]

또 다른 한편에서는 사회적 기본권이 자유권적 기본권처럼 직접 효력을 가지는 완전한 의미에서의 구체적 권리는 없다 할지라도, 적어도 청구권적 기본권이나 정치적 기본권의 일부와 동일한 수준인 불완전하나마 구체적 권리로서의 성격을 띠고 있는 '불완전한 구체적 권리'[49]라는 주장도 있으나, 그 의견은 다수의 동의를 얻지 못하는 듯 보인다.[50]

만일 우리 헌재의 입장과 같이 하위 입법이 따르지 않을 경우 사회적 기본권을 구속력이 없는 기본권으로만 인식하는 경우에는 사회적 기본권을 허울뿐인 외형적 측면의 기본권으로 이해하게 됨으로서, 「헌법」상 사회적 기본권의 공동화(空洞化)를 불러오게 되고 최고법인 「헌법」에 대한 존중정신의 약화를 초래할 수 있다.[51] 또한 현재 우리나라도 헌법재판소가 설치되어 있기에 국가의 불충분한 입법과 입법 부작위에 대해서도 「헌법재판소법」 제68조와 제75조 제2항 내지 제4항에 따라 헌법소원 또는 입법부작위위헌확인소송과 위헌법률심판제청신청을 통해 권리를 구제받을

47)헌재 1998.2.27. 선고 97헌가10 결정.
48)김철수, 앞의 책, 박영사, 945면.
49)권영성 교수는 추상적 권리설의 입장을 보이다가 최근 불완전한 구체적 권리설의 입장을 취하고 있다. 권영성(2011), 앞의 책, 648-649면.
50)성낙인 교수는 '불완전한 구체적 권리설은 현실적으로는 구체적 권리설과 본질적 차이가 없다고 평가'했다. 성낙인, 앞의 책, 1387면.; 허 영 교수는 '모든 사회적 기본권을 '청구권적 기본권과 동일한 수준의 불완전하나마 구체적인 권리'라고 이해하는 것은 문제가 있다고 지적하며, 청구권적 기본권의 대부분은 소구권이 인정되고 있음'을 적시하고 있다. 허 영, 앞의 책, 542면.
51)이준일, 앞의 논문, 461면.

수 있다는 점을 들어 사회적 기본권을 비롯한 모든 「헌법」상의 기본권은 반드시 실현 되어야할 재판규범임을 증명할 수 있다.

사회적 기본권이 「헌법」상의 기본권 이념으로만 존재하던 당시에는 추상적 권리설과 구체적 권리설에 대한 양분적 논의가 유의미 했을지 몰라도, 현재에 이르러 각종 입법과 정책들이 「헌법」의 기본권 규정의 실천적 규범으로 존재하게 된 만큼 더 이상 추상적 권리설과 구체적 권리설의 논쟁은 사실상 무의미하다고 보인다. 이는 우리 「헌법」이 보장하고 있는 국민의 기본권은 본질적으로 입법방침에 그치는 것일 수 없는 것이고, 만일 단순히 수혜적인 기대권에 불과한 것으로 판단할 경우에는 기본권에 대한 헌법적 함의가 형해화 되어버리는 결과로 귀결될 수 있기 때문이다.[52]

Ⅱ. 노동기본권의 본질과 가치

노동과 관련된 문제는 여느 국가를 불문하고 인간의 생활과는 따로 떼어 놓을 수 없는 필수불가결하고 근본적인 문제이며 시간이 지나고 산업이 발달해갈수록 더욱 다양한 형태로 변모하고 있다. 따라서 이 같은 시간적 흐름 속에 노동기본권의 정립은 현대 산업사회의 핵심적 과제로서 부각되고 있는데,[53] 노동기본권은 노동자들의 역사적 쟁취물인 동시에 노동자들의 사회경제적 지위향상을 통해 자유민주주의의 체제개선에 기여하고 노동자계급의 불만을 보다 합리적이며 제도적으로 해소하여 자유민주주의의 체제내로 동화시키려는 목적을 가진 권리라고 정의해 보기로 한다.[54]

우리가 흔히 말하는 노동이란, 육체노동과 정신노동을 불문하고 인간다움을 실현할 수 있는 가치를 지니고 있는 것으로 더 나아가서는 국가경제발전에 이바지하는 주요한 가치를 담고 있는 것이라 평가할 수 있다. 하지만, 노동력 이외에는 아무런 생활 수단을 가지고 있지 않은 노동자와 생산수단을 소유하고 있는 사용자와의 관계에서 노동자는 본래부터 실질적으로 불리한 지위에 서있을 수밖에 없고, 사용자에

52)허 영, 앞의 책, 542면.
53)성낙인, 앞의 책, 1421면.
54)신인령, 앞의 책, 16-17면.

비해 경제적 · 사회적으로 약자라는 사실이 자본주의가 발전함에 따라 명백해졌다.

따라서 노동자와 사용자는 법률상 대등한 인격체라고 하는 자본주의 사고방식을 배척하는 것이 오히려 타당하며, 노동자는 현실적으로 사용자에게 예속되어 있으므로 양자는 불평등한 관계에 있다는 사실을 전제로 하여 국가가 노사관계에 간섭하고 경제적 · 사회적 강자인 사용자의 계약자유를 제한해 노동자의 지위가 실질적으로 대등해질 수 있도록 해줄 필요가 있다.[55] 그로인해 노동기본권이 요구되기 시작한 것이고 자본과 노동 중 자본 쪽으로 편향돼 치우쳐져 있는 균형점을 자본과 노동의 중앙으로 수정하여 인간의 존엄성과 사회적 약자의 기본적 권리를 보장하고 노동자의 생존을 확보하여 사회적 정의를 구현하는데 노동기본권의 목적이 있는 것이다.

이 같은 사실에 기초해있는 노동기본권은 20세기 초반 이후 노동자들의 인간다운 삶을 보장하기 위한 생존권의 일환으로 정립되기 시작해 1919년에 이르러 바이마르 헌법에서 이를 명문으로 보장하게 되면서부터 노동기본권은 자유권을 능가하는 두터운 법적 보호가 따르게 된 것으로 파악된다.[56] 그 후 노동기본권은 보편적 규범과도 같이 각국의 헌법에 스며들어가게 되었는데 더 나아가 노동기본권을 국제적으로 보호하기 위한 국제노동회의의 필요성이 대두됨에 따라 같은 해 베르사이유 협약에 의해 국제노동기구(ILO)가 창설을 불러온바 있다.

이처럼 노동문제의 해결과 노동가치의 보장을 위한 노동기본권은 고도 산업사회로 진행되어 갈수록 사회적 기본권의 구성요소 중 가장 핵심적인 가치로 평가되고 있으며, 나날이 그 중요성이 부각되어 노동인격을 보호해야 한다는 이념이 국경을 초월하는 보편적 개념으로 자리 잡고 있다. 이러한 세계적 추세와도 같이 우리나라에서도 노동기본권을 「헌법」상의 권리로서 규정하고 있는데, 우리 「헌법」이 보장하고 있는 여러 기본권 중 사회적 기본권에 관련된 사항들은 노동기본권과도 밀접하게 연관 지어져 있다는 점에 있어서도 노동의 가치를 추측해볼 수 있다.

우리나라 노동기본권의 연혁을 돌이켜보면 건국헌법에서 처음으로 헌법상의 권리로 수용된 이래 우리 헌정사와 역사를 같이하고 있음을 알 수 있다. 하지만 헌정사 속에서 노동기본권이 걸어온 길은 순탄치만은 않게 진행되어 온 것이 사실이다. 우

55)홍천용 외(2000), 『시민생활과 법』, 박영사, 222면.
56)이병태(2005), 『노동법』, 중앙경제, 75면.

리의 노동기본권은 때로는 개헌을 통해 직접적으로 제한되기도 하였고, 다시금 제자리를 찾아간 후에도 정권에 따라서, 또는 사안에 따라서 직간접적으로 탄압의 대상이 되기도 했던 역사적 사실이 있으며, 현재에 이르러서도 그 해소가 완벽하게 이루어 졌다고 보기 어렵다. 통상적으로 한 국가의 민주화의 발달 척도는 그 나라에서 노동자들의 여러 권리를 어떻게 보장하고 있는가 하는 정도를 보고 파악하기도 하는데,[57] 이러한 점에 비추어볼 때 우리나라의 민주주의는 여전히 성숙되지 못한 것으로 판단된다. 또한 오늘날에 이르러 다소 개선되었다고는 하지만 현재까지도 자본과 노동의 대립 측면에서 판단해본다면 여전히 자본의 입장에 치우쳐있는 모습에서도 그 흐름을 읽을 수 있다.[58]

우리 사회에서 노동기본권은 '근로기본권', '근로활동권'[59] 등 다양한 용어로 표현되지만 명칭여하에 상관없이 그 내용을 '근로권'(노동의 권리)과 '노동3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권)'으로 풀이하고 있음은 이견이 없다. 우리 「헌법」에서는 노동기본권의 직접 규정으로 제32조 '근로할 권리 · 의무 등'과 제33조 '근로자의 단결권 등'에 걸쳐 규정해두고 보장하고 있다. 이처럼 노동기본권을 「헌법」이 보장하고 있다는 것은 경제적인 국력신장의 밑거름이 될 뿐만 아니라, 우리 「헌법」이 추구하는 사회 정의와 사회의 평화 실현을 위해서도 중요한 선언적 의미를 갖는다. 이러한 점에서 노동기본권은 우리나라의 자유경제질서가 유지되기 위한 중요한 이념적 기초로 평가된다.

하지만 이제는 더 이상 노동기본권을 단순히 '노동의 권리'와 '노동3권'에만 한정하여 평가하는데 그칠 것이 아니라 추가적으로 제14조 '거주 · 이전의 자유'와 제15조 '직업 선택의 자유', 제21조 '집회 · 결사의 자유'와 제23조 '재산권의 보장', 제34조 '인간다운 생활을 할 권리'까지 연관시켜 이해하여야 한다.[60] 그리고 이를 더욱 확장

57)인권법교재발간위원회(2007), 이원희 -「노동과 인권」, 『인권법』, 아카넷, 345면.

58)사법부의 전형적인 계급적 연대라는 점에서 법정은 어떤 경우에도 지배계급 이해관계로 크게 편향되어 있다. 사법부는 평등권과 사회정의에 비해 사적 소유권과 이윤율을 우선해 판결하는 경향이 있다. Harvey David(2007), 『신자유주의(간략한 역사)』, 한울아카데미, 214면,; 조경배(2008), 「신자유주의, 자본권력의 강화와 노동인권의 위기」, 『민주법학』 38권, 민주주의법학연구회, 45면 주)14에서 재인용.

59)허 영 교수는 본인의 저서에서 노동기본권을 '근로활동권'이라는 용어를 사용하여 표현하고 있다. 허 영, 앞의 책, 538면.

60)허 영, 앞의 책, 538-539면.

하여 나아가 제10조 '인간의 존엄과 가치 · 행복추구권', 제11조 '평등권', 제119조 '사회복지국가원리 및 사회적 시장경제질서'까지도 노동기본권에 직간접적으로 관련성을 가지고 있다고 확장시켜야할 필요성이 요구된다고 하겠다.[61]

1. 노동의 권리

1) 노동의 권리의 개념

흔히 '근로권'으로도 대변되기도 하는 우리 「헌법」 제32조[62] 노동의 권리는[63],

---

61)성낙인, 앞의 책, 1422면.

62)「헌법」 제32조 ①모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다.
②모든 국민은 근로의 의무를 진다. 국가는 근로의 의무의 내용과 조건을 민주주의원칙에 따라 법률로 정한다.
③근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다.
④여자의 근로는 특별한 보호를 받으며, 고용·임금 및 근로조건에 있어서 부당한 차별을 받지 아니한다.
⑤연소자의 근로는 특별한 보호를 받는다.
⑥국가유공자·상이군경 및 전몰군경의 유가족은 법률이 정하는 바에 의하여 우선적으로 근로의 기회를 부여받는다.

63)조약 제1006호(관보 제11548호)로서 1990년 7월 10일 우리나라에서도 발효 된 「경제적 사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약」(약칭 : 사회권규약 또는 A규약)에서도 제6조와 제7조에 걸쳐 노동권 및 유리한 근로조건에 관한 권리를 보장하고 있다.
제6조 1. 이 규약의 당사국은, 모든 사람이 자유로이 선택하거나 수락하는 노동에 의하여 생계를 영위할 권리를 포함하는 노동의 권리를 인정하며, 동 권리를 보호하기 위하여 적절한 조치를 취한다.
2. 이 규약의 당사국이 노동권의 완전한 실현을 달성하기 위하여 취하는 제반조치에는 개인에게 기본적인 정치적, 경제적 자유를 보장하는 조건하에서 착실한 경제적, 사회적, 문화적 발전과 생산적인 완전고용을 달성하기 위한 기술 및 직업의 지도, 훈련계획, 정책 및 기술이 포함되어야 한다.
제7조 이 규약의 당사국은 특히 다음 사항이 확보되는 공정하고 유리한 근로조건을 모든 사람이 향유할 권리를 가지는 것을 인정한다.
(a) 모든 노동자에게 최소한 다음의 것을 제공하는 보수
(i) 공정한 임금과 어떠한 종류의 차별도 없는 동등한 가치의 노동에 대한 동등한 보수, 특히 여성에게 대하여는 동등한 노동에 대한 동등한 보수와 함께 남성이 향유하는 것보다 열등하지 아니한 근로조건의 보장
(ii) 이 규약의 규정에 따른 노동자 자신과 그 가족의 품위 있는 생활
(b) 안전하고 건강한 근로조건
(c) 연공서열 및 능력 이외의 다른 고려에 의하지 아니하고, 모든 사람이 자기의 직장에서 적절한 상위직으로 승진할 수 있는 동등한 기회

인간이 생활에서 필요한 기본적 수요를 충족시키기 위한 육체적 · 정신적 활동을 할 수 있는 권리로써, 노동 능력을 가진 자가 일을 하려고 하여도 일할 기회를 가질 수 없을 경우에 일할 기회가 제공되도록 국가의 적극적인 개입과 뒷받침이 요구되는 권리라고[64] 정의 된다. 이 같은 노동의 권리는 그 권리의 내용이 실현될 수 있도록 국가에 대하여 요구할 수 있는 주관적 공권의 측면으로 주로 파악되어 왔으며, 국가는 이러한 국민의 권리에 상응하는 의무를 다하기 위해 다양하고 적극적인 조치를 취해야만 한다.[65]

따라서 노동의 권리는 자유권적 기본권의 성질과 사회권적 기본권의 성질을 아울러 갖는다고 볼 수 있지만 본질적으로는 사회적 기본권성에 기대어 있다고 볼 수 있는 것이다. 이 점에서 우리 헌재는 "근로의 권리는 생활의 기본적인 수요를 충족시킬 수 있는 생활수단을 확보해 주고 나아가 인격의 자유로운 발현과 인간의 존엄성을 보장해 주는 것."[66]이라 판시한 바 있다. 이처럼 '일할 권리'를 내용으로 하고 있는 노동의 권리는 지금까지도 '일할 기회를 제공해달라고 국가에 요구할 수 있는 권리'[67]라는 측면으로만 해석되어지고 있는 것이 일반적이다.

2) 「헌법」의 실현적 기능으로 확장

하지만 4차 산업을 목전에 둔 고도화된 현대 산업사회에서는 과거와 같이 일차원적 시각의 접근으로 노동의 권리를 해결하려는 방식으로는 더 이상 현재 노동환경이 직면해있는 문제들을 풀어나갈 수 없으므로 지양되어야만 한다.

그렇다면 노동의 권리를 「헌법」의 실현적 기능으로서 확장해 보는 것이 필요한데, 일차적으로는 '직장을 구할 수 있도록 국가에게 요구할 수 있는 권리'와 '직장을 구한 이후에 적정한 삶이 유지될 수 있도록 보장해 줄 것을 국가에게 요구할 수 있는 권리'로 구분[68]할 수 있으며, 이는 다시 '일할 자리에 관한 권리'와 '일할 환경에

(d) 휴식, 여가 및 근로시간의 합리적 제한, 공휴일에 대한 보수와 정기적인 유급휴일

64)성낙인, 앞의 책, 1423면.

65)김형배, 앞의 책, 108면.

66)헌재 2007.8.30. 선고 2004헌마670 결정.

67)차병직 · 윤재왕 · 윤지영(2016), 『지금 다시, 헌법』, 로고폴리스, 204면.

관한 권리'로 바꾸어 말할 수 있다.

먼저 '일할 자리에 관한 권리'는 다시 '자유권적인 소극적 권리'와 '생활권적 구체적 권리'로 구분 지어지는데 먼저 구체적인 취업 기회를 박탈당하지 않을 권리는 '자유권적 소극적 권리'라 말할 수 있고, 고용증진을 위한 사회정책 · 노동정책 · 경제정책 · 남녀고용평등정책과 원호대상자의 우선적 일자리 요구권 등은 '생활권적 적극적 권리'라고 각각 표현할 수 있다. 후자인 '일할 환경에 관한 권리'는 합리적인 작업환경의 보장을 요구할 수 있는 생활권적 성질의 구체적 권리로, 합리적 근로조건의 보장을 요구할 수 있는 권리와 일한 대가에 알맞은 적정한 임금의 보장 또는 최저임금제시행을 요구할 수 있는 권리를 내포하고 있다고 판단해야한다.[69] 헌재 역시 이러한 점에 있어서 '일할 자리에 관한 권리'와 '일할 환경에 관한 권리'를 모두 인정하고 있음을 알 수 있으며, 특히 그 중에서도 '일할 환경에 관한 권리'를 인간의 권리로서 자유권적 성격을 강조하고 있는 것을 확인할 수 있다.

> "…근로의 권리가 "일할 자리에 관한 권리"만이 아니라 "일할 환경에 관한 권리"도 함께 내포하고 있는바, 후자는 인간의 존엄성에 대한 침해를 방어하기 위한 자유권적 기본권의 성격도 갖고 있어 건강한 작업환경, 일에 대한 정당한 보수, 합리적인 근로조건의 보장 등을 요구할 수 있는 권리 등을 포함한다고 할 것…"[70]

또한 현행 「헌법」은 모든 노동자에게 합리적인 근로조건을 보장해주기 위해서 합리적 근로조건에 관한 네 가지의 헌법적 기준을 제시하고 있다. 첫째로 인간의 존엄성을 존중하는 근로조건(「헌법」 제32조 제3항), 둘째로 여자노동자를 특별히 보호하며 부당하게 차별하지 않는 근로조건(「헌법」 제32조 제4항), 셋째로 연소노동자를 특별히 보호할 수 있는 근로조건(「헌법」 제32조 제5항과 「근로기준법」 제64조 제1항), 넷째로 민주주의원칙에 어긋나지 않는 근로조건(「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」)등이 그것이다. 민주주의원칙에 어긋나지 않는 근로조건이라 함

68)노호창(2011), 「헌법상 근로권의 내용과 성격에 대한 재해석」, 『노동법 연구』 제30호, 서울대노동법연구회, 158면.
69)허 영, 앞의 책, 543-544면.
70)헌재 2007.8.30. 선고 2004헌마670 결정.

은 노동자의 경영참가, 노사협의기구에서의 노동자의 발언권 존중 등이 실현되어야 함을 뜻한다. 이 같은 네 가지 헌법적 기준은 계약 자유원칙에 따라 근로계약을 체결하는데 있어서 헌법적 한계점으로서의 역할을 한다. 따라서 모든 노동자는 건강한 작업환경의 보장과 합리적 임금 · 근로시간 · 휴일 · 연차유급휴가 · 퇴직금제도 · 재해대책 등이 실현될 수 있도록 보장을 요구할 수 있고, 「헌법」상 이념의 실천적 규범으로서 현행 「근로기준법」에서도 이들 사항을 세부적으로 규정하고 있다.[71]

이러한 노동의 권리에 국가의 의무가 대응됨은 두말할 나위가 없다. 또한 노동의 권리를 '일할 자리에 관한 권리'와 '일할 환경에 관한 권리'로 접근하게 되면 외부노동시장과 내부노동시장을 모두 포섭할 수 있는 장점이 있고, 이때의 노동기본권은 실업자나 구직자에게만 의미가 있는 것이 아닌, 기 취업자들의 고용보장과 유지에도 중요한 의미가 될 수 있다. 또한 국가적으로도 적극적 고용정책에 주목하고 있는 현실에서 '일할 환경에 관한 권리'를 '좋은 환경에서 일할 권리'로 한 차원 더 높여 접근하는 것도 바람직해 보인다.[72]

2. 노동3권

1) 노동3권이 지니고 있는 가치와 한계

노동자에게 임금은 곧 삶의 기반이 되고 노동력은 유일한 생활 수단이자 생존의 수단이다. 하지만 노동자는 사용자에 비해 경제적으로 약한 지위에 서있을 수밖에 없고 이를 그대로 방치할 경우 노동환경은 극히 열악해 질 수 밖에 없는 것이 현실이다.[73] 이러한 문제를 방지하기 위해 우리 「헌법」은 제33조에서 노동3권(단결권 · 단체교섭권 · 단체행동권)을 규정하고 있는데,[74] 이 같은 노동3권은 노동자가 근

71)허 영, 앞의 책, 544-545면.
72)노호창, 앞의 논문, 163면.
73)차병직 · 윤재왕 · 윤지영, 앞의 책, 209면.
74)우리나라는 1948년 건국헌법 이래로 일관되게 노동3권을 헌법 제21조 제1항 국민 일반의 결사의 자유와는 별도로 규정하며 단결권과 단체교섭권, 단체행동권을 병렬적으로 규정하고 있다. 독일의 경우 기본법에서 결사의 자유와는 별도로 '단결의 자유'를 보장하기는 하지만 단결권 외의 노동3권이 병렬

로조건의 유지와 향상을 위해서 자주적으로 단체를 조직하고, 단체의 이름으로 사용자와 교섭을 하며 소기의 목적을 달성하기 위한 방편으로 집단적 행동을 할 수 있는 권리를 말하는 것으로 정리된다.[75] 이는 국가에 대해서는 물론이고 대사인적 관계로서 자본가에 대해서도 직접적으로 적용 되므로, 자본가의 소유권과는 대립관계에 있는 보다 현실적이고 구체적 권리인 것이다.[76]

흔히 노동3권은 '일하는 사람의 기본권'이라 표현되기도 한다. 하지만 일하는 사람의 기본권이라 표현했다고 해서 반드시 현실적 취업자에 한정할 이유는 없고, 일시적 실업 상태에 있는 자와 구직 중인 자 역시 포함하는 것으로 이해하는 것이 합리적이며, 우리 법원도 동일한 입장을 보이고 있다.

> "…'근로자'에는 특정한 사용자에게 고용되어 현실적으로 취업하고 있는 자뿐만 아니라, 일시적으로 실업 상태에 있는 자나 구직중인 자도 노동3권을 보장할 필요성이 있는 한 그 범위에 포함되고…"[77]

우리 「헌법」에 보장되어 있는 노동3권은 제33조 제1항에서 "근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권 · 단체교섭권 및 단체행동권을 가진다."라고 규정하여, '근로조건의 향상'을 위한다는 단서 이외에는 법률이 정하는 바에 따라서 무언가를 유보시킨다거나 별도로 제한한다는 규정도 존재하고 있지 않다. 이는 「헌법」에 규정된 노동3권에 대한 성찰이 가장 기본적으로 삼아질 것이 요구되는 것이다.[78]

또한 이것이 노동자로 하여금 사용자와 대등한 지위에 서서 근로조건을 결정할 수 있도록 하기 위한 것이라는 것은 너무나도 명확한 사실이고, 자유와 평등을 기조로 하는 「헌법」이 실질적 의미에 있어서 자유와 평등을 노동자들에게 확보해주기 위한 기본권이라 풀이할 수 있음은 의심의 여지가 없는 것이다.[79] 이 같은 점에 있어 우리 헌재의 결정례 입장도 이와 크게 다르지 않다.

되어 있지 않으며, 사용자를 포함하여 모든 국민이 단결권을 기본권으로 보장받는 것과는 대조적이라 할 수 있다. 곽노현(2005), 『노동법Ⅱ』,한국방송통신대학교출판부, 4면.

75)허 영, 앞의 책, 547면.

76)강경선 · 서경석 · 이경주, 앞의 책, 303면.

77)대법원 2004.2.27. 선고 2001두8568 판결.

78)「헌법에 보장된 권리 노동3권을 생각하자」, 『시사IN』, 2014. 10. 29., <http://www.sisain.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=21561> 참조.

79)김형배, 앞의 책, 114면.

"…헌법 제33조 제1항은 '근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다.'라고 규정하여 근로자의 근로3권을 보장하고 있다. 헌법이 이와 같이 근로3권을 보장하는 취지는 원칙적으로 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 하는 시장경제의 원리를 경제의 기본질서로 채택하면서, 노동관계 당사자가 상반된 이해관계로 말미암아 계급적 대립·적대의 관계로 나아가지 않고 활동과정에서 서로 기능을 나누어 가진 대등한 교섭주체의 관계로 발전하게 하여 그들로 하여금 때로는 대립 · 항쟁하고, 때로는 교섭·타협의 조정과정을 거쳐 분쟁을 평화적으로 해결하게 함으로써, 결국에 있어서 근로자의 이익과 지위의 향상을 도모하는 사회복지국가 건설의 과제를 달성하고자 함에 있다.…"[80]

한편으로 노동3권은 합리적인 근로조건과 일한 대가에 알맞은 적정 수준의 임금 또는 법이 정한 최저임금의 보장을 요구할 수 있는 '일할 환경에 관한 권리'의 실효성을 보장해주는 수단으로서의 기능도 갖는다. 또, '인간다운 생활'을 보장해주기 위한 제도적 장치로서의 기능을 갖추어 「헌법」이 보장하는 '인간다운 생활 영위권'을 제도적으로 뒷받침 하고 있으며, 경제적 약자인 노동자에게 상대적으로 경제적 강자인 사용자에 대항할 수 있는 「헌법」상의 권리를 실질적으로 보장되게 함으로서 사회평화와 사회정의의 실현에 이바지 한다는 「헌법」상의 의의도 내포하고 있다. 이는 '계약자유의 원칙'과 '재산권 보장'의 역기능적 현상을 방지하고 「헌법」이 추구하는 실질적 평등이 노사관계에서도 실현될 수 있도록 함으로써 사회적인 불평등의 원인이 되지 않도록 순기능적 방향으로 유도하는 역할을 하는 것이다.[81]

"…근로자에 대하여 그러한 두터운 보호를 하는 이유는 자유민주주의 및 자본주의 경제질서에 초래될 수 있는 폐단을 최소화하면서 그 제도를 유지하고 보호하기 위한 것으로서 근로3권의 보장은 자유민주주의를 유지·존속·발전시키기 위한 제도적 장치라는 것을 우선 유념하지 않으면 안되는 것이다.…"[82]

---

80)헌재 1993.3.11. 선고 92헌바33 결정.
81)허 영, 앞의 책, 548면.
82)헌재 1991.7.22. 선고 89헌가106 결정.

이러한 점을 종합하여 볼 때 노동3권 역시 노동의 권리와 마찬가지로 자유권적 기본권의 측면과 사회권적 기본권의 측면을 두루 갖추고 있다고 보는 것이 적합하다.

> "…헌법 제33조 제1항이 보장하는 노동3권의 핵심적인 내용은 자주성과 민주성이며, 그 요체는 단체교섭권에 있고 단체협약은 단체교섭권의 목적이자 결과물로서 결국 노동3권의 목적이다.……근로3권은 국가공권력에 대하여 근로자의 단결권의 방어를 일차적인 목표로 하지만, 근로3권의 보다 큰 헌법적 의미는 근로자단체라는 사회적 반대세력의 창출을 가능하게 함으로써 노사관계의 형성에 있어서 사회적 균형을 이루어 근로조건에 관한 노사간의 실질적인 자치를 보장하려는데 있다. 근로자는 노동조합과 같은 근로자단체의 결성을 통하여 집단으로 사용자에 대항함으로써 사용자와 대등한 세력을 이루어 근로조건의 형성에 영향을 미칠 수 있는 기회를 가지게 되므로 이러한 의미에서 근로3권은 '사회적 보호기능을 담당하는 자유권' 또는 '사회권적 성격을 띤 자유권'이라고 말할 수 있다. 이러한 근로3권의 성격은 국가가 단지 근로자의 단결권을 존중하고 부당한 침해를 하지 아니함으로써 보장되는 자유권적 측면인 국가로부터의 자유뿐이 아니라, 근로자의 권리행사의 실질적 조건을 형성하고 유지해야 할 국가의 적극적인 활동을 필요로 한다. 따라서 근로3권의 사회권적 성격은 입법조치를 통하여 근로자의 헌법적 권리를 보장할 국가의 의무에 있다.…"[83]

하지만 실질적 측면에서 노동3권은 여느 사회적 기본권과 마찬가지로 어떠한 경우에도 제한할 수 없는 절대적 권리가 아니다. 노동3권은 그 자체로서 내재적 한계를 가지고 있는 것이 사실이고 권리의 주체와 업무의 성질과 「헌법」상의 기본원리 등에 의해서 제한될 수 있는 상대적 권리인 것이다. 다만 그러한 경우에도 그 제한은 최소한도에 그쳐야하는 것이 원칙이므로 노동3권을 전면 부인한다는 것은 부정되어야 하며, 본질적 내용의 침해부분에 있어서도 허용되지 않을 것이 전제되어야 한다.

2) 법적 성격의 판단

83)헌재 1998.2.27. 선고 94헌바13 결정.

(1) 단결권

단결권은 노동자가 사용자와 대등한 교섭력을 가질 수 있는 단체를 자주적으로 구성할 수 있는 권리를 말한다. 다시 말하면 노동조합을 조직하고 그에 가입할 수 있는 권리라는 것인데, 단결권이야말로 사회적 법치국가의 본질적 구성요소로 볼 수 있다. 독일의 노동법학자 진츠하이머(H.Sinzheimer)에 따르면 단결권은 공권력은 물론 단결을 공동화하는 그 밖의 경향, 특히 사법상의 의사표시나 법률행위에 의해 타인의 권리를 침해하는 '사회적 권력'으로부터 노동자를 보호한다는 측면으로서 중요한 의미를 갖는 것이고, 이 같은 노동자의 단결권은 노사관계의 차원에서 보장되지 않으면 무의미한 것으로 본다.[84]

우리「헌법」상 단결권은 제21조의 결사의 자유에 대해서도 일부 특별법적 성격을 갖기도 한다. 하지만, 본질적으로 단결권은 사회적 기본권의 특성을 강하게 가지고 있기에 결사의 자유의 일반원리와는 접근을 달리하여야만 한다.[85] 다시 말하면, 노동자의 단결권은 국가가 적극적으로 보호하고 조성해야 할 생존권의 일종으로 보아야 하기에 자유권적 기본권의 일종인 결사의 자유와는 구별되는 것이다.[86] 물론 이 같은 시각으로 본다고 할지라도 단결권이 사회권적 기본권으로서 자유권적 기본권의 성질을 두루 갖추고 있는 기본권이라는 것은 다시 말할 필요가 없다.

단결권의 내용을 풀어보면 일할 환경의 유지와 개선을 실현하기 위한 목적을 가지고 자주적으로 노동조합을 조직하고 운영하며 조합 활동을 할 수 있는 자유와 노동조합의 가입과 탈퇴의 자유, 노동조합과 무관할 수 있는 소극적인 단결권 등을 내용으로 하고 있음을 알 수 있다. 또 이러한 단결권은 대국가적 효력과 대사인적 효력을 동시에 가지고 있으므로 침해 시 보다 적극적으로 구제받을 수 있는 권리이다.

대국가적 효력은 국가권력으로부터 단결권에 대한 직접적인 간섭배제와 노동자의 단결권 행사를 사용자가 부당노동행위로서 제한할 경우에 국가가 나서서 그 방해를 배제하여줄 간접적 의무를 말한다. 이를 국가가 이행하지 않을 경우 부작위에 따라

84)강경선 · 서경석 · 이경주, 앞의 책, 305면.
85)성낙인, 앞의 책, 1433면.
86)김철수, 앞의 책, 박영사, 1011면.

단결권이 침해된 것으로 보아 위헌의 책임과 위법이며, 불법행위를 구성할 경우에는 형사책임과 손해배상책임을 면할 수 없다. 반면 사용자가 단결권을 침해하는 경우에는 부당노동행위에 해당하지만 그 침해 행위가 당연무효로 되는 것은 아니다. 사용자로부터의 침해를 구제받기 위한 노동자의 구제신청 내지 행정소송이 있는 경우에 한해서 노동위원회나 법원이 「헌법」의 규정을 기초로 삼아 사안판단을 판단하게 된다는 수동적 측면이 존재한다. 또 이러한 경우에도 노동위원회나 법원으로부터 구제명령 또는 판결을 내려질 때야 비로소 무효가 성립하게 되므로 대국가적 효력에 비해 대사인적 효력의 측면에서는 간접적 효력의 측면이 보다 강한 것으로 구분된다.[87] 이 같은 단결권은 그 존재 자체만으로는 무의미하다. 단결권의 존재 의의는 단결된 힘을 바탕으로 단체교섭을 전개함으로서 노동자의 근로조건을 개선하고 노동자의 경제적 · 사회적 지위를 실질적으로 향상시키는데 있기 때문이다.[88]

(2) 단체교섭권

단체교섭권이란 노동자가 일할 환경의 유지와 개선을 위해서 노동자 단체의 이름으로 사용자 또는 사용자 단체와 자주적 교섭을 할 수 있는 권리를 말한다.[89] 이러한 단체교섭권은 「헌법」에서 보장된 권리로서 노동자의 일할 환경의 유지와 개선을 교섭 대상으로 한다는 점에서, 노사 간 기업 내 공동이행사항을 협의하여 노동자의 복지 증진과 기업의 건전한 발전을 목적으로 하는 노사협의 제도와는 구별되고, 노동자의 생존권을 보장하는데 목적이 있다는데서 다른 거래와도 구별된다.[90]

그렇다고 단체교섭의 교섭 범위를 반드시 일할 환경의 유지와 개선에만 한정하여 볼 이유는 없다. 사안이 노동자들의 경제적 내지 사회적 지위의 향상에 관한 것으로서 사용자와 교섭이 가능한 사항이라면 원칙적으로는 교섭 범위 안에 들어와 있는 것으로 보아야 하고,[91] 이 같은 측면에서 단체교섭권은 노동자 단체의 중요한 활동

87)허 영, 앞의 책, 554-555면.
88)홍천용 외, 앞의 책, 236면.
89)허 영, 앞의 책, 555면.
90)이병태, 앞의 책, 85면.
91)김형배, 앞의 책, 150면.

의 자유에 속하는 것으로 이해된다.[92] 이러한 단체교섭권은 단체협약의 체결이 따르지 않는다면 사실상 가치를 상실할 수밖에 없기에 사실행위인 교섭행위 뿐 아니라 자주적 교섭을 통한 결과로 합의된 사항을 단체협약으로 체결할 권리 역시 당연히 내포하고 있다고 보아야한다는 점에 있어서는 이견이 없다.

그러나 단체교섭 사항의 대상으로 경영 · 인사에 관한 사항을 포섭하여 인정할 수 있느냐 하는 부분에 있어서는 논란이 있다. 이제까지는 경영 · 인사에 해당하는 사항일지라도 노동자의 노동조건이나 지위에 직접 관련되거나 그에 중대한 영향을 미치는 사항이라면 그 한도 안에서 단체교섭의 대상으로 이해되는 것이 일반적이었다.

> "…기업의 운영에 관한 관리와 경영 및 인사에 관한 사항은 사용자에게 그 결정권이 있으므로, 기업의 경영 및 인사에 관여하는 노동조합의 활동은 원칙적으로 정당한 조합 활동의 범위를 일탈한 것이라 할 것임. 그러나 기업의 경영과 인사에 관한 사항일지라도 근로자들의 근로조건이나 지위에 직접적으로 관련되거나 중대한 영향을 미치는 경우에는 그 한도 내에서 이에 관하여 사용자와 노동조합 사이에 단체교섭이나 합의가 이루어 질 수 있고, 사용자가 이러한 합의를 하였음에도 이를 제대로 이행하지 않는 경우에 위 합의사항의 이행을 요구하는 것은 부당한 경영권 및 인사권 침해라고 할 수는 없다.…"[93]

하지만, 최근 대법원은 판결문에서 기업의 경쟁력 강화를 들어 노동3권을 퇴보시키는 입장을 견지하고 있다.

> "…오늘의 우리나라가 처하고 있는 경제현실과 오늘의 우리나라 노동쟁의의 현장에서 드러나는 여러 가지 문제점 등을 참작하면, 구조조정이나 합병 등 기업의 경쟁력을 강화하기 위한 경영주체의 경영상 조치에 대하여는 원칙적으로 노동쟁의의 대상이 될 수 없다고 해석하여 기업의 경쟁력 강화를 촉진시키는 것이 옳다. 물론 이렇게 해석할 경우 우선은 그 기업에 소속된 근로자들의 노동3권이 제한되는 것은 사실이나 이는 과도기적인 현상에 불과하고, 기업이 경쟁력을 회복

---

92)허 영, 앞의 책, 555면.

93)서울민사지방법원 1991.9.12. 선고 90가합5721 판결.; 같은 취지의 판결로는 대법원 1992.5.12. 선고 91다34523 판결.; 1994.8.23. 선고 93누21514 판결 참조.

하고 투자가 일어나면 더 많은 고용이 창출되고 근로자의 지위가 향상될 수 있으므로 거시적으로 보면 이러한 해석이 오히려 전체 근로자들에게 이익이 되고 국가경제를 발전시키는 길이 된다.……또한 근로자참여및협력증진에관한법률은 경영사항을 포함한 광범위한 영역에서 노·사가 협의하도록 제도화하고 있다. 이러한 사정을 종합하여 보면 위와 같은 해석이 결코 노동3권의 본질적인 내용을 침해하거나 헌법 및 노동관계법의 체계에 반하는 해석이라 할 수 없다.…"[94][95]

이 같은 판결의 내용을 전적으로 부정하는 것은 아니지만, 쉽게 수긍하기 어려운 점이 있다. 노동자는 사용자에 비해 현저히 불리한 지위에 있는 것이 사실이고 이를 보완하기 위한 방법의 궁리로 노동기본권의 보장이 시작된 점을 돌이켜볼 때 아쉬움이 남는 판결이다. 법원은 경영권을 인정해 상대적으로 노동3권을 제한 할 것이 아니라 기업의 유지와 나란한 위치에서 그 기업에 소속된 전체 노동자가 가진 최소한의 생존권도 같이 고려했어야만 한다.[96] 물론 투자자의 이윤취득권에 속하는 사항 등은 원칙적으로 교섭대상이 될 수 없는 점에 있어서는[97] 공감하지만, 고전적으로 경영권의 범위에 속한다고 일컬어져 온 사항들이라 할지라도 그것이 노동자의 근로조건과 생활조건에 영향을 주는 것이라면 넓은 의미에서 근로조건 가운데 포괄되는 것으로 보아야 한다.[98] 또 이처럼 경영권으로 불리는 것과 노동자들의 근로조건과는 겹쳐지는 면이 많이 있어 한쪽에서 보면 경영자의 전권사항으로 이해되는 것도 다른 한쪽에서 본다면 근로조건으로 판단되는 사례도 적지 않기에,[99] 인간의 창의적 노동력과 자본 그리고 시설이 유기적인 결합을 통해 성립되는 인사 · 경영에 관한 사항이 사용자에게만 독점적이고 전속적인 권리로 주어지는 것은 아니라고 판단된다.[100]

---

94)대법원 2003.7.22. 선고 2002도7225 판결. 같은 취지의 판결로는 대법원 2003.11.13. 선고 2003도687 판결 참조.

95)이 같은 판결은 대법원이 "「헌법」뿐만 아니라 법률 조항 어디에도 없는 '경영권'을 「헌법」적 지위로 높이고 노동기본권의 가치를 깎아내렸다"는 비난의 대상이 된다. 조경배(2012), 「국제 노동기준에 비춰본 한국 노동자의 노동기본권 보장 실태」, "[국제 정책 세미나] 국제기준에 비춰 본 한국의 노동기본권과 ILO 협약 비준 확대 방안", 30면.

96)이병태, 앞의 책, 240면.

97)임종률(2017), 『노동법』, 박영사, 28면.

98)노동부의 질의 회시기록(근로기준정책과-314, 2015.2.12.)도 인사 · 경영권은 근로조건 또는 복무규율에 포함되지는 않지만 그 행사로 인해 임금저하 등 근로조건에 직접적인 영향을 미치면 취업규칙에 포함될 수 있다는 견해를 표시한다. 하갑래(2017), 『근로기준법』, 중앙경제, 143면. 주1) 참조.

99)신인령, 앞의 책, 97면.

만일 경영권을 재산권의 개념으로 접근한다 치더라도 「헌법」 제23조 제2항에서 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 제한하고 있음에 반해 노동기본권의 행사는 그 자체가 공공복리에 합치되는 것으로 구분되어 지는 것이므로 재산권으로도 제한할 수 없는 대상이 된다.

> "…근로자들이 헌법상 보장된 단결권에 기하여 자유로이 노동조합을 조직하거나 이에 가입하고 노동조합을 통한 자주적인 노사교섭을 바탕으로 노사의 실질적인 평등을 향하여 나아감은 현대의 노동법이 구현하고자 하는 최고의 공익적 가치라고 보아야 하고 그 자체가 공공의 복리에 합치되는 것이므로 일시적인 행정편의에 의하여 이를 희생하거나 제한할 수 없으며…"[101]

또한 경영권은 실정법상의 권리가 아니기에[102] 「헌법」 제33조에서 정한 노동기본권의 행사에 경영권에 따른 제한이 인정되지 않고 있으며, 경영권의 핵심이 되는 인사권은 근로계약에 근거를 두고 있는 것으로 근로계약에 반할 수 없는 것이다. 나아가 오늘날 노사관계는 '참가와 협조'의 시대를 맞아 노동자의 경영참가가 일반화되어가는 양상을 보이고 있다.[103] 이 같은 점을 종합하여 볼 때 사용자의 경영권이 더 이상 단체교섭의 대상이 될 수 없는 특별한 권리의 영역으로서 보장되어 있는 것이라 보기는 힘들다. 오히려 「헌법」상의 사용자 재산권 보장과 노동자의 노동3권 보장은 상호간에 서로 균형을 이루며 사회전체적인 체계가 보다 합목적적으로 규율되기를 기대하는 것으로 보는 것이 타당하다.[104] 따라서 종래의 입장과도 같이 근로조건에 직접 관련되거나 중대한 영향을 미치는 경우에는 여전히 교섭대상으로 인식하는 것이 보다 합리적이다.

---

100)이희성(2007), 「사용자의 경영권과 근로자의 노동3권의 충돌에 관한 연구」, 『산업관계연구』 제17권 제1호, 한국고용노사관계학회, 132면.

101)서울고등법원 1991.5.30. 선고 90구587 판결.

102)"경영권은 법률상의 용어가 아니고 사회적 관용어에 지나지 않는다.", 이병태, 앞의 책, 239면.; "이른바 경영권 · 인사권이란 사용자가 기업 내에서 사실상 행사하는 권능으로서 일종의 기업용어일 뿐 법적권리로서의 효력(물권적 · 청구권적 · 형성권적 효력 중 어느 것도)은 인정되지 않으며…", 신인령, 앞의 책, 102면.

103)이병태, 앞의 책, 240면.

104)이희성, 앞의 논문, 132면.

(3) 단체행동권

단체행동권은 노동자의 일할 환경의 유지 · 개선을 관철시킬 목적으로 집단적으로 행동을 함으로서 업무의 정상적 운영을 저해할 수 있는 권리라고 정의된다.[105]

단체행동권을 인정한다는 것은 노동자들이 사실적인 실력행사를 통해 경제적 지위를 실질적으로 향상 시키는 것을 제도적으로 보장하는 것이며, 사용자와 노동자들이 상호 이해관계의 대립 상태로 들어간 노동쟁의 상태를 쟁의행위에 의해 해결하도록 하는 것이다.[106] 여기서 말하는 노동쟁의란 "노동조합과 사용자 또는 사용자단체간에 임금 · 근로시간 · 복지 · 해고 기타 대우 등 근로조건의 결정에 관한 주장의 불일치로 인하여 발생한 분쟁상태를 말한다. 이 경우 주장의 불일치라 함은 당사자 간에 합의를 위한 노력을 계속하여도 더 이상 자주적 교섭에 의한 합의의 여지가 없는 경우를 말하며,"(「노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제5호) 쟁의행위라 함은 "파업 · 태업 · 직장폐쇄 기타 노동관계 당사자가 그 주장을 관철할 목적으로 행하는 행위와 이에 대항하는 행위로서 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위"(「노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제6호)를 말한다. 또, 사용자는 단체교섭 또는 쟁의행위로 인하여 손해를 입은 경우에 노동조합 또는 노동자에 대하여 그 배상을 청구할 수 없고(「노동조합 및 노동관계조정법」 제3조), 이를 수인해야할 의무가 있다. 다만 그러한 수인의무는 절대적인 것은 아니며 노동자의 쟁의 행위가 정당성을 벗어나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.

> "…쟁의행위는 근로자가 소극적으로 노무제공을 거부하거나 정지하는 행위만이 아니라 적극적으로 그 주장을 관철하기 위하여 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위까지 포함하므로, 쟁의행위의 본질상 사용자의 정상업무가 저해되는 경우가 있음은 부득이한 것으로서 사용자는 이를 수인할 의무가 있으나, 이러한 근로자의 쟁의행위가 정당성의 한계를 벗어날 때에는 근로자는 업무방해죄 등 형사상 책임을 면할 수 없다. 쟁의행위의 형사상 책임이 면제되는 정당성의 요건은 쟁의

105)허 영, 앞의 책, 556면.
106)김형배, 앞의 책, 153면.

행위가 단체교섭과 관련하여 근로조건의 유지·개선 등을 목적으로 하는 것이어서 그 목적이 정당하여야 하고, 쟁의행위의 시기와 절차가 법령의 규정에 따른 것으로서 정당하여야 하며, 또 쟁의행위의 방법과 태양이 폭력 또는 파괴행위를 수반하거나 기타 고도의 반사회성을 띈 행위가 아닌 정당한 범위 내의 것이어야 한다.…"[107]

이 같은 쟁의권으로서의 개념 이외에도 단체행동권은 '조합활동권'으로도 이해된다.[108] 조합활동권은 일상적인 조직선전 활동을 말하는 것으로 조합원에 대한 교육 · 홍보 활동, 임원 선출, 조합비 징수 등과 같은 활동과 사용자가 제공한 조합사무실과 게시판과 같은 시설물의 이용, 쟁의행위 중 또는 쟁의 상태에서 홍보물의 부착과 배포, 리본 완장착용과 집회개최, 연설 등과 같은 활동을 포함하는 것으로 보는 것이 일반적이다.[109] 하지만 조합활동권을 근거로 하는 노동조합의 활동은 취업규칙이나 단체협약에 별도의 허용규정이 있거나 관행 또는 사용자의 승낙이 있는 경우 외에는 근무시간 외에 행하여져야 한다. 또 이러한 경우에도 사업장의 전면적, 배타적 점거는 허용되지 않고 그 활동에 필요한 최소한의 범위 내에서 사업장 일부를 점거, 이용하는데 그쳐야 그 행위의 정당성을 확보할 수 있다.[110] 한편, 사용자는 이러한 정당한 단체행위에 참가하였음을 이유로 하여 노동자를 해고한다거나 그 밖의 불이익한 제한을 하지 못한다는 측면에서 단체행동권의 헌법적 보호는 재산권에 대한 노동3권의 우월성을 상대적으로 인정한 것이라 하겠다.[111]

제3절 소결

근대 시민법 국가에서 나타났던 자유주의적 정치사상과 자유방임주의적 경제사상은 국가권력의 간섭을 배제하는 소위 국가의 소극적 역할을 그 덕목으로 삼고 있던

107)대법원 1992.9.22. 선고 92도1855 판결.
108)대법원 1990.5.15. 선고 90도357 판결.
109)이병태, 앞의 책, 87면.
110)대법원 1993.9.28. 선고 91다30620 판결.
111)권영성, 앞의 책, 693면.

덕분에 자유시장경제가 발달하며 민주주의와 자본주의가 눈부시게 발달 할 수 있었다는 긍정적 측면도 분명히 존재한다. 하지만 그렇다고 그 이면에서 찾아왔던 자본주의적 경제체제의 모순으로 인해 노동자들이 극심한 빈곤과 실업으로 고통을 받기도 했던 부분을 무시할 수는 없다. 따라서 현재의 현대적 기본권 시대는 근대적 기본권 시대의 반성과 궁리로 시작되었다는 것을 잊지 말아야 한다. 현대적 기본권 시대는 보다 적극적인 국가의 개입이 요구되고 있으며 사회복지국가의 원리가 녹아있는 사회적 기본권이 대두됨에 따라 국가를 구성하고 있는 개개인으로서의 국민은 국가권력으로부터 보호를 받아야할 대상이라 인식되고 있다.

이 같은 점에서 사회적 기본권은 국민의 적극적 지위를 보장하는 권리라는 것을 쉽게 간과해서는 안되며, 사회적 기본권에 대한 가치 보호의 필요성 역시 보다 절대적으로 인식해야 한다. 만일 이 같은 사회적 기본권의 이념적 가치를 망각할 경우 「헌법」이 보장하고 있는 사회적 기본권의 형해화를 불러와 실질적으로는 자유권 시대로 회귀되어 지난날의 과오를 반복하게 될 가능성이 충분하다. 물론, 이러한 경우에도 자유권과 사회적 기본권을 이원론적 사고로 차별하여 이해할 것을 요구하는 것은 아니며 사회복지헌법의 원리에 따라 자유와 평등의 실질적 보장이라는 측면에서[112] 이해하는 것이 보다 합리적이다.

오늘 날 「헌법」상 기본권 규정의 보호대상이 되는 법익은 반드시 국가에 의해서만 침해되는 것은 아니다. 인간의 존엄과 가치가 보호하려는 인격체로서의 인간존재는 국가만이 침해할 수 있는 대상의 것이 아니라 사인 간에, 특히 사실상 압도적인 힘의 우위에 있는 사인에 의해서도 침해될 가능성이 충분하다. 따라서 「헌법」상의 기본권 규정을 통해 사인 상호간의 관계를 규율할 필요성이 대두된다.[113] 이러한 점에 있어 기본권 중에서는 사회적 기본권이, 사회적 기본권 중에서는 노동기본권이 가장 유의미하다. 노동기본권이 보장하고자 하는 '노동의 권리'와 '노동3권'은 서로 불가분의 영역에 서있는 것으로 봐야한다. 이는 '노동의 권리'가 추구하는 노동자의 '일할 자리에 관한 권리'와 '일할 환경에 관한 권리'는 '노동3권'이 있기에 더욱 빛을 발휘할 수 있으며, '노동3권'은 그러한 '노동의 권리'가 있으므로 그 존재의 의미와

112)성낙인, 앞의 책, 1391면.
113)강경선 · 서경석 · 이경주, 앞의 책, 305면.

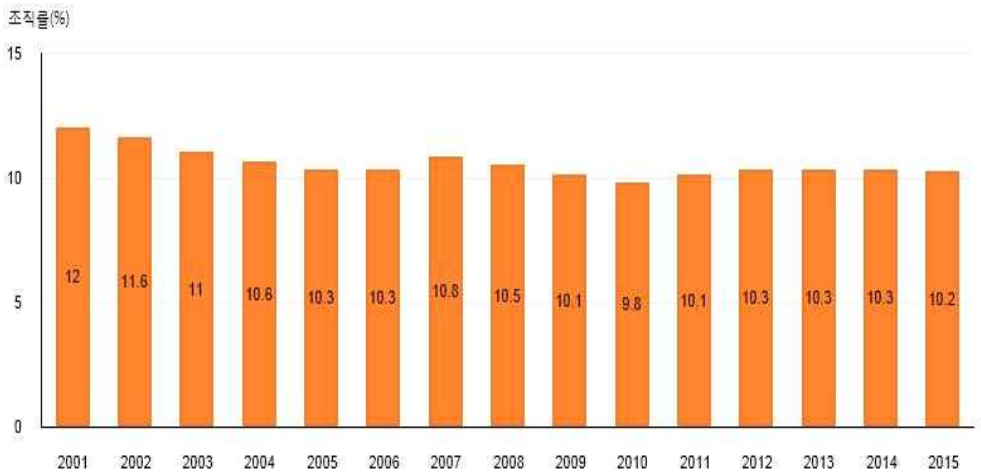
가치가 부여되기 때문이다.

하지만 현재 우리나라에서는 노동기본권에 대한 왜곡된 인식으로 노동자의 단결체가 핍박과 억압의 대상이 되기도 하고 때로는 외면의 대상으로 치부되고 있는 것이 이 시대의 현실이다. 또 그러한 노동자 단결체의 활동을 보장하고 있는 「노동조합 및 노동관계조정법」 마저 대다수의 규정이 노동자들의 단결체를 보호하려는 점보다 한계를 부여하려는데 중점을 두고 있다는 문제를 지니고 있다. 따라서 이럴 때 일수록 사회적 기본권의 배경이 담고 있는 이념을 종합적으로 판단해 노동기본권에 대해 개선된 인식을 가져야 한다. 또 그로부터 더 나아가 노동기본권을 보다 인간다운 삶을 실질적으로 보장 받을 수 있게 하는 권리로 보아 반드시 지켜내야 할 가치가 충분한 것으로 바라보아야 할 필요가 있다.

제3장 헌법적 이념에 기초한 취업규칙제도

제1절 노동기본권과 취업규칙의 상관관계

취업규칙은 노동조합이 조직되어 있지 않은 사업장이나 노동조합이 조직되어 있다 할지라도 그 노동조합에 가입되어 있는 조합원의 수가 노동자 과반수가 되지 않는다면 해당 사업 또는 사업장에서 노동자를 상대로 실질적인 영향력을 갖추게 된다. 우리나라 산업현장의 노동조합 조직률 추이를 확인해 보면 최근 10년여의 기간 동안 노동조합 조직률이 10%선에 머무르고 있는 것을 알 수 있다. 그것은 다시 말하면 90%대에 가까운 노동조합이 조직되지 않은 사업 또는 사업장에서 취업규칙이 가지고 있는 보편적인 구속력을 가늠해볼 수 있는 방증의 자료가 된다.



<그림 2> 노동조합 조직률 변화 추이

출처 : e-나라지표 참조. <http://www.index.go.kr>

또한 평균적으로 노동조합 조직률이 10%선 이라고 할지라도 현실적으로 그 노동조합이 무조건 사업장의 과반수로 구성되어 있는 노동조합일 것이라 예측할 수는 없다는 점에 주목하여 볼 때, 사실상 대다수 사업 또는 사업장에서 취업규칙이 절대적인 영향력을 가지고 있을 것이라는 점 역시 그리 어렵지 않게 예상해 볼 수 있다.

따라서 취업규칙은 현실적 노사관계에서 지대한 역할을 하게 되는 바 취업규칙의 불이익한 변경에 대한 요건의 완화는 더욱 신중한 접근을 하여야 한다. 만일 섣부르게 취업규칙의 불이익한 변경 요건이 완화될 경우 근로조건의 노사대등결정원칙의 근간이 훼손되게 됨은 물론이고 사용자 일방이 일방적으로 취업규칙의 불이익한 변경을 가해 근로조건과 노동환경을 직접적으로 저하시키는 것[114] 역시 어렵지 않게 할 수 있게 될 것이다. 이는 궁극적으로 '합리적인 근로조건의 보장을 요구할 수 있는 권리'와 일한 대가에 알맞은 적정한 임금의 보장 등에 대한 권리인 '일할 환경에 관한 권리' 측면으로서의 노동기본권이 침해될 수 있는 문제로 경각심을 가져야할 필요성이 부각된다. 우리는 앞서 노동기본권이 산업혁명 이후 직면한 자본주의경제체제의 모순과 사회적 갈등의 심화 등으로 나타나게 된 일련의 사회현상들을 수정하고 반성적으로 극복해내기 위한 궁리 끝에 도출된 사회적 기본권의[115] 일환으로서 노동인권을 실질적으로 보장하기 위한 「헌법」적 권리라는 점을 이미 확인할 수 있었다. 이러한 부분에 있어 노동기본권에 취업규칙이 연관 지어지는 것이다.

또 취업규칙 제도를 규율하고 있는 측면에서 접근해 보아도 「근로기준법」이 노동기본권 등 우리 「헌법」이 담고 있는 노동자 보호이념을 현실적으로 실현하기 위한 응답으로,[116] 그 요건들을 규율해 제도적으로 갖추고 있다는 것은 명확한 사실이다. 따라서 취업규칙과 관련 된 조항 역시 그 요건들 중의 하나라는 점에서 궁극적으로 취업규칙 역시 「헌법」상의 노동기본권을 실현하기 위한 「근로기준법」의 제도적 산물로[117] 이해할 수 있다.

이는 우리나라에서 최초로 취업규칙에 대해서 판례의 법리를 정립한 것으로 평가되는[118] '대법원 1977.7.26. 선고 77다355 판결'에서도 확인되고 있다. 법원은 취업규칙의 변경에 의해 종전의 근로조건 내용을 일방적으로 노동자에게 불리하게 변경하

114)최은실(2015), 「취업규칙 불이익 변경요건과 노동자 대표성 문제」, "노동시장 구조개혁 및 비정규직 종합대책(안)에 대한 법률단체 토론회", 23면.

115)최규환(2014), 「사회적 기본권의 사법심사 가능성」, 박사학위논문, 고려대학교, 24면.

116)「근로기준법」은 제1조 목적에서 "이 법은 헌법에 따라 근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 한다."고 규정하여 「헌법」 제32조에 따른 노동기본권 보장의 부름에 대한 응답 입법임을 명시하고 있다.

117)이병태, 앞의 책, 1025면.

118)정진경, 「근로조건의 불이익변경 - 취업규칙과 단체협약에 의한 근로조건의 불이익변경에 관한 대법원판례를 중심으로」, 『노동법연구』 제13호, 서울대 노동법 연구회, 30면.

려면 변경대상이 되는 종전 취업규칙의 적용을 이미 받고 있던 노동자 집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 필요로 하고, 만일 이와 같은 동의가 없을 때에는 동의 없이 이루어진 취업규칙의 불이익한 변경의 효력이 무효가 됨은 물론이거니와 그러한 취업규칙의 변경에 대해 동의를 했던 노동자들에 대해서도 변경된 취업규칙은 일체의 효력을 발할 수 없다고 판시하였는데, 그 근거로 「근로기준법」이 보호법으로서의 정신과 기득권 보호의 원칙, 근로조건은 노동자와 사용자가 동등한 지위에 서서 자유의사에 의해 결정되어야 한다는 「근로기준법」의 노사대등결정의 원칙을 들었다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.

"…취업규칙은 사용자가 기업경영권에 기하여 사업장에 있어서의 근로자의 복무규율이나 근로 조건의 기준을 획일적 통일적으로 정립하기 위하여 작성하는 것으로서 이는 근로기준법이 종속적 노동관계의 현실에 입각하여 실질적으로 불평등한 근로자의 입장을 보호강화하여 그들의 기본적 생활을 보호향상시키려는 목적의 일환으로 그 작성을 강제하고 이에 법규범성을 부여한 것이라고 볼 것이므로……과반수의 동의가 없는 한 취업규칙의 변경으로서의 효력을 가질 수 없고 따라서 그러한 취업규칙변경에 대하여 개인적으로 동의한 근로자에 대하여도 효력이 없는 것이라고 할 것이다. 왜냐하면 기존근로조건의 내용을 사용자가 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하는 것은 위의 근로기준법의 보호법으로서의 정신과 기득권 보호의 원칙 및 근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 의하여 결정되어야 한다는 근로기준법 제3조의 규정상 허용될 수 없다 할 것이고,……근로자는 단체로써 행동할 때 실질적으로 사용자와 대등한 입장에 서게 된다는 것이 모든 노사관계법의 기본입장이므로…"[119]

하지만 이 같은 취지의 판결은 이후 전원합의체 판결에서 판례가 변경되며 그 의미가 퇴색된바 있다. 법원은 전원합의체 판결에서 기존의 입장을 바꾸어 취업규칙의 작성과 변경의 권한은 원칙적으로 사용자에게 있어 사용자가 그 의사에 따라 취업규칙을 작성하거나 변경할 수 있고, 사용자가 취업규칙을 변경한 경우 취업규칙의 변경이 기존의 노동자에게 불리한지의 여부를 불문하고 취업규칙의 변경은 유효하다고

119)대법원 1977.7.26. 선고 77다355 판결.

판시하며 입장을 바꾸었으며, 안타깝게도 이는 현재까지도 입장의 변화 없이 판례에서 답습되며 이어지고 있다.

"…취업규칙의 작성·변경에 관한 권한은 원칙적으로 사용자에게 있으므로 사용자는 그 의사에 따라 취업규칙을 작성·변경할 수 있으나, 다만 근로기준법 제95조의 규정에 의하여 노동조합 또는 근로자 과반수의 의견을 들어야 하고 특히 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 동의를 얻어야 하는 제약을 받는바, 기존의 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에 필요한 근로자의 동의는 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의임을 요하고 이러한 동의를 얻지 못한 취업규칙의 변경은 효력이 없다 는 것이 당원의 일관된 견해……사용자가 취업규칙에서 정한 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경함에 있어서 근로자의 동의를 얻지 않은 경우에 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 그 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지 되지만, 그 변경 후에 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하고 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 하고, 기득이익의 침해라는 효력배제사유가 없는 변경 후의 취업근로자에 대해서까지 그 변경의 효력을 부인하여 종전 취업규칙이 적용되어야 한다고 볼 근거가 없다. 위와 같은 경우에 취업규칙변경 후에 취업한 근로자에게 적용되는 취업규칙과 기존근로자에게 적용되는 취업규칙이 병존하는 것처럼 보이지만, 현행의 법규적 효력을 가진 취업규칙은 변경된 취업규칙이고 다만 기존근로자에 대한 관계에서 기득이익침해로 그 효력이 미치지 않는 범위 내에서 종전 취업규칙이 적용될 뿐이므로, 하나의 사업 내에 둘 이상의 취업규칙을 둔 것과 같이 볼 수는 없다.…"[120]

이처럼 입장을 변경한 전원합의체의 판결은 당초 '대법원 1977.7.26. 선고 77다355 판결'이 제시했던 세 가지 근거 중 기득권 보호의 원칙만을 유지하고 「근로기준법」의 보호법으로서의 정신과 집단적 결정에 의한 근로조건의 노사대등결정의 원칙이라는 대원칙을 방기한 측면이 있다. 이는 노동자 보호법인 「근로기준법」상의 조

120)대법원 1992.12.22. 선고 91다45165 판결.

항을 근거로 하여 사용자의 의사를 넘어서까지 사용자이익에 대한 배려를 행한 것이라고 평가 된다. 또 신규 노동자에게는 제시된 취업규칙에 대한 부동의의 표명이 사실상 고용의 기회를 상실하는 것을 의미한다는 현실을 무시한 것이고, 취업규칙을 통한 근로조건의 통일적이고 획일적인 처리라는 요청을 간과하였다는 점에 있어서 취업규칙의 법규성에도 반하는 것이며 기존의 판례이론과도 조화되기 어려운 것이라는 비난의 대상이 되고 있다.[121]

사실상 취업규칙은 사용자가 일방적으로 사업이나 사업장에 적용할 복무규율과 근로조건을 정하여둔 문서이기에 그 자체로만 놓고 본다면 본질적으로는 노동자를 보호하고자 하는 제도로만 평가하기는 어렵다는 측면이 존재한다. 따라서 그러한 점을 근거로 하여 취업규칙을 근로조건의 노사대등결정 원칙에 정면으로 반하는 제도라고 보는 비판도 있는 것도 사실이다.

그러나 이 같은 논점은 취업규칙이 최초 작성될 당시에 한정하여 볼 문제이다. 일단 취업규칙이 해당 사업 또는 사업장에서 구속력을 인정받게 되면 노동자뿐 아니라 사용자까지도 그러한 취업규칙의 내용에 구속되는 바 일정부분에서는 사용자로부터 노동자를 보호하는 역할도 기대할 수 있다. 또한 불이익한 변경을 진행할 시에는 동의를 얻도록 규정하고 있어 실질적으로는 소극적 측면에서나마 여전히 근로조건의 노사대등결정 원칙도 내포하고 있다고 본다. 더 나아가서는 노동자에게 합리적인 근로조건을 보장해주기 위한 「헌법」적 함의로서 노동기본권 측면에서의 '일할 환경에 관한 권리'를 보장하려는데 그 목적이 있다는 점에서도 노동기본권과 「근로기준법」상의 취업규칙 관련 조항들의 연관성은 충분히 설명된다.

또 다른 측면으로 「헌법」이 제33조에서 규정하고 있는 노동3권의 측면에서 접근하여 보더라도 「헌법」상 노동기본권의 실천적 법규범인 「근로기준법」이 제94조 제1항에서 노동자 과반수로 구성된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합이 취업규칙의 불이익한 변경에 대한 동의권을 가지게 된다는 것을 명시해 규율하고 있으므로

121)이 준(1996), 「취업규칙의 불이익한 변경과 변경 후에 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 효력」, 『민사판례연구』 XⅦ, 박영사, 344-347면.; 오창수(1994), 「취업규칙의 불이익변경」, 『판례연구』 (7), 서울지방변호사회, 205-207면,; 이철수(1993), 「취업규칙에 대한 판례법리와 문제점」, 『사법행정』 통권392호, 한국사법행정학회, 22-23면,; 정진경, 앞의 책, 31면에서 재인용.; 최영호(1993), 「취업규칙의 불이익변경」, 『노동법연구』 제3호, 서울대학교 노동법연구회, 169-170면.

그러한 노동조합과의 동의절차를 위반한 취업규칙의 불이익한 변경 역시 궁극적으로는 노동기본권을 침해하게 되는 것이다. 따라서 이러한 사실들에 기초해 볼 때 취업규칙 제도를 노동기본권에 기대어 점검해볼 필요성이 요구된다.

제2절 취업규칙의 의의와 효력

Ⅰ. 취업규칙의 개념

본래 취업규칙은 사용자가 사업 또는 사업장에 다수의 노동자를 사용하고 있는 경우에 직장의 질서를 유지할 목적으로 노동자가 지켜야할 복무규율과 이를 위반한 자에 대한 제재를 규율하기 위한 필요에 의해서 생겨나기 시작한 것이다. 그 후 다수 노동자에 대한 근로조건을 집단적이고 보다 통일적으로 처리하기 위한 필요성이 제기되면서 근로조건에 관한 여러 규정이 더해지게 되었고,[122] 그 결과 사용자와 개별 노동자 사이의 합의로 결정되어야할 근로조건이 실제로는 취업규칙으로 결정되어지는 경우가 증가하게 되었다는 측면이 있다.[123]

이 같은 취업규칙은 노동통제법규가 대부분이던 일제강점기와 남과 북이 서로 체제경쟁 측면에서 경쟁적으로 노동보호법규를 제정했던 미군정 등의 시대적 배경을 뒤로한 채 한창 6.25전쟁 중이던 1953년 05월 10일 피난 수도 부산에서 제정되었고 동년 08월 09일 법률 제286호로 시행되며 우리 앞에 명문 규정으로 등장하게 된다.[124] 이는 건국헌법에서 규정한 노동기본권을 구체화하기 시작한 노동입법이라 평가 받고 있으나[125] 당시의 노동입법은 미국의 노동법제 영향을 받은 일본의 노동기준법을 그대로 모방한 것에 불과한 것으로서 우리나라의 실질적 노동관계의 현실이 무시된 것이라는 평가도 존재한다.[126] 이후 1989년 03월 29일 「근로기준법」의 개

---

122)이병태, 앞의 책, 1020-1021면.
123)임종률, 앞의 책, 354면.
124)인권법교재발간위원회, 앞의 책, 344면.
125)이홍재(1999), 「노동기본권과 사회보장수급권의 실효성」, 『서울대학교 법학』 제39권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 112면.
126)김형배, 앞의 책, 50면.

정에 이르러 취업규칙의 불이익한 변경에 대한 노동자 집단의 동의제도를 도입하게 되었고, 2005년 03월 31일 개정 시 출산전후휴가와 모성보호, 육아휴직에 관한 사항을 추가했으며, 2008년 03월 28일 개정에서 일 · 가정 양립지원에 관한 사항을 추가해 넣게 되며 취업규칙 제도는 현재의 모습을 갖추게 됐다.[127]

오늘날에 이르러 취업규칙은 직업현장에서 통상적으로 사규, 내규, 복무규정 등 다양한 이름으로 불린다. 하지만 불리는 명칭에 관계없이 다수 노동자에게 집단적이고 통일적으로 적용되는 규칙의 총체로 포괄되며, 근로조건과 복무규율에 관한 내용을 사용자가 일방적으로 정하여둔 문서라는데 있어서 대부분 이견이 없다.[128]

> "…취업규칙이란 복무규율과 임금 등 근로 조건에 관한 준칙의 내용을 담고 있으면 그 명칭을 불문하는 것이므로 개별 근로계약에서 복무규율과 근로 조건에 관한 준칙의 내용을 담고 있으면 이 또한 취업규칙에 해당한다 할 것이다…"[129]

> "…회사의 급여규정(취업규칙)에서 상여금에 대해서는 '별도의 지침에 따른다'고 규정하였으나, 별도의 지침을 규정함이 없이 그동안 상여금 지급율을 500%씩 관행적으로 지급하였다면 동 관행은 근로조건화 되었다고 볼 수 있음. 관행으로 근로조건화된 상여금 지급률 등 근로조건을 변경하고자 하는 경우에는 취업규칙의 변경절차를 거쳐야…"[130]

따라서 취업규칙은 당사자 간에 근로조건의 이행 여부와 관련하여 논란이 있을 경우에 일종의 규범성을 가지고 상호간 근로조건의 이행 여부를 판단하는 잣대로 활용되기도 한다.[131] 하지만 취업규칙이 노동자에 비해 상대적으로 우월한 지위에 서있는 사용자 일방이 작성한 문서라는 점과 다수 노동자에 대해 가지고 있는 획일적 근로조건의 규율성으로 인하여 취업규칙으로부터 발생하는 폐해가 적지 않았던 것이

---

127)하갑래, 앞의 책, 143면.

128)김엘림 · 윤애림(2016), 『근로보호법』, KNOU PRESS, 80면.; 이상윤(2007), 『노동법』, 법문사, 372면.; 김엘림(2005), 『노동법Ⅰ』, 한국방송통신대학교출판부, 41면.; 정지원(2016), 「취업규칙 변경의 합리적 기준과 절차」, 고용노동부, 24면.

129)대법원 1997.11.28. 선고 97다24511 판결.

130)회사 내부의 공식적인 결재 과정을 거쳐 완성된 방침이 있고 이러한 내부방침에 근거해 노사간 장기간에 걸쳐 이러한 관행이 확립되어 실시되어 왔다면 그 역시 취업규칙으로 봐야한다는 의견이다. 2000.6.20 근기 68207-1873 참조.

131)하갑래, 앞의 책, 144면.

사실이다. 또 취업규칙의 내용이 관련 법령이나 단체협약에 위배된다거나 그 의미가 명확하지 않아 노동자들이 실질적으로 그 내용을 알고 있지 못하는 가운데 작성된다거나 변경이 진행되어 취업규칙을 사용자가 노동자를 희생시키는 도구로써 활용했던 측면도 있다.[132] 때문에 「근로기준법」에서는 이러한 폐해를 방지하기 위해 필요적 기재사항을[133] 포함한 취업규칙의 작성과 신고의 의무를 부과한다. 또한 취업규칙의 작성과 변경절차의 준수사항과 제재 규정의 제한, 법령과 단체협약의 준수의무, 위반의 효력, 법령 요지 등의 게시 의무 등도 다양하게 규정하여 보장하고 있다.

한편 취업규칙은 사용자 일방이 작성한다는 점에서 사용자와 노동자가 상호 합의에 의해 체결하는 근로계약이나 사용자와 노동조합이 합의에 의해 체결하는 단체협약과는 구별된다. 노동조합이 조직되지 않은 사업장에서는 취업규칙이 법령 이외에는 실질적으로 노동관계를 규율하는 유일한 집단적 규범으로서 작용될 수밖에 없게 된다. 또한 설령 노동조합이 조직되어 있다하더라도 단체협약에서 세부적인 내용까지 모두 규정하고 있기는 힘들다는 측면에서 볼 때 취업규칙은 사실상 사업장에서 상당히 중요한 규범으로 작용하게 되는 것이 어렵지 않게 추론된다.[134] 따라서 더욱 조심스러운 접근이 요구되며 내용의 해석측면에 있어서도 명확한 증거가 없는 한 문언 상의 객관적 의미를 무시하는 해석은 배척되어야만 한다. 또 그에 이르는 사실인

---

132)이병태, 앞의 책, 1021면.

133)현행 「근로기준법」은 총13가지의 필요적 기재사항을 명시하고 있으며, 그 내용은 아래와 같다.

제93조(취업규칙의 작성·신고) 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호의 사항에 관한 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다. <개정 2008.3.28., 2010.6.4., 2012.2.1.>

1. 업무의 시작과 종료 시각, 휴게시간, 휴일, 휴가 및 교대 근로에 관한 사항
2. 임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정기간·지급시기 및 승급(昇給)에 관한 사항
3. 가족수당의 계산·지급 방법에 관한 사항
4. 퇴직에 관한 사항
5. 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조에 따라 설정된 퇴직급여, 상여 및 최저임금에 관한 사항
6. 근로자의 식비, 작업 용품 등의 부담에 관한 사항
7. 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항
8. 출산전후휴가·육아휴직 등 근로자의 모성 보호 및 일·가정 양립 지원에 관한 사항
9. 안전과 보건에 관한 사항

9의2. 근로자의 성별·연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항

10. 업무상과 업무 외의 재해부조(災害扶助)에 관한 사항
11. 표창과 제재에 관한 사항
12. 그 밖에 해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항

134)하갑래, 앞의 책, 143면.

정은 해석상의 중요성을 감안해 보다 신중하고 엄격해야 할 것이다.[135]

Ⅱ. 법적 성질에 대한 입장의 대립

「근로기준법」 제4조에서 “근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 따라 결정하여야 한다.”라고 근로조건대등결정의 원칙을 규정하고 있다. 하지만 근로조건의 내용을 사용자 일방이 작성한 문서인 취업규칙에 노동자가 구속될 수밖에 없다는 점에 있어서 취업규칙의 법적 성질 부분에서 학설의 대립이 있는 등 논란이 있어 정리가 필요하다. 또한 취업규칙의 법적 성질은 우리 대법원 판례가 꾸준히 주장하는 ‘사회통념상 합리성’ 이론을 ‘실질적으로 취업규칙에 적용할 수 있는가’ 하는데 있어 주요한 판단의 근거가 되어주는 것이므로 확인해볼 가치가 있다.

우선 취업규칙의 법적 성질과 관련된 논의의 쟁점은 (1)「근로기준법」은 근로조건의 결정에 관해 노사대등결정의 원칙을 이상으로 하고 있는데 반해 그 이면으로 취업규칙에 대한 사용자의 일방적인 제정과 변경을 용인하는 모순을 취하고 있다는 점. (2) 근대 시민법은 국가의 제정법과 계약이 아닌 이상 당사자를 구속하는 법규범을 인정하지 않고 있음에도 취업규칙은 사실상 사회규범의 일종으로서 당사자를 구속하고 있기에 그 본질이 법규범인가 하는 의문이 생긴다는 점. (3) 취업규칙은 사용자가 일방적으로 작성할 수 있는 것임에 반해 의견청취 또는 동의 의무와 신고의무, 국가의 행정감독 등을 통해 내용의 정당성과 준수 여부를 확인하는 노동 보호적 역할을 하는 양면적 성격을 지니고 있는 점. (4) 취업규칙의 내용 중 근로조건에 관한 규정과 작업준칙 등에 관한 규정들이 그 성질과 효력이 다름에도 불구하고 서로 혼재되어 있어 그 성질을 통일적으로 구명하기 어렵다는 점으로 축약해 볼 수 있다.[136] 이에 대해 학설은 주로 ‘법규범설’과 ‘계약설’로 양분되어지고 판례의 입장은 법규범설상의 수권설로 파악된다.

---

135)대법원 2003.3.14. 선고 2002다69631 판결.

136)김치중(1987), 「취업규제에 관한 연구」, 석사학위논문, 서울대학교, 20면. ; 장진나(2008), 「취업규칙 불이익 변경시 사회통념상 합리성에 관한 연구」, 석사학위논문, 고려대학교, 7-8면에서 재인용.

1. 법규범설

법규범설은 말 그대로 취업규칙의 법적 성질 대해서 법규범성을 인정해 해석하는 것을 말한다. 하지만 법규범성의 근거를 어디에서 찾을 수 있는가하는 부분에서 견해는 또다시 나뉘어져 '소유권설(or경영권설)'과 '관습법설', '수권설'로 구분되어 진다.

1) 소유권설

'소유권설(or경영권설)'의 입장은 '취업규칙은 기업의 규율이고, 기업은 사용자가 소유권을 가지고 설립한 것인데 국가가 그러한 소유권을 법적으로 보장하기 때문에 취업규칙이 법규범이 된다는 견해'[137]이다. 그러나 사용자가 생산수단의 소유자나 이용자로서 공장시설 등의 관리와 운영권을 갖기는 하지만 그것을 이유로 근로조건에 대해 사용자의 일방적 결정권이 정당화되기는 어렵다는 문제가 발생하기에 오늘날 학설에서는 그 의의를 상실하고 있다.

2) 관습법설

'관습법설'의 입장을 보면, 취업규칙은 사업장이라고 하는 조직체가 스스로 만든 자치법규로서 「민법」 제1조[138]에 의해 법규범성을 부여받는다는 견해이다.[139] 하지만 이 견해에 비추어보면 실질적으로 장기간에 걸쳐 관습에 이해 확립된 규범에 대해서만 규범성을 인정할 수 있을 뿐, 취업규칙이 신설되었거나 기존의 취업규칙이 전면적으로 개정되어 동일성을 잃게 될 경우 관습으로 인정할 취업규칙이 사라지게 되므로 법규범성을 설명하지 못하게 되는 문제점이 발생한다.

---

137)하갑래, 앞의 책, 144면.
138)「민법」 제1조(법원) 민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.
139)하갑래, 앞의 책, 144면.

3) 수권설

'수권설'은 현재 우리나라 다수설의 입장이자 판례의 입장이다. 수권설은 취업규칙 자체로는 법규범성을 가지지 않는 사회규범에 불과하지만 「근로기준법」 제5조 [근로조건의 준수]와 제93조 [취업규칙의 작성·신고] 그리고 제97조 [위반의 효력] 등의 규정이 취업규칙에 노동자와 사용자 관계를 규율할 힘을 주어 법적 규범으로 활용될 수 있게 된다는 견해이다.[140] 이것은 취업규칙의 법규범성의 근거를 「근로기준법」 체계상의 지위에 조응하여 노동자 보호라는 입법 · 정책적 근거에서 찾아 창설적으로 법규범성을 부여할 수 있다는 것으로서,[141] 판례 역시 동일한 입장을 취하고 있는 것을 확인할 수 있다.

> "…이는 근로기준법이 종속적 노동관계의 현실에 입각하여 실질적으로 불평등한 근로자의 입장을 보호 강화하여 그들의 기본적 생활을 보호 향상시키려는 목적의 일환으로 그 작성을 강제하고 이에 법규범성을 부여한 것이라고 볼 것이므로…"[142]

2. 계약설

법규범설과 마찬가지로 계약설에서도 취업규칙의 구속력의 근거가 어디에 있는가에 따라 또 다시 여러 갈래로 견해가 구분되어져 '순수한 계약설', '사실규범설', '사실관습설' 등으로 구분된다.

1) 순수한 계약설

'순수한 계약설'의 입장은 시민법적 계약의 자유는 실질적으로 경제적 필연성의 관

---

140)하갑래, 앞의 책, 144-145면.
141)조득주(2008), 「취업규칙제도에 관한 연구」, 박사학위논문, 고려대학교, 22면.
142)대법원 1977.7.26. 선고 77다355 판결.

철이라고 이해되므로 사용자가 일방적으로 작성한 취업규칙을 법규로 보는 것은 근대적 법개념에 모순된다는 사고를 기초로, 일반적 계약조건으로서 당사자의 합의를 통해서 계약의 내용이 된다는 설이다. 이러한 순수한 계약설의 논리에 따르면 노동자가 실질적으로 취업규칙의 내용을 잘 모르거나 현실적으로 알 수 없을 경우라 할지라도 사용자가 노동자에게 취업규칙을 제시하였었던 사실만으로 법적 효력이 인정된다는 것이다. 하지만 이는 노동자가 취업규칙 변경 등에 대해서 동의하지 않는다 하더라도 합의된 것으로 보게 되므로 지나치게 의제적이라는 문제가 있다.[143]

2) 사실규범설

'사실규범설'은 취업규칙은 그 자체로는 법규범이 아니고 근로계약에 특별히 약정함으로서 근로계약의 내용이 된다는 설이다. 하지만 이 견해는 「근로기준법」 제96조와 제97조가 취업규칙을 사회규범으로서 법적 효력을 인정하고 있는 것에 부합하지 못한다는 단점이 있다.[144]

3) 사실관습설

'사실관습설'의 측면은 취업규칙에 의해 근로조건이 결정된다는 관습이 있기 때문에 「민법」 제106조의 사실인 관습에 해당하고 노동자가 근로조건에 반대한다는 의사표시가 없는 한 그러한 관습에 기초하여 노동자의 묵시적인 동의를 매개로하여 그 전체가 근로계약의 내용으로 된다는 설이다. 이에 따르면 취업규칙은 반대 의사를 표명한 노동자를 구속하지 않는 것이 원칙이지만 불이익변경의 경우에는 예외적으로 법률이 특별히 창설한 규정에[145] 따라 근로자의 집단적 동의를 받은 이상 개인적으로 반대 의사를 표명한 노동자에게도 구속력을 미친다는 결론에 도달한다.[146]

---

143)김형배, 앞의 책, 291면.
144)하갑래, 앞의 책, 145면.
145)「근로기준법」 제94조 제1항.
146)임종률, 앞의 책, 356면.

3. 판단

현재 주된 논의의 대상이 되는 '법규범설'상의 '수권설'과 '계약설'상의 '사실관습설'을 기준으로 보자면, '수권설'의 입장으로 보게 되면 취업규칙의 불이익한 변경 시에 노동자의 동의를 요하는 「근로기준법」 제94조 제1항의 규정을 설명하기 힘들다는 문제가 발생한다. 또한 '사실관습설'의 입장에서 보게 되면 노동자가 반대의 의사를 명확히 표시한 경우에 대해서까지 법적 효력을 갖는다는 점을 설명하기 힘들다는 난제에 부딪히게 된다. 대법원이 전원합의체 판결에서 법규범설과 계약설 사이의 절충적 입장을 표명한 바 있는데 이것은 이러한 연유를 기반으로 한 것으로 보인다.

> "…근로기준법 제95조의 규정에 의하여 노동조합 또는 근로자 과반수의 의견을 들어야 하고 특히 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 동의를 얻어야 하는 제약을 받는바, 기존의 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에 필요한 근로자의 동의는 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의임을 요하고 이러한 동의를 얻지 못한 취업규칙의 변경은 효력이 없다 는 것이 당원의 일관된 견해이다. 그러므로 사용자가 취업규칙에서 정한 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경함에 있어서 근로자의 동의를 얻지 않은 경우에 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 그 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지 되지만, 그 변경 후에 변경된 취업규칙에 따른 근로조건을 수용하고 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 하고, 기득이익의 침해라는 효력배제사유가 없는 변경 후의 취업근로자에 대해서까지 그 변경의 효력을 부인하여 종전 취업규칙이 적용되어야 한다고 볼 근거가 없다.…[147]

이는 집단적 동의의 결과로서 기득이익을 보존하겠다는 측면에서 기존 판례의 입장인 법규범설에 계약설의 일부를 도입한 것으로 판단되지만 이 판결 역시 논리적인 모순에 대한 비판에서는 여전히 자유롭지 못한 것이 사실이다.

---

147)대법원 1992.12.22. 선고 91다45165 판결.

법규범설과 계약설의 견해를 종합하여 볼 때 어떠한 견해를 취하더라도 결론적으로는 취업규칙이 구속력을 갖게 된다는 점에서는 차이가 없다. 그러나 현재 시점에서는 어떠한 견해를 취하더라도 취업규칙의 개별성과 집단성을 충분하게 설명한다는 것은 역부족하다.[148] 이에 취업규칙을 「헌법」상의 노동자 보호 이념의 구현을 위한 제도적 산물로 보아 「헌법」을 근거로 하는 「근로기준법」에 의해 그 요건을 모두 갖춘 경우에 한하여 규범성을 인정하고, 만일 작성이나 변경 등에서 법적요건과 절차를 제대로 갖추지 못한 경우에는 규범성을 부정하는 편이[149] 보다 합리적으로 보이지만 그 역시도 명쾌한 답이 되어줄 수는 없다. 이처럼 현재까지의 학설과 판례의 입장으로는 명확한 설명이 어렵다는 결론에 도달한다. 하지만 취업규칙의 법적 성질이 실질적으로 무엇인가 하는 것은 노동자에게 불리하게 변경된 취업규칙을 적용할 수 있는가 하는 효력발생 요건의 문제를 해결하기 위한 수단이 되는 것인 만큼 보다 적극적인 논의의 대상으로 삼을 필요성이 요구된다.

Ⅲ. 효력과 효력발생시기

「근로기준법」 제97조에서는 "취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 따른다."고 명시하여 근로계약에 대한 취업규칙의 효력을 정해두고 있다. 이는 취업규칙에 미달하는 조건을 내용으로 하고 있는 근로계약상의 근로조건은 효력을 상실하게 된다는 측면에서의 '강행적 효력'과 그 강행적 효력으로 인해 무효로 되어 효력이 상실된 부분에 대해서는 취업규칙이 직접적으로 적용돼 규율한다는 측면에서 '직접적 효력'을 동시에 내포하고 있는 것으로 취업규칙이 근로조건의 최저기준선임을 명확히 밝히고 있는 것이다.

또한 「근로기준법」 제96조 제1항은 "취업규칙은 법령이나 해당 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약과 어긋나서는 아니 된다."라고 규정하여 취업규칙이

148)장진나, 앞의 논문, 16면.
149)이병태, 앞의 책, 1025면.

효력을 발휘할 수 있는 조건을 명시하고 있다. 여기서 말하는 '취업규칙'은 「근로기준법」상 취업규칙 작성의무가 있는 상시 10인 이상의 노동자를 사용하는 사업장에 비치된 다수 노동자에게 집단적, 통일적으로 적용되는 규칙의 총체만을 의미하는 것이 아니다. 「근로기준법」 제96조 제1항이 말하고 있는 취업규칙은 좀 더 넓은 범위를 포괄하고 있는 것으로 작성과 비치 의무가 없는 상시 10인 미만의 노동자를 사용하는 사업장의 그것 역시 여기서 말하는 취업규칙에 해당한다.[150]

이어 '법령'이라 함은 「근로기준법」과 그 시행령은 물론이고 「남녀고용평등법」, 「최저임금법」, 「퇴직급여보장법」, 「산재보험법」, 「산업안전보건법」, 「노동조합 및 노동관계조정법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」, 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 등과 그 시행령과 같이 강행적 효력을 가지고 있는 법령을 말한다.[151] 이때 비단 노동관계 법령에만 한정하여 볼 것이 아니라 당해 근로관계에 적용되는 일체의 법령을 말하는 것으로 보아야하고 지방자치단체가 정한 조례 · 규칙 등의 자치법규도 강행적 성격을 띤 것이라면 모두 포함하는 것으로 보는 것이 합리적이다.[152] 또 이에 관해서는 벌칙조항의 유 · 무를 조건으로 하지 않으며 「민법」 제103조의 반사회질서의 법률행위에 관한 규정까지도 포함한다고 보아야 한다.[153] 따라서 이러한 법령의 기준에서 벗어나는 내용을 담은 취업규칙이라면 그 내용은 효력이 없다. 다만 법령의 기준에서 다소 벗어나는 내용을 담은 취업규칙일지라도 그 내용이 노동자에게 실질적으로 유리한 것이라면 그 조항은 효력을 잃지 않고 유리조건우선의 원칙을 적용해 노동자에게 그대로 귀속되므로 노동자들은 그러한 취업규칙을 우선 적용받게 된다.

한편 '단체협약에 어긋나서는 아니 된다.'라는 부분을 살펴보기 전에 우리 법원의 판례를 검토해보자면 단체협약과 취업규칙의 구별기준에 대해 법원이 나름대로의 기준을 설정해 두고 있는 것을 알 수 있다.

"…단체협약은 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준 등에 관한 사항을 정

150)임종률, 앞의 책, 368면.; 김형배, 앞의 책, 284면.
151)김형배, 앞의 책, 298면.
152)조득주, 앞의 논문, 80면.
153)이병태, 앞의 책, 1051면.

하는 협정으로서 서면으로 작성하여 노사 쌍방이 서명날인하여야 하고, 유효기간에 있어서 일정한 제약이 따르며, 원칙적으로 노동조합원 이외의 자에 대하여는 그 규범적 효력이 미치지 아니하는 것이고, 이에 비하여 취업규칙은 사용자가 근로자의 복무규율과 임금 등 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 준칙을 규정한 것을 말한다.…"[154]

판례는 단체협약의 범위에 대해 반드시 노조법상의 요건을 갖춘 노동조합과 맺은 단체협약에 국한될 것이 아닌 근로조건 기타 대우에 관한 기준 등에 관한 사항을 담고 있는 것으로 노사 쌍방이 서명, 날인한 협정이라면 단체협약의 대상이 되는 것으로 판단한다. 따라서 그러한 단체협약에 어긋나는 취업규칙이라면 당연히 무효가 되어 해당 조항은 효력을 발생할 수 없다.

이때 노동부장관은 「근로기준법」의 근거 조항을[155] 들어 법령이나 단체협약에 어긋나는 취업규칙에 대해서 변경할 것을 명령할 수 있다. 하지만 이는 취업규칙을 변경하도록 사업주에게 의무를 부과하는데 그치는 것으로서 변경 명령 자체가 취업규칙의 변경을 불러오는 것은 아니다. 따라서 사용자가 실질적으로 그 명령에 따라 취업규칙의 변경절차를 거치는 등 후속절차를 이행하였을 때 비로소 취업규칙이 유효하게 변경 완료된 것으로 본다. 그러나 만일 사용자가 변경명령에 따라 취업규칙 변경을 이행하지 아니할 경우, 변경명령의 대상이 되었던 취업규칙의 내용은 효력이 부정되고 노동부장관의 명령을 이행하지 않은 사용자는 형사처벌의 대상이 된다.

원칙적으로 취업규칙의 작성 또는 변경 조건을 충족하는 유효하게 성립된 취업규칙은 당해 사업이나 사업장에서 노사관계를 규율하는 구속력을 형성하게 되는 것이 당연하다. 하지만 유효한 취업규칙의 효력 발생시점에 대해서는 여전히 의론이 있다.

통상적으로 사용자가 취업규칙을 작성하거나 변경할 당시 행정관청에 신고하기까지에 이르는 일련의 절차를 모두 마무리한 다음 시행일을 명시하여두고 노동자에게 주지한 경우 그 시행일에 효력이 발생한다는데 있어서는 이견이 없다. 하지만 시행일을 명시하지 아니한 경우에 있어서 노동자에게 실질적으로 의견청취 또는 동의를

154)대법원 1997.4.25. 선고 96누5421 판결.
155)제96조 제2항. 고용노동부장관은 법령이나 단체협약에 어긋나는 취업규칙의 변경을 명할 수 있다. <개정 2010.6.4.>

완료한 때가 효력의 발생시기로 볼 것인가,[156] 아니면 행정관청에 신고를 완료하였을 때가 효력의 발생시기가[157] 되는 것인가 하는 점이 주로 문제가 되는데, 절차상의 하자 없이 행정관청에 신고를 완료하였을 때가 효력의 발생 시점이 되는 것이 보다 합리적이라 판단된다.

제3절 취업규칙 변경절차의 법적구조

Ⅰ. 의견청취 대상과 동의주체

원칙적으로 취업규칙의 작성과 변경에 관한 부분에 대해서는 사용자에게 권한이 있으므로, 단체협약이나 노사협의에서 달리 정함이 없다면 사용자가 취업규칙을 단독으로 작성하거나 변경할 수 있다.

> "…단체협약에 명문으로 징계규정을 별도로 제정하기로 하였고, 그 규정에 의하여 징계규정이 만들어진 이상 다시 구체적인 징계규정의 내용에 관하여 회사와 근로자 간에 합의가 있어야 한다고 말할 수 없고, 근로자의 상벌 등에 관한 인사권은 사용자의 고유권한으로서 그 범위에 속하는 징계권 역시 기업운영 또는 노동계약의 본질상 당연히 사용자에게 인정되는 권한이기 때문에 그 징계규정의 내용이 강행법규나 단체협약의 내용에 반하지 않는 한 사용자는 그 구체적 내용을 자유롭게 정할 수 있고…"[158]

다만, 사용자 일방이 정한 취업규칙의 내용이 노동자의 근로조건에 직접적으로 영향을 미치게 됨에 따라 그러한 취업규칙의 구속력이 인정되기 위해서는 취업규칙의 작성이나 변경 시에 노동자가 참여할 수 있는 제도적 장치가 필수적으로 요청된

---

156)하갑래 교수는 "취업규칙을 작성하거나 불리하지 않게 변경한 경우에는 그 시점이 효력발생 시기가 되며 불리하게 변경한 경우에는 근로자 집단의 동의를 받은 시점이 효력발생 시점"이라는 견해를 주장한다. 하갑래, 앞의 책, 173면.

157)이병태 교수는 "취업규칙의 규범성은 근기법에 그 근거를 두고 있으므로 취업규칙은 근기법에 따른 절차를 모두 마친 뒤 비로소 효력이 생긴다"고 주장한다. 이병태, 앞의 책, 1049면 참조.

158)대법원 1994.9.30. 선고 94다21337 판결.

다.[159] 이에「근로기준법」은 이러한 취업규칙의 한계를 보완하고 내용의 적정성을 기하기 위해 사용자가 취업규칙을 변경할 시 그 적용을 받는 노동자의 의견을 청취하고 그 변경의 내용이 불이익할 시에는 동의를 얻도록 규정하고 있다.[160]

이 같은 측면으로 접근하여 본다면 취업규칙의 변경은 당사자인 사용자와 노동자 사이에서 새로운 의사의 합치를 전제로 하여야만 한다는 결론에 도달한다.[161] 이것은 노동자에게 취업규칙에 관하여 발언권을 부여함과 동시에 사용자 일방의 취업규칙 작성과 변경 진행에 있어 노동자의 의견을 반영할 기회를 부여하고 이를 통해 실질적으로도 그 내용이 반영될 수 있도록 노력하라는 목적을 내포하고 있는 것이다.[162] 또 더 나아가서는 「헌법」적 함의로서 노동기본권 측면에서의 '일할 환경에 관한 권리'를 보장하여 합리적인 근로조건을 보장하기 위하는데 그 목적이 있다.

그렇다면 의견청취의 대상과 동의의 주체에 대한 개념을 우선 정립해둘 필요가 생긴다. 먼저,「근로기준법」 제94조의 규정을 살펴보면, '노동자 과반수로 조직된 노동조합이 있을 경우에는 그 노동조합', '노동자 과반수로 조직된 노동조합이 없을 경우에는 노동자의 과반수'로 의견청취의 대상과 동의의 주체에 대해 명문으로 규정하고 있음을 확인할 수 있다. 이에 '노동자 과반수로 조직된 노동조합이 있을 경우의 그 노동조합의 동의' 요건의 범위를 확인하여 한정할 필요가 있는데,「근로기준법」에서 말하는 과반수로 조직된 노동조합은 통상적으로 노동자 과반수로 구성된 노동조합의 노동조합 대표를 말한다. 따라서 이 경우 당해 사업장의 노동조합 대표에게 동의권이 있다고 보아야 한다.[163]

"…근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 회사에서 취업규칙이 근로자에게 불리하게 변경되는 경우 그에 대한 노동조합의 동의를 얻어야 하는데, 이 경우에

159)하갑래(2009),「취업규칙 불이익변경에 있어 사회통념상 합리성」,『법학논총』 제33권 제2호, 단국대학교 법학연구소, 768면.

160)「근로기준법」은 제94조 제1항에서 "사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다."고 규정하고 있다.

161)박종희(2015),「임금피크제와 취업규칙 변경절차에 관한 법적 검토」,『노동법포럼』 제15호, 노동법이론실무학회, 28면.

162)임종률, 앞의 책, 359면.

163)하갑래, 앞의 책, 156면.

있어서 노동조합의 동의는 법령이나 단체협약 또는 노동조합의 규약 등에 의하여 조합장의 대표권이 제한되었다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 조합장이 노동조합을 대표하면 되는 것이지 노동조합 소속 근로자의 과반수의 동의를 얻어서 하여야 하는 것은 아니라고 하여…"[164]

한편 노동조합의 지부 또는 분회는 독자적인 노동조합이 아니므로 「근로기준법」 제94조 제1항에서 말하는 노동조합에 해당하지 않는다고 보아야하지만,[165] 연합노조로부터 취업규칙의 변경동의권을 위임받은 것으로 볼 수 있다면 참여주체로 인정된다.[166] 또한 노동조합 대의원대회의 위임을 받은 조합운영위원회의 취업규칙변경 동의서는 유효하다고 본다.[167] 반면, 취업규칙의 작성과 변경에 있어 노동자의 참여제도는 강행규정의 성격을 갖고 있으므로 이사회나 경영협의회 등 다른 제도로 대체할 수 없다.[168] 따라서 노동조합과는 법적지위가 명확히 다른 노사협의회는 인정되지 않고 노동자 과반수로 조직되지 않은 소규모 노동조합 역시 해당하지 않는다.

이어 '노동자 과반수로 조직된 노동조합이 없을 경우에서 노동자 과반수의 동의'가 뜻하고 있는 노동자 과반수의 개념은 종전의 취업규칙의 적용을 받고 있던 노동자의 과반수를 의미한다. 이때 노동자 과반수로 조직된 노동조합의 경우에 있어서의 '노동조합의 대표자'와는 달리 '노동자의 과반수를 대표하는 자'가 아닌 '개별 노동자의 과반수'의 의견을 들어야 한다는 점이 차이점이다.[169]

"…그 동의방법은 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의, 그와 같은 노동조합이 없는 경우에는 근로자들의 회의방식에 의한 과반수의 동의가 있어야 하고, 여기서 말하는 근로자의 과반수라 함은 기존 취업규칙

164)대법원 2002.6.28. 선고 2001다77970 판결.
165)임종률, 앞의 책, 52-53, 359면.
166)"…노동조합이라 함은 설립신고 된 노동조합을 의미하므로 설립신고 되지 않은 노동조합의 임의조직인 분회장이 노동조합으로부터 취업규칙 변경 동의에 관한 위임을 받지 않고 임의 동의한 취업규칙은 효력이 없음…", 2001.5.10. 근기 68207-1521 행정해석 참조.
167)"노동조합 대의원대회에서 이에 관한 권한을 위임받은 위 조합운영위원회가 비누진제를 받아들이기로 결의하였다 하여 이를 유효로 본 사례." 대법원 1984.11.3. 선고 84다카414 판결 참조.
168)하갑래, 앞의 책, 152면.
169)이 점에 있어서는 기존 '근로자 과반수를 대표하는 자'에서 1989년 03월 29일 「근로기준법」의 개정 시에 현재의 '근로자 과반수'로 변경된바 있다.

의 적용을 받는 근로자 집단의 과반수를 뜻한다.…”[170]

하지만 간주근로시간제나 탄력적 근로시간제, 선택적 근로시간제, 경영상의 이유로 인한 고용조정 등의 사례에 있어 적용되는 노동자 대표의 개념은 「근로기준법」 제94조 제1항이 말하고 있는 노동자 대표의 개념으로 포섭할 수 없기에 주의해야 한다.[171] 또한 「근로자 참여 및 협력 증진에 관한 법률」에 의한 노사협의회의 노동자 대표 역시 취업규칙의 작성과 변경 시 의견청취의 대상이 되는 노동자 대표의 주체가 될 수 없음을 유념할 필요가 있다.

“…취업규칙상의 정년규정을 신설함에 있어서 노사협의회의 구성원인 근로자위원 전원으로부터 위 55세 정년규정의 신설에 대하여 동의를 받았다고 하더라도 노사협의회는 근로자와 사용자 쌍방이 이해와 협조를 통하여 노사공동의 이익을 증진함으로써 산업평화를 도모할 것을 목적으로 하는 제도로서 노동조합과 그 제도의 취지가 다르므로 비록 노동부 예규가 근로조건에 관한 사항을 그 협의사항으로 규정하고 있다 하더라도……노사협의회의 근로자위원들 또는 노조분회장의 동의를 얻은 것을 노동조합 또는 근로자들 과반수의 동의를 얻은 것과 동일시 할 수는 없고…”[172]

“…노사협의회는 생산, 교육, 작업환경, 불만처리, 노사분규의 예방 등에 관하여서만 협의 할 수 있을 뿐 근로조건에 관한 사항은 그 협의의 대상이 될 수 없으므로 위와 같은 방식에 의한 집단적 의사결정에 의하지 아니한 채 노사협의회의 의결만을 거친 취업규칙의 변경은 그 효력이 없다.…”[173]

Ⅱ. 의무적 사항으로서 의견청취

대법원은 「근로기준법」 제94조 제1항을 적용한다 할지라도 취업규칙의 내용이 불리하게 변경되지 않는다면, 사용자가 취업규칙의 내용이 변경되게 됨에 따른 노동

170)대법원 2008.2.29. 선고 2007다85997 판결.
171)하갑래, 앞의 책, 152면.
172)대법원 1997.5.16. 선고 96다2507 판결.
173)서울고등법원 1990.3.2. 선고 89나27081 제1민사부 확정판결.

자의 의견청취를 하지 않았다고 해서 취업규칙의 변경 자체가 무효로 되는 것은 아니라고 판시한다. 단지, 「근로기준법」 제114조에 해당하는 벌칙의 대상이 될 뿐이지 의견청취를 하지 않았다는 이유만으로 변경된 취업규칙 자체가 효력이 발생되지 않는 것은 아니라는 것이다.

> "…취업규칙의 작성·변경에 관한 권한은 원칙적으로 사용자에게 있으므로 사용자는 그 의사에 따라 취업규칙을 작성·변경할 수 있다 할 것이고, 단체협약에서 취업규칙의 작성·변경에 관하여 노동조합의 동의를 얻거나 노동조합과의 협의를 거치거나 그 의견을 듣도록 규정하고 있다 하더라도 원칙적으로 취업규칙상의 근로조건을 종전보다 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우가 아닌 한 그러한 동의나 협의 또는 의견청취절차를 거치지 아니하고 취업규칙을 작성·변경하였다고 하여 그 취업규칙의 효력이 부정된다고 할 수 없다.…"[174]

이는 취업규칙의 필요적 기재사항을 일부 누락하거나 제외시킨 경우 작성의무 위반으로 벌칙의 대상이 될 뿐이지 효력발생에 영향을 주는 것은 아니라고 판단하는 것과 같은 맥락으로 보인다. 학설에서는 이러한 의견청취의무 위반에 대해 다툼이 있는데 '효력규정설'의 입장으로 본다면, 「근로기준법」 제94조 제1항이 정하고 있는 의견청취의무는 "기업 내 노사대등을 확보하기 위한 기초이고, 취업규칙의 합리성을 확보하기 위한 조건이므로 근로자 측의 의견청취가 없는 취업규칙의 작성 · 변경은 무효"이고 "의견청취에 관한 본문은 단속규정으로 보고 불이익변경 동의의 단서는 효력규정이라고 보는 것은 논리의 일관성을 결여"한다고 보는 입장이다.[175]

그러나 현재의 다수설이 취하고 있는 견해는 취업규칙의 변경 사항이 불이익한 변경이 아닌 이상 그 내용이 적법하다면 민사상의 효력에는 아무런 영향이 없다는 '단속규정설'로 보인다.[176] 하지만 이 같이 단속규정설의 입장을 취하는 경우에 있어서도 여전히 「근로기준법」이 담아내고 있는 노동자 보호의 취지가 몰각되지 않을 수 있도록 최대한 노력해야하며, 취업규칙의 작성과 변경을 진행함에 있어서 노동자의

---

174)대법원 1994.12.23. 선고 94누3001 판결.
175)이병태, 앞의 책, 1032면.
176)김형배, 앞의 책, 296면.; 임종률, 앞의 책, 362면.; 하갑래, 앞의 책, 155면.; 대법원 1994.12.23. 선고 94누3001 판결.; 1999.6.22. 선고 98두6647 판결.

이익과 조화를 이룰 수 있도록 노동자의 의견 청취는 성실히 이루어져야 한다.[177]

통상적인 부분에서 의견청취 의무는 취업규칙의 내용에 불이익한 변경이 따르지 않는다는 전제가 있기에 반드시 노동자 집단의 동의나 합의를 얻을 것까지를 요하지 않는다. 따라서 취업규칙의 변경을 목적으로 사용자가 진행하는 의견청취에 대해 노동자 집단이 의견제시를 거부한다거나 반대의 의사를 표시한 자가 더 많을지라도 의견청취의 효력으로는 아무런 하자가 없다고 보인다.[178] 나아가 이른바 '근로조건 변경 예고제' 역시 인정되는데 노동자 과반수에게 배포하여 취업규칙의 변경내용을 공람케 하고 서명을 받는 등 실질적으로 노동자 과반수가 취업규칙의 변경내용을 인지할 수 있었다면, 「근로기준법」 제94조 제1항의 의무를 이행한 것으로 보는 것이 합리적이다.[179]

Ⅲ. 불이익한 변경시의 동의 문제

1. 불이익함의 판단 기준

우리가 취업규칙의 불이익한 변경 시 동의 요건을 논하기 위해서 불이익의 개념을 확인해 볼 때, 과연 취업규칙의 어떠한 경우의 변경까지를 노동자에게 불리하게 변경되는 경우로 판단할 것인가 하는 '범위의 문제'와 어떠한 사안을 노동자 집단의 동의 대상이 되는 불이익한 변경으로 적용해야 하는가 하는 '기준의 문제'를 먼저 마주하게 된다. 하지만 「근로기준법」은 취업규칙의 변경에 대한 불이익 여부의 판단에 대해 아무런 정함을 두지 않고 있기 때문에 학설과 판례 등의 입장에 기대어 판단하고 해결해 볼 수밖에 없는 실정이다.

먼저 취업규칙에서 정하고 있는 근로조건을 노동자에게 불리하게 변경하는 경우에 있어 그 범위를 어떻게 볼 것인가에 대한 '범위의 문제'는 판례를 통해 확인해 볼 수

177)방준식(2016), 「임금피크제의 도입에 따른 법적 문제」, 『법학연구』 제24권 제2호, 한국노동법학회, 136면.
178)노동부 1991.6.27. 근기 01254-9222 행정해석.
179)노동부 1991.8.28. 근기 01254-12348 행정해석.

있다. 우리 판례는 이미 작성되어 정함이 있는 취업규칙의 내용을 노동자에게 불리하게 변경하는 경우로만 동의의 대상을 한정할 것이 아니라 취업규칙의 작성 이전에 이미 노동자에게 적용하고 있었던 내용을 노동자에게 불리하게 변경하거나 새로이 신설하여 적용하는 경우까지 동의의 대상으로 확장하여 포함한다.

"…취업규칙의 작성 또는 변경이 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하여 불이익한 근로조건을 부과하는 내용일 때에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자집단의 집단의사 결정방법에 의한 동의를 요하고 이러한 동의가 없이 작성, 변경된 취업규칙은 무효라고 보아야 할 것이다.……인사규정제정당시에 신설되었던 또는 그 후 개정 시에 신설되었던 위와 같은 조항은 근로자에게 불이익한 근로조건이므로 이를 새로이 취업규칙의 일부로 넣으려면 미리 근로차측의 집단의사결정방법에 의한 동의를 받아야만 그 효력이 있다고 할 것이다.…"[180]

다른 한편으로 '기준의 문제' 측면에서의 학설과 판례 입장은 전체 노동자를 대상으로 하는 취업규칙의 내용이 일부 특정한 근로조건은 유리하게 변경되는 반면, 또 다른 근로조건에서는 불리하게 변경되는 경우에 유리한 조건과 불리한 조건의 대가관계나 연계성 등을 고려하여 제반사정을 종합적으로 판단해 그 취업규칙의 변경이 유리한 변경인지 불리한 변경인지를 판단해볼 필요가 있다고 하여,[181] 기본적으로는 취업규칙의 불이익한 변경에 대해 종합적인 판단을 전제로 한다.

"…개정의 유·무효를 판단함에 있어서 우선 퇴직금 지급률이 전반적으로 인하되어 그 자체가 불리한 것이라고 하더라도 그 지급률의 인하와 함께 다른 요소가 유리하게 변경된 경우에는 그 대가관계나 연계성이 있는 제반 상황(유리하게 변경된 부분 포함)을 종합 고려하여 과연 그 퇴직금에 관련한 개정 조항이 유리한 개정인지 불리한 개정인지를 밝혀서 그 유·불리를 함께 판단하여야 할 것…"[182]

여기서 말하고 있는 '대가관계'란 어느 근로조건을 불리하게 변경하는 대신 이를

180)대법원 1995.3.10. 선고 94다18072 판결.
181)이병태, 앞의 책, 1037면.
182)대법원 1995.3.10. 선고 94다18072 판결.

보상하기 위해 새로운 근로조건을 마련하거나 기존의 조건을 종전보다 더 유리하게 변경하는 것을 말하며, '연계성'이란 변경 전의 조건이나 제도의 성격이나 내용에 있어 밀접한 관련이 있는 것을 의미한다. 따라서 제반 상황 고려 시 대가관계는 '보상을 한다는 사용자의 주관적 의사'에서, 연계성은 '성격이나 내용상의 밀접한 관련 부분이라는 객관적 기준'이 각각 판단의 기준으로 작용한다.[183]

이 같은 부분에 있어서 취업규칙의 변경 시 특정한 근로조건이 불리하게 변경되고 다른 근로조건이 유리하게 변경되는 경우에는 전체를 불이익으로 보아야 한다는 반대 의견도[184] 있다. 하지만 취업규칙의 변경으로 인해 일부 저하되는 조건이 있을지라도 노동자들의 기득의 권리를 침해하는 부분이 비교적 크게 차지하지 않고 그에 비해 개선되는 조건의 범위가 넓어, 실질적으로 그 변경된 취업규칙의 적용을 받게 될 노동자들이 얻게 될 이익이 일부 저하되는 조건을 충분히 상쇄시킬 만큼 크다면 불이익한 변경이 아니라고 판단된다.

반면 변경된 취업규칙이 일부 노동자에게는 유리하지만 일부 노동자에게는 불리하게 적용되는 것과 같이 취업규칙의 변경에 대한 불이익의 판단이 어려운 경우에는 변경된 규정의 적용으로 하여금 유 · 불리를 달리하는 노동자 집단의 규모를 상호 비교할 필요 없이 모두 불이익한 변경으로 보는 것이 합리적이라는 점에[185] 있어서 학설과 판례는 의견을 같이 한다.

> "…취업규칙의 일부를 이루는 급여규정의 변경이 일부의 근로자에게는 유리하고 일부의 근로자에게는 불리한 경우 그러한 변경에 근로자집단의 동의를 요하는지를 판단하는 것은 근로자 전체에 대하여 획일적으로 결정되어야 할 것이고, 또 이러한 경우 취업규칙의 변경이 근로자에게 전체적으로 유리한지 불리한지를 객

183)정진경, 앞의 책, 9면.

184)곽동효는 "규범으로서의 유기체적 성격이나 동일성에 반하며, 불이익변경은 구규정과 신규정 전체를 비교하는 것이어서 개정이 무효라고 하면 개정 자체가 없게 되어 신규정은 존재하지 아니하므로 그 이후의 유·무효가 거론될 여지가 없는 점에서 대법원 판결이 노사쌍방의 입장을 고려한 것으로 법현실에 부응하는 면이 있다고 하더라도 무리한 해석이고, 전체적으로 근로자에게 불이익한 것으로 보아 전체가 무효로 되는 것으로 해석해야 한다."는 견해를 밝히고 있다. 곽동효(1996), 「일정기간의 근속기간에 대한 지급률만이 정하여진 퇴직금규정을 근로자의 동의 없이 개정하면서 종전의 지급률은 낮추고 그 이후의 지급률을 새로이 정한 경우의 효력」, 『재판과 판례』 제5집, 대구판례연구회, 472-473면.; 정진경, 앞의 책, 11면에서 재인용.; 같은 의견으로 임종률, 앞의 책, 362면.

185)임종률, 앞의 책, 363면.; 김형배, 앞의 책, 305면.

관적으로 평가하기가 어려우며, 같은 개정에 의하여 근로자 상호간의 유, 불리에 따른 이익이 충돌되는 경우에는 그러한 개정은 근로자에게 불이익한 것으로 취급하여 근로자들 전체의 의사에 따라 결정하게 하는 것이 타당하다.…"[186]

"…규정의 개정으로 인하여 피고가 근로자들에게 지급하게 되는 임금의 총액이 기존의 급여 체계에 비하여 증가하였다 하더라도, 위와 같이 위 규정의 적용을 받게 되는 근로자 개인에 따라 그 유 · 불리의 결과가 달라진다면, 위 규정은 근로자에게 불이익한 것으로 취급하여 근로기준법에 따른 변경절차를 따라야 한다.…"[187]

그렇다면 취업규칙의 변경이 불이익한 변경에 해당하는가에 대한 여부를 판단하게 되는 기준 시점을 언제로 해야 하는가 하는 논의도 있을 수 있다. 하지만 이 점은 취업규칙 개정 당시의 시점으로 한정하여 기준으로 삼는 것이 보다 합리적이다.

"…취업규칙의 일부인 퇴직금 규정의 개정이 근로자들에게 유리한지 불리한지 여부를 판단하기 위하여는 퇴직금 지급률의 변화와 함께 그와 대가관계나 연계성이 있는 기초임금의 변화도 고려하여 종합적으로 판단하여야 하지만, 그 판단의 기준 시점은 퇴직금 규정의 개정이 이루어진 시점이라고 할 것인바…"[188]

만일 취업규칙의 변경에 대한 기준 시점을 실질적으로 불이익하게 개정이 이루어진 시점이 아닌 취업규칙의 불이익한 개정 이후에 새로 신설된 또 다른 규정까지 포함하여 취업규칙의 불이익한 변경 여부를 종합적으로 판단하게 된다면, 자칫 그 전체를 한 개의 틀로 보아 판단하게 될 수 있어 동의 대상인 해당 규정의 개정이 노동자들에게 유리한 것으로 오판하게 되어 노동자들의 동의를 얻을 필요가 없다고 결론짓게 되는 우를 범할 수도 있다.

2. 절차적 요소로서 집단적 동의

186)대법원 1993.5.14. 선고 93다1893 판결.
187)서울중앙지법 2017.5.18. 선고 2016가합566509 판결.
188)대법원 2000.9.29. 선고 99다45376 판결.

「근로기준법」 제94조 제1항이 규율하고 있는 '동의' 규정은 사용자 일방이 취업규칙의 내용을 노동자에게 불리하게 변경하여 노동자의 기득의 권리나 이익을 박탈하고 근로조건을 저하시키거나 복무규율을 강화하는 것에 대해 일방적으로 진행하는 것을 방지하려는 취지로 규정된 것이다.[189] 이는 실질적인 의미에서 노사대등결정 원리를 투영한 것으로,[190][191] 노동자가 사용자에게 종속되어 있는 객관적 현실 속에 노사 간의 힘의 균형을 회복시켜 진정한 의미의 자유를 실현하는데 목적이 있다.[192]

이 같은 동의의 범위에는 기왕의 취업규칙에 정해져 있던 사항이 아니라 할지라도 노동자에게 불리한 취업규칙 규정을 신설하는 것 역시 불이익한 변경으로 보아 노동자 집단 과반수의 동의 대상에 포함시킨다.

> "…취업규칙의 변경에 의하여 기존 근로조건의 내용을 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하려면 종전 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자 집단의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 요한다 할 것이고 그 동의방법은 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의, 그와 같은 노동조합이 없는 경우에는 근로자들의 회의방식에 의한 과반수의 동의가 있어야 하고 위와 같은 방법에 의한 동의가 없는 한 취업규칙의 변경으로서의 효력을 가질 수 없다.…"[193]

> "…근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 회사에서 취업규칙에 근로자에게 불리한 정년제 규정을 신설하는 경우, 그에 대한 노동조합의 동의를 얻어야 하는데…"[194]

반면에 집단적 동의 절차를 거쳐 적법하게 불이익하게 변경된 취업규칙을 동의 이전까지 소급하여 적용할 수 있는가 하는 소급가능성 여부에 대한 다툼이 있을 수 있는데, 판례와 학설은 변경된 취업규칙의 소급적용에 대해 부정한다.

---

189)이병태, 앞의 책, 1037면.

190)김성진(2015), 「근로조건 대등결정의 원리」, 『노동법학』 제54호, 한국노동법학회, 8면.

191)「근로기준법」이 취업규칙의 불리한 변경 시 노동자의 집단적 동의를 받도록 한 것은 이 같은 기득이익 보호 원칙과 노사대등결정 원리 외에도 「근로기준법」의 기본원리로서 노동자보호의 정신과 근로조건의 통일적 규율을 위한 규범적 요청에 따른 것이다. 노동법실무연구회(2010), 『근로기준법 주해Ⅲ』, 박영사, 479면 참조.

192)조경배(2003), 「취업규칙 불이익변경의 유효요건인 집단적 동의 : 대법원 2003. 4. 11 선고, 2002다71832 판결에 대한 분석과 평가를 중심으로」, 『사회과학연구 논문집』 제9권 제1호, 순천향대학교 사회과학연구소, 59면.

193)대법원 1991.9.24. 선고 91다17542 판결.

194)대법원 1997.5.16. 선고 96다2507 판결.

"…퇴직금지급율에 관한 취업규칙이 근속기간에 따른 누진제에서 단순제로 변경된 경우 취업규칙의 불이익변경에 대한 근로자들의 동의가 있었다고 하여도 그것만으로는 불이익하게 변경된 취업규칙이 종전 재직기간에 대하여까지 소급적용된다고 볼 수는 없으므로, 위 취업규칙 변경 이전에 입사하였다가 그 변경 이후에 퇴사한 근로자의 퇴직금을 산정함에 있어서 입사일부터 퇴직금지급율 변경 전까지의 재직기간에 대한 퇴직금지급율에 관하여는 종전 취업규칙을, 그 이후 퇴사일까지의 재직기간에 대한 퇴직금지급율에 관하여는 변경된 취업규칙을 각 적용하여 계산하여야 한다.…"[195]

그러나 그 내용이 노동자에게 유리할 경우에는 '기득권 보호의 법리'와 '불이익 불소급의 원칙'에 반하지 않는 것으로 보아 예외적으로 소급적용도 인정한다.[196]

"…해외연수 근로자가 퇴직할 당시 인사규정이 근로자에게 더 유리하게 개정되었다면 아직 면제기간이 진행중이던 근로자의 해외연수비용 상환의무를 면제받는 의무복무기간은, 개정된 인사규정에 소급적용을 배제하는 별도의 규정이 없는 한, 유리하게 개정된 인사규정이 적용된다.…"[197]

한편 집단적 동의의 대상이 되는 노동자의 범위는 변경된 취업규칙의 적용을 받게 될 노동자 집단의 과반수를 말하는 것이기에 취업규칙의 변경으로 인해 받을 불이익이 없는 노동자의 동의까지 필요로 하는 것은 아니다. 따라서 전체 노동자 과반수의 동의를 받았다 하더라도 직접적으로 그 취업규칙 변경 내용의 적용 대상이 되는 노동자 집단의 과반수 동의가 없다면 변경된 취업규칙을 적용할 수 없다.

"…사원과 노무원으로 이원화된 개정 퇴직금규정이 개정 전의 그것보다도 퇴직금 지급일수의 계산 및 퇴직금 산정 기초임금의 범위에 있어 근로자에게 불리하게 변경된 경우에는 이에 관하여 종전 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자집단의 동의가 있어야 유효하다고 할 것인바, 노동조합원인 총 근로자 중 85%가 넘

195)대법원 1990.11.27. 선고 89다카15939 판결.
196)조득주, 앞의 논문, 91면.
197)대법원 1994.5.10. 선고 93다30181 판결.

는 수를 차지하는 노무원이 퇴직금개정안에 완전히 동의하였다 하더라도 개정 퇴직금규정이 노무원에 대한 부분에 국한하여 효력이 있는 것 일뿐, 개정에 동의한 바 없는 사원에 대한 부분은 효력이 없다.…"[198]

다만 이 같이 노동자 집단 과반수의 동의를 구해야하는 것은 취업규칙이 노동자에게 불리하게 변경하는 경우로 한정해서 보아야할 것이고, 사용자가 취업규칙을 최초로 작성할 때나 노동자에게 불리하게 변경하는 것이 아닐 때에까지 확장하여 노동자의 동의를 구해야한다고 볼 수는 없다.

3. 묵시적 동의와 소급적 동의의 효력

또 다른 예로 취업규칙의 불이익한 변경에 있어 사용자가 노동자에게 불이익한 변경의 내용에 대한 동의를 구했을 당시 노동자 측에서 별다른 이의 제기를 하지 아니하는 등의 경우에는 묵시적 동의를 한 것으로 인정될 수 있는지 생각해 볼 수 있다.

하지만 우리 「근로기준법」 제94조 제1항에 따르면 취업규칙의 불이익한 변경 시에는 노동자 과반으로 구성된 노동조합의 대표자의 동의나 개별 근로자 과반수의 동의를 구해야 한다. 이는 적극적 형태를 띈 집단적 의사결정 방법에 의하여야만 인정받을 수 있는 것으로 사실상 묵시적 동의가 인정될만한 요소는 존재하지 않는다고 판단되며 이는 판례의 입장과도 같다.

"…근로조건에 관한 규정과 기타 사규 변경시 회사에서 노동조합에 이를 통지하기로 협의한 사실, 이에 따라 1993. 3. 31. 피고 회사 총무국장이 노동조합에 개정 보수규정의 내용을 통지한 사실 및 이에 대하여 노동조합이 별다른 이의를 제기하지 아니한 사실은 인정되나, 이러한 사정만으로는 종전 급여규정의 개정에 대하여 근로자의 과반수로 구성된 피고 회사 노동조합이 묵시적으로 동의한 것이라고 보기는 어려우며, 또한 개정 보수규정의 시행 전에 퇴직한 근로자 40명 중 36명이 특별상여금 200%를 제외하여 산정된 퇴직금을 수령하고서도 이의를 제기

198)대법원 1990.12.7. 선고 90다카19647 판결.

하지 아니하였다는 사정이 있다 하더라도 이러한 점만으로는 종전 급여규정에서 말하는 "평균 월급여"에 특별상여금이 제외된 것이라거나 혹은 이를 제외하기로 하는 묵시적 합의나 관행이 있었다고 보기는 어렵다…"[199]

이어 노동자들이 취업규칙의 불이익한 변경 진행 당시에는 동의를 하지 아니하였다가 추후 사전 동의 없이 개정되었던 취업규칙에 동의하게 되는 경우 발생하게 되는 소급적 동의의 유효성 문제에 대해 생각해볼 필요가 있다.

통상의 경우 유 · 불리 측면의 변경 여부를 떠나 변경된 취업규칙은 장래를 향해 그 효력을 발하게 되는 것이 일반적이다. 그러나 취업규칙이 불이익하게 변경될 당시 그 변경의 내용을 과거의 일정 시점으로 소급하여 적용시키겠다는 것에 동의하는 것이거나, 취업규칙의 불이익한 변경이 동의 없이 이루어진 이후에 비로소 동의하게 되어 불이익한 개정이 이루어진 당시로 동의의 효력을 소급시키게 되는 결과를 불러오는 경우가 발생하기도 한다. 판례는 이 경우에도 취업규칙의 변경절차가 적법하게 이루어 졌다고 인정하여 변경 된 취업규칙에 효력을 부여한다.

"…동의의 방법은 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 조합의 그와 같은 조합이 없는 경우에는 근로자들의 회의방식에 의한 과반수의 동의가 있어야 하며, 위와 같은 방법에 의한 동의가 없는 한 그 취업규칙의 변경은 효력을 가질 수 없다고 할 것이나, 그와 같은 방법에 의한 동의나 합의가 있는 한 근로자 개개인의 동의를 얻을 필요 없이 그 취업규칙의 변경은 유효하다고 할 것이고, 이는 취업규칙의 변경에 의하여 기존의 근로조건이나 근로자의 권리를 소급하여 불이익하게 변경하는 경우에도 마찬가지라고 보아야 할 것…"[200]

"…퇴직금지급규정을 개정하면서, 피고 공단 소속 직원들의 의견청취나 동의절차 없이 다만 이사회의 의결만을 거친 후 상공부의 승인을 얻어 그때부터 개정된 퇴직금지급률에 따라 계산된 퇴직금만을 퇴직자에게 지급해 오고 있는 사실, 그 후 피고 공단 근로자들은 1988.12.21. 과반수 이상이 가입하고 있는 노동조합을 설립하여 피고 공단과의 사이에 1989.4.15.자로 단체협약을 체결하면서, 그 협약

199)대법원 2000.9.29. 선고 99다45376 판결.
200)대법원 1994.5.24. 선고 93다46841 판결.

제4조에서 피고 공단은 이미 실시하고 있는 근로조건을 어떠한 명목으로도 저하시킬 수 없다고 규정하면서 나아가 그 경과규정으로 부칙 제4조에서 위 단체협약 시행일 이전에 발생한 모든 사항을 위 협약에 의한 것으로 본다는 규정을 두고, 그때부터 위 단체협약의 규정이 피고 공단 직원들에게 적용·시행되어 온 사실 등을 인정한 다음, 피고 공단 노동조합이 위 단체협약부칙 제4조의 규정을 둔 것은, 피고 공단이 설립된 이후 위 단체협약 체결시까지 사이에 노사관계에서 발생하였던 근로조건 등의 모든 사항에 관하여 노동조합이 그 효력을 소급적으로 승인하는 취지라고 보여지는바, 위 단체협약에서 특별히 퇴직금지급률의 변경을 위한 위 1982.4.29.자 취업규칙의 개정에 관한 사항을 배제하는 내용의 규정을 두지 않았으므로 노동조합은 위 단체협약에 의하여 퇴직금지급률의 변경에 관하여도 소급적으로 동의한 것으로 해석하여야 할 것이고…"[201]

이처럼 소급적 동의 · 승인 · 추인 등의 의사표시의 결과로 취업규칙의 불이익한 변경이 적법한 변경의 효력을 갖기 위해서는 동의 당시의 노동자 또는 노동조합이 대상 취업규칙이 과거에 동의 없이 불이익하게 변경된 것이라는 점을 분명히 인식하고 이를 전제로 하여 불이익변경에 동의한다는 뜻으로 동의의 의사표시를 해야 한다.[202] 만일 이러한 사정을 모르고 단순히 동의 당시 시행 중인 규정이 유효한 것으로 여겨 이를 그대로 유지하는 것 정도로 생각하여 규정의 개정에 동의를 한 것이라면 소급적 동의의 의사표시로 볼 수 없어 동의의 효력이 부정된다.

"…1981.1.27.자 보수규정의 개정이 무효라는 사실자체를 모르고 있었기 때문에 위 규정의 추인이 거론될 여지가 없다가, 1980년대 말에 한국도로공사나 대한주택공사 등 정부투자기관이 1981년경에 한 취업규칙의 개정이 무효라는 판결이 나오자 비로소 피고 공사나 근로자들이 피고공사의 1981.1.27.자 보수규정이 무효인 사실을 알게 되어 1989.12.에 단체교섭을 하면서 이를 거론하게 된 사실을 인정할 수 있다. 또한 노동조합이나 근로자들이 위 단체협약체결당시 그때 시행중이던 보수규정이 유효하다고 여기고 있었던 사실만으로써 위 무효인 1981.1.27.자 보수

201)대법원 1993.3.23. 선고 92다52115 판결.
202)사법연수원(1999), 『해고와 임금』, 사법연수원, 229면.; 정진경, 앞의 책, 28면에서 재인용.

규정의 개정을 추인하였다고 볼 수는 없는 바이다…”[203]

다만 이러한 경우에도 노동자들이 취업규칙의 개정 당시 기존의 개정된 취업규칙상의 일부 규정이 동의 요건의 흠결로 인해 효력에 문제가 있어 이를 보완하고자 하는 뜻으로 동의를 구한 것이라는 사정을 알고 이에 동의한 것이라면 동의의 효력이 부정되지 않는다.

“…현행 퇴직금제도가 유효한 것으로 알고 이를 그대로 유지하는 것으로만 생각하여 위 취업규칙 개정안에 동의한 것이라면 기존의 근로조건의 불이익한 변경에 대한 동의의 의사표시라고 보기 어려움은 원심이 지적하는 바와 같다. 그러나 기록에 의하면 과거에 피고 회사로부터 퇴직한 일부 근로자들이 단수제의 현행 퇴직금제도(1972.1.1.자 개정)는 개정시에 적법한 근로자들의 동의를 받지 못하여 무효라는 이유로 그 전의 누진제에 의한 퇴직금청구소송을 제기하여 승소판결을 받아 대법원에서 확정된 사건이 여러 건 있었으므로 피고로서는 근로자들의 동의를 받음으로써 현행 퇴직금 제도를 유효화 시키고자 위 1987.4.1.자 개정안에 퇴직금부분을 포함시킨 사정이 엿보이는바, 근로자들이 위와 같은 사정, 즉 현행 퇴직금제도의 효력에 문제가 있어 이를 보완하는 뜻으로 동의를 구하는 것이라는 사정을 알면서 이에 동의한 것이라면 이러한 동의의 효력을 부인할 것이 아니므로…”[204]

4. 단체협약의 변경으로 인한 취업규칙의 불이익 변경

취업규칙의 불이익한 변경은 비단 개별 노동자 과반수의 동의 또는 노동자 과반수로 구성된 노동조합의 대표자의 동의로만 변경될 수 있는 것은 아니다. 사업장에 노동자 과반수로 구성된 노동조합이 있다면 그 사업에 적용되는 단체협약과의 관계 속에서 취업규칙은 얼마든지 불이익한 변경에 따른 동의 없이도 불이익하게 변경될 수 있다. 물론 단체협약제도의 취지가 「헌법」상 권리인 노동3권을 실질적으로 보장하

203)대법원 1992.9.14. 선고 91다46922 판결.
204)대법원 1992.2.25. 선고 91다25055 판결.

기 위함이고 근로조건의 향상과 노동자들의 보호에 있다는 것은 명백한 사실이다. 그리고 협약자치제도 역시 노동자의 근로조건 개선과 사회적 · 경제적 지위향상을 목적으로 한다는 데에도 이의가 있을 수 없다.

그러나 학설은 단체협약제도가 시장경제체제하에서 기업경쟁력의 경제적 능력범위를 벗어나 마냥 유리하게만 기능을 할 수는 없다는 점에서 그 보호 기능의 한계가 있어 불이익하게 변경되는 것에 대해서도 용인이 가능하다는 입장이고,[205] 판례의 입장도 그것에서 크게 벗어나지 않는다.

> "…협약자치의 원칙상 노동조합은 사용자와 사이에 근로조건을 유리하게 변경하는 내용의 단체협약뿐만 아니라 근로조건을 불리하게 변경하는 내용의 단체협약을 체결할 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 그러한 노사 간의 합의를 무효라고 볼 수 없고 노동조합으로서는 그러한 합의를 위하여 사전에 근로자들로부터 개별적인 동의나 수권을 받을 필요가 없으나, 근로조건을 불리하게 변경하는 내용의 단체협약이 현저히 합리성을 결하여 노동조합의 목적을 벗어난 것으로 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 그러한 합의는 무효라고 보아야 하며, 이때 단체협약이 현저히 합리성을 결하였는지 여부는 단체협약의 내용과 그 체결경위, 협약체결 당시의 사용자 측의 경영상태 등 여러 사정에 비추어 판단하여야 한다…"[206]

이러한 연유로 단체협약을 체결하면서 부칙 등에 취업규칙의 불이익 변경을 승인하는 경과규정을 둔다거나 단체협약에 일정한 근로조건에 관한 사항은 취업규칙의 내용에 따른다는 인용조항을 두는 방법, 단체협약에서 불이익하게 변경된 취업규칙의 규정과 동일한 내용의 조항을 직접 두는 방법 등 여러 형태로써 취업규칙에 영향을 주는 단체협약의 변경이 다양하게 나타나고 있다. 이 경우 불이익한 변경이 현저하게 합리성을 결여하지 않았다면 원칙적으로 그 효력을 인정받게 된다.[207]

> "…노동조합으로서는 사용자가 일방적으로 변경한 임금, 근로시간, 퇴직금 등

---

205)김형배, 앞의 책, 1085면.; 임종률, 앞의 책, 158면.
206)대법원 2011.7.28. 선고 2009두7790 판결.
207)정진경, 앞의 책, 23면.

근로조건의 기준에 관하여 소급적으로 동의하거나 이를 승인하는 내용의 단체협약을 체결할 수 있고, 그 근로조건이 퇴직금인 경우에 그 퇴직금 지급기준은 장래의 근속기간에 대해서 뿐만 아니라 기왕의 근속기간에 대해서까지 적용된다는 것(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다34073 판결)이거나, 취업규칙의 하나인 퇴직금 규정이 기존의 근로자에게 불리하게 변경됨으로써 기득이익을 침해하는 경우라도 노동조합의 동의나 노동조합과 사용자 사이의 합의가 있는 한 근로자 개개인의 동의가 없어도 그 퇴직금 규정의 변경은 유효…"[208]

또한 유리의 원칙을 적용하여 단체협약 보다 유리한 조건의 취업규칙의 내용을 불이익하게 변경된 단체협약의 내용으로 저하시키는 것을 부정할 수 있는가하는 점에 대해서도 생각해 볼 수 있다. 유리의 원칙이란 근로조건을 규율하는 규범에 상 · 하위규범이 있을 때 원칙적으로 하위규범에 정한 조건이 상위규범에 위반되면 그 효력은 무효가 되고 하위규범이 상위규범보다 노동자에게 더 유리한 근로조건을 정하고 있는 경우 유리한 하위규범을 우선 적용한다는 원칙을 말한다.

유리의 원칙의 적용을 부정하는 견해는 단체협약 자치의 원칙상 노동조합의 구성원인 노동자 개개인이 단체협약의 집단적 규율에 따라야하는 것은 그 자유의사에 따라 사적 자치의 원칙에 의한 계약 자유를 스스로 제약하였으므로 당연한 결과이고, 만일 유리의 원칙을 인정할 경우 노동조합을 통한 단결권이나 단체교섭권이 상당부분 침해 될 위험이 있다고 주장한다. 반면, 유리의 원칙을 전면적으로 긍정하는 견해는 단체협약은 근로조건의 최저기준을 정한 것으로 근로계약이 단체협약보다 유리할 경우 단체협약의 강행적 효력은 부정된다고 주장하며, 마지막으로 절충적 견해는 단체협약과 근로계약 사이의 유리 원칙을 인정하는 것은 근로자 개개인의 행복추구권 관점에서 인정하되, 취업규칙이나 노동관행 등과 같이 노동자에 대한 집단적 규율을 목적으로 하는 경우에 대해서는 유리의 원칙을 배제해야한다는 입장을 견지한다.[209]

하지만 우리나라의 경우 기업별 단체협약이 지배적이므로 단체협약상의 기준은 표준적인 근로조건으로 작용하고 있다. 이는 노동자가 노동조합에 가입해 스스로 일정

208)대법원 2000.9.29. 선고 99다67536 판결.

209)이광선(2016), <취업규칙과 단체협약과의 관계>, 법무법인 지평 노동 뉴스레터, 2016년 4월 제1호, 3면.

한 범위에서 계약의 자유를 제한하였다고 볼 수 있는 것으로, 만일 개별조합원에 대해 사용자와의 근로조건에 대한 개별교섭을 허용한다면 노동조합의 단결권과 단체교섭권이 상당부분 침해될 소지가 있어 명문 규정에도 없는 유리의 원칙을 인정하기에는 다소 무리가 따른다.[210]

그렇다면 판례의 입장을 살펴볼 필요가 있는데, 우리 법원은 유리의 원칙은 노동자 개인의 개별 약정에 의한 근로계약에서 문제되는 것으로 취업규칙에 대해서는 노동자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 동의를 얻어 취업규칙을 노동자에게 불이익하게 변경할 수 있으므로 노동조합이 단체협약을 체결하면서 기존의 취업규칙에 정한 근로조건보다 불리한 내용의 근로조건의 기준을 정함으로써 취업규칙을 변경하는 것은 위 법규정에 의해 허용되는 것으로[211] 볼 수 있고 이러한 한도 안에서 취업규칙과 단체협약 사이의 유리의 원칙은 입법에 의해서 배제되어있다고 보아 사실상 유리의 원칙을 배제시키는 입장이다.[212]

이 같은 점에 있어서 또 다른 한편에서는 노동조합은 근로조건의 유지 · 개선을 목적으로 하여야 한다는 점을 강조하면서 근로조건을 노동자에게 불이익하게 변경하는 것은 협약자치의 한계를 넘는 것으로 허용되지 않는다고 보는 견해도 있지만,[213] 이는 크게 지지 받지는 못한다.

5. 동의절차 위반의 효과

취업규칙의 작성과 변경권이 사실상 사용자에게 있다 하여도 취업규칙의 변경으로 인해 발생될 결과가 기존보다 노동자에게 불리하게 작용하는 것이 예상될 경우 그 적용을 받게 될 노동자 집단의 사전 동의를 구해야 함을 정해두고 있는 것은, 취업규칙이 가지고 있는 편무성을 「근로기준법」이 강행규정으로 다소나마 해소시키기

210)김유성(2001), 「노동법Ⅱ」, 법문사, 159면.; 정진경, 앞의 책, 43면에서 재인용.

211)대법원 1992.7.24. 선고 91다34073 판결.; 대법원 1993.3.23. 선고 92다51341 판결.; 대법원 1997.8.22. 선고 96다6967 판결 등.

212)이홍재 · 남효순(2002), 『노동법강의 — 기업구조조정과 노동법의 중요과제』 서울대학교 법과대학 전문분야 연구과정 제7권, 법문사. 66면.

213)홍준호(1999), 「근로조건의 저하에 관한 고찰」, 『인권과 정의』 통권276호, 대한변호사협회, 53-54면.; 정진경, 앞의 책, 48면에서 재인용.; 임종률, 앞의 책, 158면 주3) 참조.

위한 목적을 가지고 있는 것으로 이해된다.

이처럼 취업규칙의 불이익한 변경에 대한 동의 조건은 '효력요건'에 해당하므로, 노동자의 과반수 동의를 받았다면 그로 인해 변경된 취업규칙은 동의하지 않은 노동자에게까지 구속력이 미치게 되지만, 동의 과정을 거치지 않거나 대상 노동자 과반수의 동의를 얻지 못하였다면 원칙적으로 효력이 없는 것으로 본다.[214] 즉, 취업규칙의 불이익한 변경에 노동자 과반수의 동의를 얻지 못하였다면 그와 같은 불이익한 변경의 내용은 기득이익을 가지고 있는 노동자에게는 구속력을 갖지 못함은 당연하고, 그러한 내용에 동의한 노동자에게도 아무런 영향을 미치지 못한다.

"…원칙적으로 취업규칙의 작성변경권은 사용자에게 있다 할 것이나 취업규칙의 변경에 의하여 기존 근로조건의 내용을 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하려면 종전 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자 집단의 집단의사결정 방법에 의한 동의를 요한다고 할 것이며 그 동의방법은 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 조합의 그와 같은 조합이 없는 경우에는 근로자들의 회의방식에 의한 과반수의 동의가 없는 한 취업규칙의 변경으로서의 효력을 가질 수 없고 따라서 그러한 취업규칙변경에 대하여 개인적으로 동의한 근로자에 대하여도 효력이 없는 것이라고 할 것이다. 왜냐하면 기존근로조건의 내용을 사용자가 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하는 것은 위의 근로기준법의 보호법으로서의 정신과 기득권 보호의 원칙 및 근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 의하여 결정되어야 한다는 근로기준법 제3조의 규정상 허용될 수 없다 할 것이고…"[215]

"…취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에 해당하여 노동조합 또는 근로자 과반수의 동의를 얻어야 하고, 동의를 얻지 않은 경우에는 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자에 대한 관계에서는 변경의 효력이 미치지 않게 되어 종전 취업규칙의 효력이 그대로 유지된다고 할 것…"[216]

---

214)이 정 · 박종희 · 하갑래(2009), 「취업규칙 분석 및 제도개선 방안 연구」, 『노동부 정책연구사업 보고서』, 110면.
215)대법원 1977.7.26. 선고 77다355 판결.
216)법제처 2006.12.01. 06-0280 법령해석 참조.

또한 취업규칙의 개정 내용 중 일부 조항이 무효의 변경으로 판단되는 경우, 이것을 각 항목별로 노동자들에게 유리하게 적용되는 것과 불리하게 적용되는 것을 판단하여 각각 유효와 무효로 구분되어 질 수 있는 것이 아니고 일부 조항만이 무효일지라도 무효인 조항과 대가성과 연계성이 있다고 판단되는 항목은 모두 무효가 된다.

> "…무효의 변경으로 되는 경우에 그 유, 불리한 각 항목에 따라 각각 그것이 유·무효로 되는 것이 아니고 위에서 본 대가성이나 연계관계에 있는 항목 모두가 무효로 되는 것이라고 할 것이고, 또한 위와 같이 퇴직금의 지급에 관한 취업규칙의 개정이 무효로 된 이상 그 이후 개정된 퇴직금의 지급에 관한 규정은 그 지급률 및 기초임금에 관한 부분 모두 그것이 앞서 무효로 된 퇴직금 규정을 추인한 것이거나 또는 그 규정과는 연계관계 없이 전혀 별도의 차원에서 변경되어 새로운 퇴직금 규정을 제정한 것으로 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 모두 무효로 되는 것이라고 보아야 할 것이다.…"[217]

Ⅳ. 불이익한 변경의 예외로서 사회통념상 합리성의 판단

우리 법원은 판례에서 취업규칙의 불이익한 변경의 예외 사유로서 '사회통념상 합리성'을 들고 있다. 따라서 구체적 사안을 판단하기에 앞서 대체 사회통념상 합리성이 무엇을 뜻하는 것이기에 취업규칙을 불이익하게 변경함에 있어 사전에 노동자 집단의 동의를 구해야만 한다는 것이 「근로기준법」에 명시적으로 규정되어 강행적 효력 요건으로 구비되어 있음에도 이에 대한 예외로 취급할 수 있는 것인가를 먼저 파악하고 개념적 정의를 확인해볼 필요성이 요구된다.

사회통념상 합리성은 '사회'와 '통념' 그리고 '합리성'의 세 가지 단어로 구성 되어 있다. 각각 사전적 의미를 찾아보자면 '사회'는 "같은 무리끼리 모여 이루는 집단."을 뜻하는 것으로서, "공동생활을 영위하는 모든 형태의 인간 집단. 가족, 마을, 조합, 교회, 계급, 국가, 정당, 회사 따위가 그 주요 형태"라고 정의되어 있다. 두 번째로

217)대법원 1995.3.10. 선고 94다18072 판결.

‘통념’은 “일반적으로 널리 통하는 개념.”으로 정의 되고, 마지막으로 ‘합리성’은 “이론이나 이치에 합당한 성질.”이라 정의 된다.[218]

각각의 정의를 다시 종합하여 보자면, 사회통념상 합리성이란 같은 무리끼리 모여 이루고 있는 집단 속에서 일반적으로 널리 통하고 있는 개념으로서 이론이나 이치에 합당한 성질을 가지고 있는 것을 의미한다고 정의해볼 수 있으며 추상적 성격을 띠고 있는 것으로 정리할 수 있다.

그렇다면 과연 이 같은 추상적 개념으로서 사회통념상 합리성을 재판상의 규범으로 다룰 수 있는 것인지 우리 판례와 행정해석 등의 입장을 살펴볼 필요가 있다.

<표1. 판례가 제시하고 있는 사회통념상 합리성의 판단 기준>

판례는 사회통념상 합리성의 판단기준으로 다음과 같은 사항을 제시한다.
<대법원 1999.11.18. 선고 98나2893 판결.>

① 노동자가 입게 되는 불이익의 정도
② 사용자측의 취업규칙 변경 필요성의 내용과 정도
③ 변경 후 내용의 상당성
④ 대상 조치 등을 포함한 다른 근로조건의 개선 상황
⑤ 노동조합 등과의 교섭 경위와 다른 노동조합이나 다른 근로자의 대응
⑥ 동종 사항에 관한 국내 일반적인 상황

그밖에도 최근에 들어서는 판단기준을 확장해 아래와 같은 사항까지 고려의 대상에 넣고 있다. <대법원 2015.8.13. 선고 2012다43522 판결.>

⑦ 실질적으로는 근로자에게 불리하지 아니하는 등 근로자를 보호하려는 근로기준법의 입법취지에 어긋나지 않는지 여부
⑧ 취업규칙 변경에 따라 발생할 경쟁력 강화 등 사용자 측의 이익 증대 또는 손실 감소를 장기적으로 노동자들도 함께 향유할 수 있는지에 관한 기업의 경영 행태
⑨ 변경 전, 후의 문언을 기준으로 불리한 변경 여부를 판단하였는지 여부

출처 : 대법원 1999.11.18. 선고 98나2893 판결과 대법원 2015.8.13. 선고 2012다43522 참고하여 재정리.

우리 법원은 ‘대법원 1978.9.12. 선고 78다1046 판결’에서 “피고조합이 종전 취업규

218)국립국어원 표준국어대사전 참조. <http://stdweb2.korean.go.kr/>

칙의 적용을 받던 근로자 집단의 동의 없이 일방적으로 그 취업규칙을 변경하여 직원의 정년을 만 55세로 하고 정년에 달한 때에는 해직하여야 한다는 내용의 규정을 새로이 두었으나, 그 정년을 위와 같이 만 55세까지로 정한 것이 사회의 일반 통례에서 벗어난 불합리한 제도라고 볼 수 없는 것이므로, 위 정년제의 신설이 원고 등 근로자의 기존근로조건상의 기득권을 침해하는 근로조건 변경이라고 단정할 수는 없으며"라고 하여 '사회의 일반통례'를 적용한 이후 꾸준히 "사회통념상 합리성의 유무는 취업규칙의 변경에 의하여 근로자가 입게 되는 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후의 취업규칙 내용의 상당성, 대상조치 등을 포함한 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭 경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 대응, 동종 사항에 관한 국내의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단" 하여야 한다고 하여, '사회적 합리성설(객관적 기준설)'의 입장을 취하고 있다.[219]

반면, '대근로자 불이익설(주관적 기준설)'에 따르면 취업규칙의 변경이 사회통념상의 합리성을 가졌는지는 불문으로 하고 실질적으로 노동자에게 불리한 조건이라면 노동자 과반의 동의를 얻어야 한다고 보는 입장이다. 이는 「근로기준법」 제94조 제1항의 취지가 사용자 일방이 근로조건을 일방적으로 저하하는 것을 방지하는데 있다는데서 의미를 찾아야 한다는 것이다.[220] 따라서 본고의 논의를 이끌어가는 입장에서 보자면 후설이 좀 더 합리적이라고 보인다.

물론 사용자가 사업장을 운영하다보면 시대의 흐름에 따라 경제적 여건이나 경영의 환경이 변화하고 그에 맞추어 기존의 근로조건을 변경해야 할 필요성이 필연적으로 요구 될 때가 있을 것이라는 점은 비단 사용자가 아니라 할지라도 어렵지 않게 유추할 수 있다. 그러나 이 같은 필요성이 객관적으로 주어진다 할지라도 근로조건을 사용자가 일방적으로 결정하는 것이 아닌 노동자 과반수의 동의를 통해 변경하도록 유도함으로써, 「근로기준법」 제4조에서 정하고 있는 근로조건의 대등결정 원칙이 준수될 수 있도록 한다는 것에서 노동자 과반수 동의의 본질적 역할이 있다고 본다.[221] 하지만 여전히 우리 법원은 취업규칙이 불이익하게 변경될지라도 사회통념상

219)대법원 2001.1.5. 선고 99다70846 판결,; 2002.6.11. 선고 2001다16722판결,; 1978.9.12. 선고 78다1046 판결,; 2010.1.28. 선고 2009다32362 판결,; 노동부 1993.7.1. 근기 01254-1434 행정해석 참조.

220)이병태, 앞의 책, 1037면.

221)김 훈 · 박종희 · 김정우(2011), 「종업원대표제도 개선방안 연구」, 『정책연구』 2011-01, 한국노

의 합리성을 갖춘다면 노동자 과반수 동의를 받지 않아도 된다는 입장을 견지한다.

이는 일본 최고재판소가 1968년에 '슈보크버스 사건(秋北バス事件)'과 1997년에 '다이시은행사건「第四銀行事件」'에서 판시했던[222] 취업규칙의 불이익한 변경 판단 기준을[223] 그대로 답습한 것으로 판단된다.[224]

<표2. 일본 최고재판소의 사회통념상 합리성 판단 기준>

일본의 최고재판소는 합리성 판단과 관련하여 취업규칙의 변경 시 그 변경의 내용과 필요성의 양 측면을 고려해야 한다고 하면서 다음의 여섯 가지를 판단의 기준으로 제시 하고 있다.

① 변경에 의하여 종업원이 입게 될 불이익의 정도
② 변경과 관련해서 행해지는 임금의 개선방안
③ 사내규유의 유지 또는 종업원의 공평한 처우를 위해서 변경이 필요한 것인가의 여부
④ 노동조합과의 교섭의 경위
⑤ 다른 종업원들의 반응
⑥ 관련 사업체의 규정 등의 사항

출처 : 日本 最大判 昭和 43.12.25., 民集 22券 13號, 最高裁判 昭和 58.11.25.; 最高裁判 昭和 63.2.16. 참조.

하지만 실질적으로 우리 법원의 합리성의 판단 구도는 막상 일본의 그것과도 조금의 차이를 보이고 있다. 일본의 판단구도는 '노동자에게 불이익한 변경인가'와 '그렇더라도 그것이 제3자 관점에서 인용될만한 것인가'라는 2단계 판단구도를 사용하고 있는 반면에 우리는 '제3자 관점에서 보아 인용될만한 것이라면 노동자에게 불이익한 것이 아니다.'라는 1단계 판단구도로 통합한 것이라는 견해가 있다. 이것은 예를 들어 '어떤 사업장의 근로조건이 동종 산업의 평균치를 넘어서 있는 경우 그 근로조건의 하향평준화를 보다 쉽게 정당화하게 할 수 있는 것'과 같이 보다 용이하게 사

동연구원, 33면.

222)일본에서는 2008년에 이르러 노동계약법 제9조, 제10조 등에서 사회통념상 합리성의 법리를 명문화하게 되기 이전까지는 노동기준법에서 취업규칙의 불이익변경에 대한 요건을 규정되어 있지 않은 가운데 판례가 일찍부터 노동자의 동의 없이 노동자에게 불이익하게 변경된 취업규칙이라 하더라도 그 내용이 사회통념상 합리적이라면 유효하다고 보아왔다. 임종률, 앞의 책, 364면.

223)김형배, 앞의 책, 308-309면.

224)이 정(2015), 「임금피크제의 도입과 취업규칙의 불이익 변경」, 『노동시장 개혁의 주요 쟁점 점검 -해고제도, 취업규칙변경을 중심으로-』, 한국경제연구원, 29면.

회통념상의 합리성을 인정하게 되는 논리구도에 해당한다. 다시 말하자면 사회통념상의 합리성 여하가 노동자에 대한 불이익성이 인정된 이후 단계에서 비로소 문제로 되는 일본과는 달리 우리나라의 경우에는 불이익변경의 해당성에 대한 판단 그 자체와 결부되고 있다는 점에서 차이를 보이는 것이다. 하지만 이러한 독특한 논리구도를 취하게 된 근거는 밝혀져 있지 않다는 문제를 안고 있다.[225]

또 우리나라 「근로기준법」 제94조 제1항 단서와는 달리 일본은 노동기준법에 취업규칙의 작성 또는 변경 절차에 대해 노동자 대표의 의견청취 조항만을 두고 있을 뿐, 취업규칙의 불이익한 변경에 대하여 근로자들의 집단적 동의를 효력요건으로 하는 판례나 법 규정이 존재하지 않는다. 따라서 판례를 통해 편무성의 단점을 해소하기 위한 법리가 발전되어 왔던 측면이 있다.[226] 오히려 2008년에 제정 · 시행된 노동계약법은 취업규칙의 불이익 변경이 제반 사정에 비추어 합리성이 있는 한 유효하다는 예외적 규정을 두고 있을 뿐이며,[227] 판례가 취업규칙의 법적 성질에 대해 정형계약설을 취하기 때문에 노동자에 불리하게 변경된 취업규칙의 효력은 노동자의 동의 유무와 관계없이 변경의 합리성 유무에 따라 결정된다는 결론에 도달할 수 있는 것이다. 이렇듯 법 규정부터가 다른 일본의 법해석상 합리성 이론을 그대로 수용하는 것은 타당치 않다.[228]

당초 사회통념상의 합리성을 주장하는 우리 판례의 입장은 취업규칙 변경 시 노동자들의 의견청취만을 요건으로 하였던 개정이전의 「근로기준법」하에서는[229] 사용자의 일방적인 취업규칙의 불이익 변경을 방지하고 취업규칙을 통일적으로 적용하는데 큰 기여를 했다는 평가도 있다.[230] 그러나 「근로기준법」의 개정으로 인해 현행 제94조 제1항 단서에서 노동자의 집단적 동의요건을 명시적으로 규정하고 있는 이상,[231] 훈시규정이 아닌 효력규정이자 강행규정의 성격을 띠는 것으로 보아야하기에

225)최영호, 앞의 책, 172-173면.
226)하갑래, 앞의 책, 167면.
227)김형배, 앞의 책, 310면.; 일본은 '노동계약법에 근로자와 합의하지 않고 일방적으로 취업규칙을 변경하여서는 안되지만, 근로자에게 불이익하게 변경된 취업규칙이 근로자가 받는 불이익의 정도, 변경의 필요성, 변경된 취업규칙 내용의 상당성, 노동조합 등과의 교섭 상황, 그 밖에 변경과 관련된 사정에 비추어 합리적인 경우 근로자의 동의가 없더라도 유효하다고 규정하고 있다.' 임종률, 앞의 책, 364면.
228)이병태, 앞의 책, 1040면.
229)[시행 1989.3.29.] [법률 제4099호, 1989.3.29., 일부개정] 이전의 것.
230)김형배, 앞의 책, 308-309면.

현재의 판례 입장은 수정되어야 함이 보다 적합하다.

한편 우리 판례가 사회통념상 합리성을 논할 때의 모습을 예전과 비교해보면 판결문의 결론 측면에서는 비슷할지 모르지만 접근 방식에 있어서는 확연한 차이가 있는 것을 확인할 수 있다. 사회통념상의 합리성을 판례에서 언급하던 초창기에는 그 기준점을 노동자에게 불리한 변경에 해당하는가의 여부를 판가름하는 잣대로 사용했던 것으로, 주로 취업규칙의 불이익 변경이 사회통념상 합리성을 들어 제한되는 측면이 강한 상황이었다.

> "…결근은 본질적으로 근무태만이나 회사의 복무규정 위반행위로서 징계사유와 다를바 없어 사용자의 일방적인 사실인정만으로 자연면직된다는 것은 불합리하고 근로자에게 불이익한 근로조건이므로, 이러한 조항을 근로자측의 동의도 없이 새로이 취업규칙에 규정하는 것은 사회통례상 합리성이 있는 것으로 보기 어렵다.…"[232]

하지만 최근 들어서 사회통념상 합리성을 언급하는 판례의 모습은 예전과는 달리 취업규칙 변경의 내용이 노동자에게 불이익한 근로조건을 담고 있는 것 일지라도 사회통념상 합리성이 있다면 노동자의 동의가 필요 없다는 논리로 변화되고 있다.

> "…법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수는 없다고 할 것이고…"[233]

> "…당해 취업규칙의 작성 또는 변경이 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 그에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 여전히 당해 조항의

231)이러한 입법은 우리와 유사한 구조의 취업규칙제도를 가지고 있는 일본과 비교해 보았을 때 노사가 대등한 위치에서 근로조건을 결정해야한다는 점에 비추어 진일보한 입법태도로 평가 된다. 정인섭(2004), 「취업규칙의 불이익변경과 집단적 동의의 방법」, 『노동법연구』 제17호, 서울대학교 노동법연구회, 306면.; 같은 취지의 의견으로 정영훈(2009), "우리나라와 매우 유사한 취업규칙 법제를 가지고 있는 일본과 비교해 볼 때에 독특한 것"이라고 평가한다., 「취업규칙의 불이익변경에 관한 일고찰 -절차심사와 내용심사의 보강의 당위성과 가능성을 중심으로-」, "한국노동법학회 · 울산대학교 사회과학연구소 공동 학술 세미나", 35면.

232)대법원 1989.5.9. 선고 88다카4277 판결.

233)대법원 2001.1.5. 선고 99다70846 판결.

법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그의 적용을 부정할 수는 없다…”[234]

이를 ‘창과 방패’의 관계로 비유하자면, 최초에는 사회통념상 합리성이 없다면 불이익하게 변경해서는 안된다고 노동자 입장에서의 일정한 ‘방패’ 역할을 해주는 입장이었지만, 현재에는 사회통념상 합리성이 있다면 불이익하게 변경해도 괜찮다는 사용자 입장에서 일종의 ‘창’의 역할로 변경되었다고 볼 수 있다.

만일 이 같은 변화가 기업의 경쟁력 유지와 다양한 취업형태의 필요성에 따라 그에 대응하기 위해서 노동법제 유연화를 목적으로 하여 취해지는 것이거나, 취업규칙의 불이익한 변경이 제반 사정상 필연적이고 그 내용이 합리적임에도 불구하고 노동자들이 기대이익에 집착해 변경에 동의하지 않으려는 경향으로 인한 것으로 대처가 필요한 것이라면 입법을 통해 해결해야할 문제로[235] 보인다. 따라서 효력규정이자 강행규정인 「근로기준법」 제94조 제1항의 노동자의 집단적 동의를 배제하고 유효요건을 몰각시키면서까지 사회통념상 합리성이론을 적용해 해결할 문제가 아니다.

「근로기준법」이 사용자 일방에게 취업규칙의 작성권한을 부여하고 있는 것을 감안해 볼 때 근로자 과반수의 동의를 취업규칙의 불이익한 변경 요건으로서 규정하고 있다는 점은, 취업규칙에 따른 근로조건의 결정과정에서 「근로기준법」 제4조가 천명하고 있는 근로조건 대등결정원칙을 고수하기 위한 최소한의 장치라고 이해해야 한다. 다시 말해 사용자의 일방적인 근로조건 불이익 변경에 대해 노동자가 집단적인 방식으로 그 근로조건의 불이익한 변경 내용에 대해 동의 여부를 직접 결정하게 함으로써 근로조건 대등결정원칙의 균형을 유지하도록 하는 것에 목적이 있는 것으로 이해하는 것이 보다 합리적이다.[236]

따라서 사회통념상 합리성을 적용할 수 있는 경우는 법관이 「헌법」과 법률에 따라 재판을 해야 할 의무를 지고 있음에도 불구하고 법 규정이 없는 경우나 추상적인

234)대법원 2004.7.22. 선고 2002다57362 판결.
235)임종률, 앞의 책, 364면.
236)오세웅(2016), 「취업규칙 불이익변경의 사회통념상 합리성 여부」, 『노동판례리뷰 2015』, 한국노동연구원, 39-40면.

경우와 입법적 흠결이 있는 경우 또는 이를 규정하는 것이 타당하지 않은 경우에 한정해 법률과 현실의 괴리를 매우는 보충적 용도로만 한정하여 보다 범위를 좁혀 사용하는 것이 타당하다.[237] 일반원칙으로서 법 전반에 걸쳐 있는 「민법」상의 신의성실의 원칙에 대해서도 엄격한 해석이 가해지고 있는데 반해[238] 판례가 주장하고 있는 사회통념상 합리성은 관계 법령상의 규율도 없는 상태의 추상적 개념에 불과한 것임에도 불구하고, 사용자의 취업규칙의 불이익한 변경에 대해 「근로기준법」상의 강행법규에 구비된 요건을 갖추지 않아도 된다고 해석하는 것으로써 법리상 용인하기 어려운 무리한 일반개념으로의 회피다.[239] 또한 이것은 우리의 법체계에도 전혀 부합하지 않는 것으로[240] 사법해석상의 한계를 넘어서는 것으로 평가된다.[241] 나아가 이는 계약자유의 원칙과 근로조건 노사대등결정원칙에도 반하는 것이며, 합리성이라는 개념자체가 추상적이고 막연하기에 법적 안정성을 해할 우려가 있으므로 이를 인정하지 않는 것이 타당하다.[242]

제4절 소결

본래 사용자와 노동자 사이에 있어 근로조건의 형성은 당사자 간의 합의나 법령에 의하여야 한다. 하지만 그러한 법적 요청에도 불구하고 실질적으로는 대다수 사업과 사업장에서 취업규칙은 근로조건의 형성에 이를 때 상당한 구속력을 미치고 있는 것이 현실이다. 또한 취업규칙은 사용자에 의하여 일방적으로 작성된다는 점에 있어서 본질적으로 근로관계의 주된 내용이 사용자 일방에게만 유리하게 결정되는 것이 통상 관례인데 반해, 노동자들은 실질적으로 그에 구속되고 따를 수밖에 없다는 점에

---

237)장진나, 앞의 논문, 75면.

238)"…객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 하는 것이며, 이와 같은 경우에 해당하지 않는 한 비록 그 권리의 행사에 의하여 권리 행사자가 얻는 이익보다 상대방이 잃을 손해가 현저히 크다 하여도 그러한 사정만으로는 이를 권리남용이라 할 수 없고…", 대법원 1998.6.26 선고 97다42823 판결 참조.

239)장진나, 앞의 논문, 99면.

240)오세웅, 앞의 책, 40면.

241)임종률, 앞의 책, 364면.

242)정진경, 앞의 책, 19면.

서 노동자들의 근로조건이 쉽게 저하될 수 있다는 위험성이 상시적으로 존재하고 있어 그에 따른 보호가 필수적으로 뒤따를 것이 요구된다.

통상적으로 취업규칙의 불이익한 변경은 그 명칭 자체에서 의미를 발하고 있는 것과 같이 노동자가 종전부터 가지고 있던 기득의 이익이나 권리를 박탈하고 근로조건을 낮추거나 복무규율을 강화하여 실질적으로 일자리의 여건을 악화시키는 역할을 한다. 다시 말해 일한 대가에 알맞은 적정 임금을 보장 받을 '합리적 근로조건의 보장 받을 권리'가 침해되는 것은 물론이고 더 나아가 '일할 자리에 관한 권리'까지도 침해될 가능성이 있다. 따라서 우리 「헌법」상의 노동기본권의 실현을 목적으로 하고 있는 「근로기준법」은 노동자 권리 보호의 이념에 따라 취업규칙의 작성과 변경에 있어 일정한 제약을 가하고 있지만, 취업규칙에 내재되어 있는 편무성과 일방성은 여전히 쉽게 해소되지 않고 있다. 하지만 취업규칙의 불이익 변경에 관한 사항에 대해서 노동자 과반수의 동의를 받거나 노동자 과반수로 구성된 노동조합의 동의를 받도록 규정하고 있는 것은 사업 또는 사업장에 적용될 노동 조건의 결정시 노동자의 의견이 반영될 수 있도록 하는 기대를 담고 있는 것으로서 근로조건대등결정원칙을 투영하고 있는 것인바 최대한 보장되어야할 가치가 있다.[243]

그러나 여전히 우리 법원은 사회통념상 합리성이라는 추상적 이론을 가지고 노동자 과반수 동의를 요건으로 하는 취업규칙의 불이익한 변경에 대해 일정부분 제약을 면제해주는 것과 같은 모습을 취한다. 이는 「근로기준법」 제94조가 가지고 있는 강행법규 효력을 부정하는 것이며, 취업규칙을 법외 사회현상으로 방치해두는 것으로 불합리하다.[244] 또한 사용자에 대한 종속성이 강해 본인의 진정한 의사에 반하여 사용자의 의지에 따라 굴복될 수 있어 자신의 근로조건을 스스로 유지하기 어려운 노동자들에[245] 대한 보호 의무를 법원이 등지는 것으로 비난 받아야 할 대상이다.

---

243)이러한 점에 있어서는 최근 중앙노동위원회는 "…회사가 취업규칙을 불이익하게 변경하면서 집단적 의사결정방법에 의한 동의절차를 거치지 않은 것이 확인 되므로…그 변경한 취업규칙이 집단적 동의절차를 위반하여 무효이고…"라고 심판한 사례가 있는데 사업장 정년변경 관련 사건에서 사회통념상 합리성 여부는 전혀 거론하지 않고 배제한 채 노동자의 집단적 동의여부만을 고려의 대상으로 하여 결정하였다는 점에서 유의미하다고 볼 수 있다. 중앙노동위원회 2017.3.10. 2016부해1371, 2016부노251. 참조.

244)황현순(2004), 「취업규칙의 변경에 따른 문제점에 관한 小考 -불이익변경의 문제점을 중심으로-」, 『법학연구』 제20집, 원광대학교 법학연구소, 380면.

245)이승재(2004), 「근로자 동의 없는 취업규칙 불이익 변경의 효력」, 『노동법률』 Vol 159, ㈜중앙경

제4장 취업규칙 관련 행정지침의 쟁점과 문제

제1절 취업규칙제도와 관련된 사회적 이슈의 점검

Ⅰ. 취업규칙의 불이익 변경 요건 완화 시도

얼마 전 우리는 노동계뿐만 아니라 경영계까지도 떠들썩하게 만들고 사회적으로도 '사회통념상 합리성'에 대한 관심을 지대하게 이끌었던 사건이 있었다. 당시 노동계와 사회 각계각층에서는 사회적 합의나 법령의 근거도 없이 정부가 '지침'으로 정하여 일방적으로 강행하는 것은 우리 사회의 경제적 주축인 노동자들을 무시하는 처사라는 비판과 노동기본권이 침해되고 노동 인권의 퇴보를 불러 올 것이라는 등 그에 따른 부작용에 대한 우려의 목소리를 나타냈다. 이에 노동계는 이를 노동개악으로 치부해 성명을 발표하는 등 그에 따른 저항의 움직임이 나타났던바 있다.

이는 2016년 01월 노동부가 박근혜 정부의 경제혁신 3개년 계획에 따른 경과조치로서 '취업규칙 해석 및 운영지침'을 내놓았던 일을 말한다. 이것은 박근혜 정부가 2015년 12월 16일 발표한 「2016 경제정책방향」에서 '구조개혁 완성과 창조경제 확산으로 경제혁신 3개년 계획의 성과를 구체화하자'는 명목으로 노동 분야에 있어서는 노사정 대타협 후속조치를 꼽았다는 점과 "취업규칙 변경 및 근로계약 해지 등의 기준 · 절차 명확화를 위한 지침 및 근로계약 전반에 관한 제도개선 방안 마련"이라는 주문을 한 것에 따른 결과물로 보인다.[246]

그러나 이 같은 '지침'은 단순하게 취업규칙의 불이익한 변경 요건에 대해서 우리 판례가 말하고 있는 '사회통념상 합리성이론'을 차용하여 기존의 노동부 행정 지침을[247] 변경하고 재구성한 것에 불과한 것으로,[248] 우리 「헌법」이 말하고 있는 법치

제, 113면.

246)박근혜 정부는 이러한 주문에 "노동시장 체질개선을 위해 정부가 추진할 수 있는 조치를 종합적으로 마련 · 시행하여 노사정 대타협 사항을 확실히 이행"이라는 단서를 포함시켰다. 기획재정부 2016년 경제정책방향 사이트 <http://www.mosf.go.kr/policy/policy37/html/pol-08.html> 참조.

247)취업규칙 해석 및 운영지침(2009.4.24. 근로기준과-1118)을 말한다.

주의에 반하는 것으로 볼 수 있다. 우리 「헌법」이 추구하고 있는 법치주의는 경제정책을 실현하는 과정에서도 예외 없이 법의 지배가 적용되어야 하는 것을 의미한다. 따라서 법이 아닌 판례를 원용해 '지침'을 만들었다는 점과 그러한 '지침'을 노동부 근로감독관 등 일선에 배포하여 업무에 참조하게 했다는 점에서 '지침'이 실무상 효력을 갖게 하겠다는 의도가 어렵지 않게 예상되기에 위법성이 검토된다.

이처럼 사회적 파장을 불러오기에 충분했던 노동부의 '지침'은 시행 1년8개월만인 지난 09월 25일 공식 폐기되었다.[249] 김영주 노동부장관은 이날 열린 전국 기관장 회의에서 노동부의 '지침'이 사회적 공감대를 형성하지 못한 채 추진돼 한국노총의 노사정위원회 불참과 노정 갈등을 초래했고, '지침' 발표 이후의 활용 과정에서도 노사간의 갈등유발과 민·형사상 다툼이 발생하는 등 사회적 혼란이 지속돼 왔다고 '지침'의 폐지 사유를 밝혔다.[250]

노동부의 이 같은 움직임은 이미 예측 가능한 것이었다. 문재인 대통령은 대통령 예비후보 시절 답변한 '19대 대선 예비후보 노동정책발표회' 서면자료에서 노동부의 '양대 지침'은 노동자들의 기본권을 침해하고 우리 노동법의 기본체계를 무너뜨렸다고 평가한 바 있다. 또 두 '지침'은 법률이 명백하게 금지하고 있는 '사용자 일방의 근로조건 변경행위'와 '부당한 해고로부터의 노동자 보호'라는 원칙을 침해하는 내용을 담고 있기에 대통령 당선 시 이러한 정부의 '지침'을 즉각 폐기할 것이라고 밝힌 바 있고,[251] 2017년 08월 취임한 김영주 노동부장관이 '양대 지침'의 실질적인 폐기를 검토하고 있었기 때문이다.

하지만 이미 다수 기업의 취업규칙은 노동부의 '2016 취업규칙 해석 및 운영지침'

---

248)이전까지의 노동부 행정해석은 취업규칙의 불이익한 변경에 해당할 경우 노동자 과반수 동의를 받아야한다는 입장을 명시하고 있었다. 고용노동부(2016), 『근로기준법 질의회시집』 2013.1.-2015.12., 194면, 202면 참조.

249)"2016 취업규칙 해석 및 운영지침'이 폐기됨에 따라 노동부는 기존의 행정 지침인 '2009 취업규칙 해석 및 운영지침'으로 되돌렸다.

250)「'쉬운 해고' 양대지침 오늘 폐기…정부 "대화 복원 기대"」, 『뉴스1』, 2017. 09. 25., <http://news1.kr/articles/?3109871> 참조.

251)이는 문재인 대통령 외에도 당시 '19대 대선 예비후보 노동정책 토론회'에 문답지를 제출한 심상정, 유승민, 안희정, 안철수, 이재명 예비 후보 등 다른 대선 후보들의 의견과도 크게 다르지 않고, 다른 후보들 역시 문답지의 내용에서 '양대 지침'에 대한 우려를 나타내고 있으며, 만일 당선되어 집권할 경우 즉시 폐기하겠다는 취지의 답변을 표한 것을 확인할 수 있다.

에 맞추어 변경이 진행 중이거나 진행이 완료되어 있었다. 더욱이 신정부 출범 이전까지 노동부는 근로조건자율개선 사업과 일터혁신컨설팅 사업을 연계하여 1300개 사업장에 양대 지침을 확산시킬 계획을 세웠던 바 있고, 실제로도 22억원 가량의 세금을 투입해 1282곳에 '양대 지침'을 이미 도입시켰기 때문에 '지침'이 폐기되었다고 해도 '지침'의 이름으로 침해된 노동자들의 노동기본권은 여전히 복구되지 않고 엎질러진 물과도 같이 노동현장 곳곳에 스며들어 잔존하고 있다. 이에 대해 노동부장관은 노사합의 없이 도입된 2대 지침의 위법성이 인정된다며, 노사합의에 의해 양대 지침을 도입한 곳에 대해서는 노사 합의를 통해서 폐기할 수 있도록 지도하고 있으며 현안에 따라 실태조사가 필요한 곳은 조사를 진행하겠다고 밝혔다.[252]

그러나 이 같은 후속조치로도 이미 '지침'에 의해 변경된 취업규칙을 적용받아 해고 되었다거나, 불이익하게 변경된 취업규칙을 적용 받다가 이미 퇴사한 노동자에 대해서는 피해복구가 어렵다는 등의 한계가 있다. 이처럼 한번 침해된 기본권은 쉽게 되돌릴 수 없기에 기본권 침해는 사전 예방이 더욱 중요하다. 따라서 기본권의 제한 사유가 발생할 경우에는 사안을 접함에 있어 보다 「헌법」적으로 읽혀지고 풀이 되어야 할 필요성이 요구된다.

Ⅱ. '지침'이 차용했던 사회통념상 합리성론

정부가 '취업규칙 해석 및 운영지침'에 차용했던 이론적 개념의 대상으로서 우리 판례는, 비록 우리의 입법현실과는 맞지 않는다는 비판이 상존하고 있는 추상적 개념으로서 사회통념상 합리성을 재판상 판단 기준으로 삼고 있기는 하지만, 정작 그 해석과 적용에 있어서만큼은 보다 엄격하게 판단해야하고 제한적으로 적용해야만 한다는 입장을 견지한다.

> "…여기에서 말하는 사회통념상 합리성의 유무는 취업규칙의 변경 전후를 비교하여 취업규칙의 변경 내용 자체로 인하여 근로자가 입게 되는 불이익의 정도,

252)「양대지침(저성과자 일반해고·취업규칙 요건 완화) 피해자 대책 시급」, 『내일신문』, 2017. 11. 01., <http://www.naeil.com/news_view/?id_art=255068> 참조.

사용자 측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후의 취업규칙 내용의 상당성, 대상(代償)조치 등을 포함한 다른 근로조건의 개선상황, 취업규칙 변경에 따라 발생할 경쟁력 강화 등 사용자 측의 이익 증대 또는 손실 감소를 장기적으로 근로자들도 함께 향유할 수 있는지에 관한 해당 기업의 경영행태, 노동조합 등과의 교섭 경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 대응, 동종 사항에 관한 국내의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 다만 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에 동의를 받도록 한 근로기준법 제94조 제1항 단서의 입법 취지를 고려할 때, 변경 전후의 문언을 기준으로 하여 취업규칙이 근로자에게 불이익하게 변경되었음이 명백하다면, 취업규칙의 내용 이외의 사정이나 상황을 근거로 하여 그 변경에 사회통념상 합리성이 있다고 보는 것은, 이를 제한적으로 엄격하게 해석·적용하여야 한다.…"[253]

또한 노동자의 집단적 의사결정방법에 의해 취업규칙의 불이익한 변경에 대한 동의를 얻도록 한 단서규정이 1989년 03월 29일 신설된 이래로 우리 법원이 실질적으로 사회통념상 합리성 이론을 원용하여 무효인 취업규칙을 유효하다고 해석한 것은 단 두 건에[254] 불과하다.[255] 이 같은 사안에 있어서도 노동자 집단과의 '합의' 내지 그에 준하는 '추인'이나 '관여'가 그 배경에 있었다는 점을 종합하여 볼 때 여전히 취업규칙의 불이익한 변경 시에 있어서 노동자 집단의 동의 요건을 완전히 배제하는 것으로 판단하고 있다고 볼 수 없다. 이러한 점에 기초해 볼 때 사회통념상 합리성의 엄격한 적용에 대한 우리 법원의 입장이 확인된다.

물론 우리 법원이 사회통념상 합리성을 다룸에 있어 엄격한 기준에서 판단하고 있다고 한들 어느 곳에도 명문규정이 없는 사회통념상 합리성이 취업규칙의 불이익한 변경에 대해서 효력요건으로 정당화 받을 수 있는 것은 아니다. 오히려 법원이 사회통념상 합리성을 취업규칙의 불이익한 변경에 대한 판단 요건으로 다룸으로 인해서 사용자 측은 취업규칙을 노동자의 집단적 동의라는 민주적 절차를 통하여 변경하려

253)대법원 2015.8.13. 선고 2012다43522 판결.
254)대법원 2001.1.5. 선고 99다70846 판결.; 2002.6.11. 선고 2001다16722 판결.
255)강선희(2015), 「임금피크제 도입을 위한 취업규칙 불이익 변경 시 동의방법과 사회통념상 합리성」, 『노동리뷰』 통권 제128호, 한국노동연구원, 70면.

하기보다, 노동자 집단과의 대화를 생략하고 사회통념상 합리성을 인정받을 만한 요소를 갖추는 것에 기대는 경향을 보이는데서 우리 「근로기준법」 제94조가 가지고 있는 취지는 이미 훼손되고 있다고 보는 것이 적합하다.[256]

노동부의 '공정인사 · 취업규칙 지침 설명자료'는 우리 법원이 사회통념상 합리성 유무의 판단기준으로 삼는 여섯 가지 조건만을 반복적으로 언급하고 있을 뿐,[257] 실질적으로 판례가 판단의 배경으로 삼고 있는 노동자 집단과의 '합의'나 '추인', '관여' 등에 관한 제반 사항에 대해서는 언급하고 있지 않고 있다. 또한 최근 판례의 입장에 추가 반영 된 세 가지 조건인 '실질적으로는 노동자에게 불리하지 아니하는 등 노동자를 보호하려는 「근로기준법」의 입법취지에 어긋나지 않는지 여부'와 '취업규칙 변경에 따라 발생할 경쟁력 강화 등 사용자 측의 이익 증대 또는 손실 감소를 장기적으로 노동자들도 함께 향유할 수 있는지에 관한 기업의 경영 행태' 그리고 '변경 전, 후의 문언을 기준으로 불리한 변경 여부를 판단하였는지 여부' 역시 전혀 언급되어 있지 않다.[258]

또한 노동부는 '취업규칙 해석 및 운영지침'에서도[259] 여전히 '공정인사 · 취업규칙 지침 설명자료'의 내용과 같이 우리 법원이 사회통념상 합리성 유무의 판단기준으로 삼는 여섯 가지 조건만을 언급한다. 반면 이러한 '지침'을 업무에 활용할 근로감독관의 업무를 설명하는 제3편에서는 "…취업규칙 내용이 사회통념상 극히 부당하다고 판단되거나…"라고 서술하고 있는데, 이는 '극히' 부당하지만 않다면 일정한 정도의 부당함이 있더라도 취업규칙의 불이익한 변경이 용인될 수 있다는 것으로 받아들여야 한다는 것인지 의문이 생긴다. 한편에서는 당시 이 같은 노동부의 '취업규칙 해석 및 운영지침'이 사회통념상 합리성에 대한 판단 요소를 잘 정리하고 있다고 평가하는 견해도[260] 있었지만 이에 동의하기 힘들다.

---

256)오세웅, 앞의 책, 39면.

257)노동부의 '공정인사 · 취업규칙 지침 설명자료'의 내용을 보면, 6면과 19면, 39면 등 세 번에 걸쳐 반복적으로 사회통념상 합리성 유무 판단 기준을 언급하고 있는 것을 확인할 수 있다. 고용노동부(2016), 『공정인사 · 취업규칙 지침 설명자료』 참조.

258)본고 71면 <표1> 참조.

259)고용노동부(2016), 『취업규칙 해석 및 운영 지침』46면과 61면 참조.

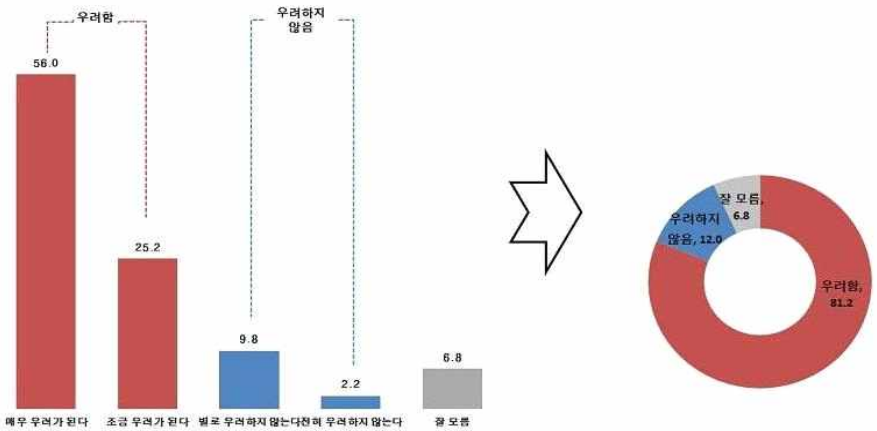
260)홍 성(2016), 「성과연봉제 확대도입과 사회통념상 합리성 이론」, 『노동법률』 Vol 302, ㈜중앙경제, 96면.

제2절 기본권 침해와 위헌성 측면에서 ‘지침’의 문제점

Ⅰ. ‘지침’의 내용 측면에서 기본권 침해 소지 검토

상황이 이러함에도 불구하고 노동부의 ‘취업규칙 해석 및 운영지침’은 여러 가지 문제가 상존하는 사회통념상 합리성 이론을 법원의 판단보다도 더욱 일반화하여 적용할 수 있다는 논리로서 전개되었던 것으로 보인다. 따라서 어떠한 결과로든지 노동자들의 노동기본권이 침해받게 되는 것으로 귀결될 것이 예상되었던바 다소 위험한 주장으로 구분지어 볼 수 있다. 이것은 그 당시 그러한 취업규칙을 적용받게 될 노동자들의 우려가 81.2%에 이를 정도이고 그 중 56%가 매우 우려한다고 응답한 것에만 비추어 봐도 결코 가볍게 판단할 문제가 아니었다는 것을 알 수 있다.

(Base: 전체 n=803, 단위: %)



<그림 3> 지침으로 인해 사용자가 임의대로 취업규칙을 변경할 수 있다는 우려도

출처 : 노사정합의에 대한 임금 노동자 여론조사보고서(2015. 09.) 참조.

노동부는 ‘취업규칙 해석 및 운영지침’의 본문 내용에서 노동조합 조직률이 2014년도 기준 10.3%로 그다지 높지 않은 상황에서 노동자의 근로조건과 복무규율을 통일적으로 정한 취업규칙은 노동자 보호에 있어서 중요한 수단이라고 표현하면서도,[261]

261)고용노동부(2016), 앞의 자료, 69면.

취업규칙의 불이익한 변경에 대해서는 사회통념상 합리성이 있는 경우 노동자의 동의를 받지 않았더라도 변경된 효력을 부정하지 않는다고[262] 판례를 원용하는 등 상반된 입장을 취하고 있다. 이는 과연 취업규칙의 변경을 다룸에 있어 노동부의 노동정책적 판단을 노동자들의 보호 측면에 중점을 두어 접근하겠다는 것인지, 아니면 노동기본권의 침해 가능성을 내포하고 있는 불이익한 변경일지라도 추상적 개념에 불과한 사회통념상의 합리성을 이유로 들어 노동자들이 일방적으로 감내해야만 하는 것이라고 판단하는 것인지 의도가 분명치 않다.

만일 노동부의 지침을 그대로 따르게 된다면 우리 판례의 입장인 사회통념상 합리성이론은 그대로 취하되, 판례가 사회통념상 합리성의 판단 배경으로 삼고 있는 '실질적으로 취업규칙이 불이익하게 변경되어가는 과정상에 있어 노동자 집단과의 합의나 추인, 관여 등에 관한 제반 사항의 검토 여부'는 배제된다. 따라서 실질적으로는 우리 법원이 판례에서 다루고 있는 사회통념상의 합리성과 명칭만 같을 뿐 그 의미와 성격이 본질적으로 달라져버리게 된다는 문제점이 생긴다. 이는 취업규칙 내용의 불이익한 변경을 보다 간편하게 가능하게 할 수 있는 것으로, 종국적으로는「헌법」상 권리인 노동기본권이 침해받게 되는 것으로 연결된다.

국가인권위원회 역시 이러한 점에 있어서 노동부의 '지침'은 법규적 효력이 없는 안내서 또는 참고자료임에 불과함에도 '지침'의 법적 성격과 효력을 오인해 개별 판례의 일반화에 따른 오용 또는 남용 가능성을 제기했다. 또 그로인해 국민의 노동기본권 중 노동의 권리가 침해될 수 있다는 점을 우려하여 노동부는 국민의 노동의 권리가 약화되지 않도록 조치할 필요가 있다는 의견표명을 한 바 있다.

> "…고용노동부가 2대 지침을 발표한 이후 이를 적극적으로 홍보하고, 소속기관에 시달하여 해고와 취업규칙 변경에 관한 사업장 지도·감독·교육의 지침으로 활용하도록 함에 따라, 일반 국민과 노사 당사자는 2대 지침이 해고와 취업규칙 변경에 대하여 법적 구속력을 가지는 것으로 오해할 수 있는 여지가 있다. 이로 인하여 2대 지침이 근로 사업장에서 근로자의 해고 및 취업규칙 변경과 관련한 실질적인 판단기준으로 통용될 경우, 국민의 권리를 사실상 규율하는 결과가 될 수

262)고용노동부(2016), 앞의 자료, 35면.

있을 것이다. 따라서 고용노동부에서는, 국민의 근로의 권리 보호를 위하여……근로자 동의 없는 취업규칙의 불이익 변경의 사회통념상 합리성 유무에 대해서도 법원은 매우 제한적으로 해석 · 적용하고 있다. 또한 법원의 판결은 개별 사건에 따라 근로자 및 사업장의 구체적 사정 및 여건 등을 종합적으로 고려하여 판단하는 것이므로 외형상 유사한 사건이라 하여 동일한 결론에 이를 것이라고 단정하기는 어렵다 할 것이다.……그러나 2대 지침상의 기준과 절차에 따르면 근로자 동의 없는 취업규칙 불이익 변경이 정당성이나 합리성을 당연히 인정받을 수 있는 것처럼 안내하는 면이 있어, 일반 국민과 노사 당사자가 이와 같이 오해하거나, 근로현장에서 사용자가 2대 지침을 근로자에게 압력을 행사하기 위한 수단으로 남용할 가능성을 배제할 수 없다.……근로자를 보호하고 노사가 동등한 지위에서 합의를 통해 근로조건을 결정하도록 한 「근로기준법」의 취지를 고려하여 오용 또는 남용을 방지할 조치가 필요하다.…"[263]

본래 국가인권위원회의 업무는 「국가인권위원회법」 제30조 제1항 규정에 따라 「헌법」 제10조부터 제22조까지의 규정에서 보장된 자유권적 기본권에 대한 침해와 차별행위에 대한 진정이 통상적인 조사 범위에 속한다. 하지만 국가인권위원회가 본 사안의 심각성을 고려해「국가인권위원회법」 제30조 제3항 규정인 "위원회는 제1항의 진정이 없는 경우에도 인권침해나 차별행위가 있다고 믿을 만한 상당한 근거가 있고 그 내용이 중대하다고 인정할 때에는 직권으로 조사할 수 있다."는 점을 들어 이례적으로 통상의 업무 범위를 벗어나 「헌법」의 사회적 기본권에 해당하는 제32조의 노동기본권에 대한 침해를 직권으로 조사하고 의견을 표명하였다는데 큰 의미가 있다.

Ⅱ. 행정입법 측면에서 '지침'의 기본권 침해 판단

「헌법」은 국가의 최고 법이고, 객관적 가치질서로서의 기본권은 「헌법」으로

263)국가인권위원회(2016), 상임위원회 결정례 : 고용노동부 「공정인사지침」및 「취업규칙 해석 및 운영지침」에 대한 의견표명, 3-6면.

이해되기 때문에, 우리 국민이 가지는 「헌법」상 권리인 기본권은 여타의 법률과 법령보다 상위의 효력을 가지게 되고 이로 인해 여타의 법령들은 기본권에 합치되어야만 한다. 이는 곧 기본권의 내용을 존중하는 법이 되어야 하는 것을 말하므로, 입법, 사법, 행정 등 모든 국가권력은 기본권을 존중해야 한다.

따라서 최근 사회적 이슈가 되었던 노동부의 '지침'은 실질적으로 취업규칙의 불이익한 변경 요건을 완화하여 노동기본권의 침해를 불러올 수 있다는 우려가 제기되었던바, 노동부의 행정작용이 구체적으로 어떠한 근거에 의해서 이루어진 것이고, 또 어떠한 법적성격을 지니고 있던 것인지 검토해볼 필요성이 요구된다.

원칙적으로 국민의 권리와 의무에 관련된 법률은 국민들의 대표기관인 국회의 입법으로 정해져야 한다.[264] 그러나 '국회중심입법의 원칙'에 따라 입법권이 국회에 속하는 경우에도 입법기능에는 일정한 한계가 있을 수밖에 없고,[265] 모든 사항을 법률로서 세세하게 정하여 둔다는 것은 조문이 매우 방대해진다는 결과를 불러오는 문제점과 행정의 변화에 대해서 국민의 이해를 탄력적으로 반영하지 못할 수 있다는 우려가 생긴다.[266] 이에 우리 「헌법」은 제75조와 제95조에서 "대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다."와 "국무총리 또는 행정각부의 장은 소관 사무에 관하여 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령을 발할 수 있다."고 각각 명시하여 행정입법을 인정한다.

행정입법이란 행정주체가 법조의 형식으로 규범을 정립하는 작용을 말하는 것으로서, 행정기관이 일반적 · 추상적 규범을 정립하는 작용을 뜻한다.[267] 여기서 '일반적'이란 불특정 다수인에게 적용됨을 의미하고, '추상적'이란 불특정 다수의 사안에 적용됨을 의미한다.[268] 광의의 개념으로서 행정입법은 국회입법권, 사법입법권, 자치입법권을 제외한 정부의 규범 정립권을 그 내용으로 하며, 대통령, 국무총리, 각부 장관, 중앙행정관청의 장 등이 갖는 법규명령과 행정명령의 제정권을 포괄한다. 반면

---

264)「헌법」은 제40조에서 "입법권은 국회에 속한다."고 명시하고 있다.
265)허 영, 앞의 책, 1030면.
266)이철주 · 강경선 · 김민배(2006), 『행정법Ⅰ』, 한국방송통신대학교출판부, 179면.
267)강의중 외(2008), 『행정법』, 교학연구사, 121면.
268)김남진 · 김연태(2007), 『행정법Ⅰ』, 법문사, 139면.

협의의 개념으로는 대통령의 법규명령(위임과 집행명령) 제정권만을 내용한다.[269]

행정입법은 자의적으로 남용될 경우 국민의 기본권이 심각하게 침해받게 될 수 있을 뿐만 아니라, 법치행정의 원칙에도 반하게 됨으로써 민주주의 체제의 근간마저 위협받게 되는 것이 예측된다. 따라서 행정입법에는 일정한 한계가 따를 수밖에 없다는 것에 의심의 여지가 없고, 헌재 역시 같은 입장을 보인다.

> "…위임입법의 한계와 관련하여 헌법 제75조는 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다고 규정하고 있다. 사실상 입법권을 백지위임하는 것과 같은 일반적이고 포괄적인 위임은 의회입법과 법치주의를 부인하는 것이 되어 행정권의 부당한 자의와 기본권행사에 대한 무제한적 침해를 초래할 것이기 때문에, 위임입법의 한계에 관한 헌법의 취지는 위와 같은 결과를 사전에 방지하고자 함에 있다고 할 것이다. 따라서 법률의 위임은 반드시 구체적 개별적으로 한정된 사항에 대하여 행하여져야 할 것이다. 다만 구체적인 범위는 각종 법령이 규제하고자 하는 대상의 종류와 성격에 따라 달라진다 할 것이므로 일률적 기준을 정할 수는 없지만, 적어도 법률의 규정에 의하여 이미 대통령령으로 규제될 내용 및 범위의 기본사항이 구체적으로 규정되어 있어 누구라도 당해 법률로부터 대통령령에 규정될 내용의 대강을 예측할 수 있으면 족하고…"[270]

이에 따라 노동부의 '행정지침'은 행정입법에 해당한다는 것을 확인했다. 그렇다면 이번에는 중앙행정관청의 장이 가지고 있는 법규명령과 행정명령(행정규칙) 중 어느 부분에 해당하는지 여부를 확인해 볼 필요가 있다.

먼저 법규명령은 '법규'를 내용에 포함하는 행정입법으로 국민의 권리와 의무에 관한 사항을 포함하며 법규명령을 위반할 시 위반에 따른 처벌을 받게 된다는 점과[271] 법원과 같은 다른 국가기관에 대해서도 구속력을 갖는다는 점을[272] 볼 때 노동부의 그것과는 성격이 다르다. 따라서 노동부의 지침은 법규명령보다는 행정기관이 하급

269)허 영, 앞의 책, 1031면.
270)헌재 1995.7.21. 선고 94헌마125 결정.
271)이철주 · 강경선 · 김민배, 앞의 책, 183면.
272)김남진 · 김연태, 앞의 책, 141면.

행정기관에 대한 지휘 · 감독권 등에 근거하여 제정할 수 있는 행정규칙(행정명령)에 더 부합한다.

행정규칙은 통상적으로 법령의 수권 없이도 행정권의 고유한 권한으로 발하는 일반 · 추상적인 규율을 의미하고, 그 형태는 고시와 훈령, 지침 등에 의한 형식이 주를 이룬다. 이때의 행정규칙은 재판규범으로서의 효력을 가지지 않는 것이 원칙이며 행정조직의 내부에서 구속력을 발휘할 목적으로 그 기관 또는 구성원만을 직접적인 규율 대상으로 삼아야하기에 법규성이 결여되어 있다. 이러한 점에서 우리 법원도 행정규칙은 대외적으로 법원이나 국민을 기속하는 효력이 없다고 판시한다.

> "…그 성질 및 내용으로 보아 같은 법 소정의 요양관리 및 요양업무처리(노동부예규 제188호 및 제221호) 등에 관하여 행정청 내부의 사무처리준칙을 정하고 있는 것에 불과하여 대외적으로 법원이나 일반 국민을 기속하는 효력은 없는 것이므로…"[273]

그러나 실제로는 상급행정기관이 정해놓은 행정규칙을 하급행정기관에서 실무차원에서 활용하게 되므로 국민과의 관계에서 집행하게 돼 사실상 행정규칙의 효과가 일반 국민에게까지 미치게 된다는 결론에 이른다.[274] 이 경우 행정조직 내부에서만 제한적으로 효력을 가지고 있어야 하는 행정규칙이 실질적으로는 대외적인 부분에 있어서도 일정부분 효력을 갖추어 영향력을 행사하게 되므로, 행정기관으로부터 국민의 기본권이 침해당하는 일이 발생할 수 있다는 점에서 우려가 제기된다.

하지만 이때 국민이 적극적으로 나서 기본권 침해요소 제거 등의 문제에 대해 권리 구제 절차를 밟아 권리 구제를 직접적으로 실현해낸다는 것은 사실상 어렵다는 측면이 있어 이를 결코 가벼이 생각할 수만은 없다. 더욱이 노동부의 행정지침들 중에는 행정규칙의 범주에도 해당하지 않는 업무매뉴얼, 가이드라인 등 비공식적인 행정작용에[275] 해당하는 것들이 많아 이러한 것들로 인해 권리의 침해가 발생할 경우 실질적인 권리 구제가 더욱 난해한 상태에 봉착하게 된다. 따라서 노동부의 '양대 지

---

273)대법원 1995.9.15. 선고 94누12326 판결.
274)김남진 · 김연태, 앞의 책, 142면.
275)민주사회를 위한 변호사모임(2016), 「'지침'에 의한 쉬운 해고, 취업규칙 변경의 문제점」, 『노동개악 저지를 위한 민변 자료집2』, 18면.

침'은 기본권 침해 요소가 상당하다.

Ⅲ. '지침'의 위헌성 여부

노동부는 중앙행정부처로서 노동관계법의 위임에 따라 부령으로 각 법률의 시행규칙을 제정하는 이외에 사무처리 기준의 정립, 행정감독과 단속, 행정지도 등을 위하여 예규와 훈령, 고시, 지침과 매뉴얼, 가이드라인 등 다양한 명칭을 사용해 많은 규정들을 세부적으로 제정하여 사용하고 있다.[276]

행정지침은 앞서 확인한 바와 같이 시행령도 아니고 시행규칙 역시 해당하지 않는 것은 물론이며 행정규칙에 불과한 것으로서 대외적인 법규범성 조차 없다. 따라서 행정지침의 위법성으로 인해 국민의 기본권에 대한 침해가 발생하게 될 시 행정소송 또는 헌법소원 등에 의한 권리구제를 받기가 힘들다는 치명적인 문제가 발생한다.

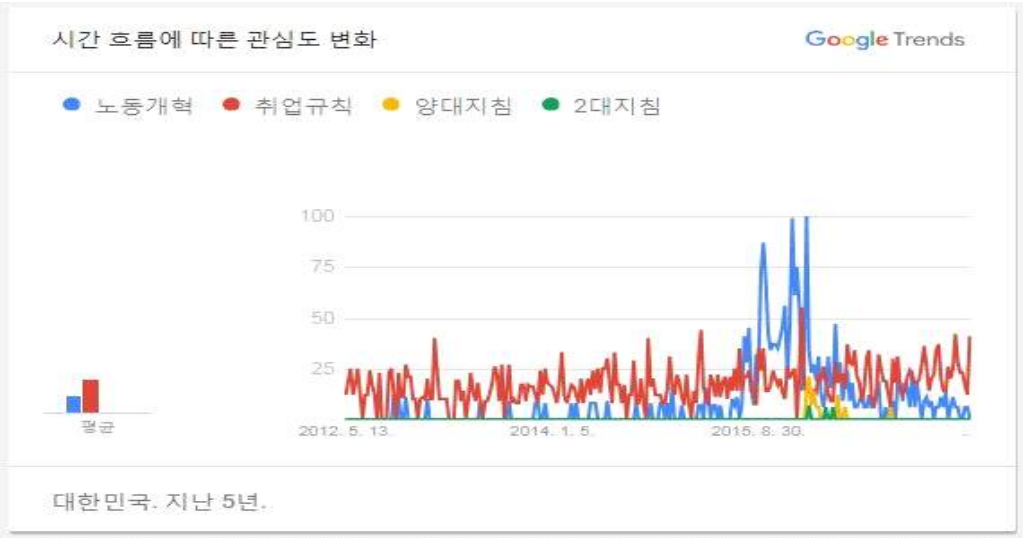
하지만 한국경영자총협회의 발표 자료인 '공정인사 지침에 대한 기업 인식 및 대응조사' 결과에 따르면 기업의 78.3%가 노동부의 '취업규칙 해석 및 운영지침'에 따라 인사제도를 개선하기위해 노력 중이라고 응답했다는 점에서[277] 우려를 표하지 않을 수 없다. 이에 최근 이루어 졌던 노동부의 '취업규칙 해석 및 운영 지침'에 대해 위헌성 여부를 판단해보고 그를 기반으로 하여 지난일과 같은 과오가 다시 반복되지 않을 수 있도록 점검해 볼 필요가 있다.

노동부는 '2대 지침'의 부당성을 이유로 노동부장관을 상대로 국가인권위원회에 제기된 지침의 철회요구 진정 사건에서[278] "2대 지침은 사용자와 근로자, 그리고 일반 국민들이 근로계약의 성립과 종료에 관한 법적 해석 등 관련 정보를 미리 알 수 있도록 하여, 법적 분쟁을 사전에 예방할 목적으로 마련된 '안내서'이거나 또는 취업규칙의 신고 및 변경 등과 관련한 행정적 · 형사적 법집행의 명확성을 제고할 목적으로 마련된 '참고자료'라고 답변"한 바 있다.[279]

---

276)민주사회를 위한 변호사모임, 앞의 자료, 1면.
277)한국경영자총협회(2016), 「공정인사 지침에 대한 기업 인식 및 대응조사」, 노동정책본부 법제1팀, 1면.
278)국가인권위원회 16진정0079500 사건.
279)국가인권위원회, 앞의 자료, 3면.

또한 '취업규칙 해석 및 운영 지침' 마련의 필요성에 대해서는 "취업규칙 변경에 있어 현행법과 판례에서 말하는 '불이익'과 '사회통념상 합리성'이라는 개념과 법리는 그 추상성으로 인해 법 적용과 해석을 둘러싼 불확실성이 존재하므로 법 적용과 해석을 둘러싼 불확실성을 해소하고, 노사가 이를 참고하여 취업규칙을 개정하도록 지원하는 한편, 지방노동관서에서 취업규칙을 심사할 때 활용하고자함을 목적으로 한다."고 명시하여 노동 실무 현장에서 '지침'을 활용하겠다는 의지를 표시한 바 있고,[280] 실제로도 곧 그것을 실행으로 옮겨 실질적으로 현장에서 '지침'을 활용하기 시작했다는 것 역시 <그림 4>를 통해서도 확인해 볼 수 있다.



<그림 4> 시간 흐름에 따른 관심도 변화[281]

출처 : Google Trends 참조. <https://trends.google.com/>

<그림4>는 빅데이터를 기반으로 하는 Google Trends를 활용해 '노동개혁', '취업규칙', '양대 지침', '2대 지침'을 키워드를 중심으로 하여 시간의 흐름에 따라 최근 5년간의 관심도 변화를 확인해 본 것이다. '노동개혁' 키워드를 중심으로 보면 평균적으로 10%대를 넘지 못하던 관심도가 대타협시기에 85%대로 치솟고 노동부가 일방적으로 '양대 지침'을 발표 시기 즈음에 100%대를 웃도는 것이 확인된다. 또한 '취업

280)고용노동부(2015), 「취업규칙 변경의 합리적 기준과 절차 공청회 발제문」, 3-4면.
281)2017.05.07. 검색 기준 최근 5년간의 자료.

규칙' 키워드를 중심으로 보면, '양대 지침'의 발표 시기 이전에는 평균 25%선 미만이었던 관심도가 '양대 지침' 발표 직후 55%선으로 올랐다. 마지막으로 '양대 지침'과 '2대 지침' 키워드는 최근 5년간 전혀 관심도에 오르지 못하다가 노동부의 '지침' 발표 이후 25%대와 10%대로 각각 상승한 것이 확인된다.

따라서 노동부가 현실적으로 해당 시기에 '양대 지침'에 대해서 적극적인 홍보를 하였을 것이라는 점과, 실무선에서도 업무에 적용하기 시작했다는 점을 유추해볼 수 있다. 더 나아가 내부적 규범인 행정지침을 가지고 외부적으로 적극 활용했다는 것 역시 유추되며, 결국 일반 국민에게 실질적으로 영향을 미쳐 관심도로 반영돼 나타난 근거로 보인다. 이는 어떠한 법적 구속력도 없는 노동부의 '행정지침'이 실무상에서는 효력을 부여 받게 돼, 일선 근로감독관들이 노동관계법령의 해석을 하고 업무를 처리하는데 있어 사실상의 기준이 된 것으로, 현실적인 측면에서는 어떠한 방식으로든 노사 당사자에게 상당한 영향을 미쳤을 것이라는 점이 그리 어렵지 않게 예상된다.[282][283]

만일 노동부의 '취업규칙 해석 및 운영 지침'이 의도하는 바가 노동부가 주장하는 바와 같이 단순히 법령과 판례를 해설하고 설명하는데 불과한 것이라면 '지침'에 대해 무용론이 제기될 것이다. 반면 법령과 판례의 법리가 추구하는 기본권 보호의 이념과 법치주의의 원리를 벗어나 단순히 취업규칙을 쉽게 변경하도록 할 수 있도록 하기 위한 길을 열어주는 것이라면 '취업규칙 해석 및 운영 지침'은 그 자체로도 위법한 것이다. 이것은 '지침'이 어느 쪽을 택하더라도 위법성의 범주에서 자유롭지 못하다는 것을 의미한다.

따라서 우리 「헌법」이 제32조 제3항에서 "근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다."고 명문으로 규정하고 있는 점과 판례도 "이처럼 헌법이

---

282)같은 의견으로는 배규식, "'취업규칙 불이익 변경', '저성과자 통상해고'와 관련된 정부의 가이드라인 발표는 그 자체로는 제도개선이나 변화는 아니지만, 현실적으로 상당한 영향을 미칠 수 있다다"고 판단하며, "가이드라인 발표를 계기로 하여 사용자측이 이를 이행하는 경우 현장에서 노사 간에 적지 않은 갈등이 예상되며 법적인 다툼도 적지 않게 일어날 것으로 예상"하고 있다., 배규식(2016), 「2015년 노사관계 평가와 2016 노사관계 전망」, 『노동리뷰』 통권 제130호, 한국노동연구원, 35면.

283)이에 대해 노사정위원회 토론회에서도 노사분야의 기본적 지도 원리는 '집단적 자치'가 되어야하고, 정부의 이 같은 지침은 노사가 자율적으로 조율할 여지를 차단시키는 우를 범할 수 있다고 우려하고 있다. 박종희(2015), 「지정토론문」, 『노동시장 구조개선을 위한 사회적 대화, 진단과 대안』, 대통령소속경제사회발전노사정위원회, 55면.

근로조건의 기준을 법률로 정하도록 한 것은 인간의 존엄에 상응하는 근로조건에 관한 기준의 확보가 사용자에 비해 경제적·사회적으로 열등한 지위에 있는 개별 근로자의 인간존엄성의 실현에 중요한 사항"이라고 설시하며 의미를 부여하고 있다는 점,[284] 그리고 「헌법」상 권리인 노동기본권을 실현하기 위한 「근로기준법」이 취업규칙 변경 절차에 대해 별도의 위임규정 없이 강행규정으로서 실질적으로 규율하고 있는 점 등을 종합해 볼 때, 노동부가 '행정지침'을 통해 노사관계의 규율을 시도하였던 것은 노동기본권의 침해요소가 상당하다. 이러한 점에서 '지침'은 위헌성을 이유로 한 헌법소원의 대상으로 볼 수 있다.[285] 하지만 이 경우에 있어서도 정부의 '취업규칙 해석 및 운영 지침'은 노동부 내부의 행정지침에 불과한 것이기에 그 내용에 위법성이 있다고 보임에도 불구하고 여전히 실질적 권리구제가 어렵다는 점은 풀어야할 과제이다.

제3절 소결

본 장에서는 최근 사회적 이슈로서 각계의 논의 대상이 되었던 단순한 '행정지침'에 불과한 정부의 '취업규칙 해석 및 운영지침'이 실질적으로는 노동자들의 노동기본권을 침해하게 된다는 점에 기초하여, '지침'의 '위법성'과 '위헌성' 여부를 판단해 보고자 하였고 어렵지 않게 결과를 도출해 낼 수 있었다. 취업규칙은 「헌법」 제32조에 따른 노동의 권리에 해당하는 노동기본권의 보호 대상이다. 이에 국가인권위원회도 정부의 '취업규칙 해석 및 운영지침'으로 인해 노동기본권 측면에서 노동의 권리가 침해될 것을 우려한다. 또한 취업규칙의 불이익한 변경에 있어 사회통념상 합리성을 대하고 있는 판례의 입장도 근래 들어 그 적용에 있어서 굉장히 신중하고 엄격한 입장에 있으며 현재에 이르러서는 판단 기준까지 추가한바 있다. 따라서 노동부가 단순히 '행정지침'에 불과한 '지침'으로 사실상 노동 현장을 규율하려 시도한 것은

284)헌재 2003.7.24. 선고 2002헌바51 전원재판부 결정.

285)이 점에서 "근로기준법 제94조에 정면으로 반하는 불법을 종용하는 지침"이라는 평가가 있다. 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회, 법률원(2015), 「노사정 위원회 '합의안'의 문제점에 대한 법률적 검토 의견서」, 14면 참조.

위법성과 위헌성이 도출된다. 하지만 그로 인한 기본권의 침해를 받게 된 국민은 실질적 구제방안이 마땅하지 않아 권리 침해의 정도가 비교적 심각하다.

노동부가 이처럼 말도 많고 탈도 많던 '취업규칙 해석 및 운영지침'을 고집하였던 이면에는 「고용상 연령차별금지 및 고령자의 고용촉진에 관한 법률」에 의해 정년이 60세로 법제화 된 것이 배경에 있고, 그에 따라 임금피크제를 실현할 목적을 가진 것으로 보인다. 하지만 「고용상 연령차별금지 및 고령자의 고용촉진에 관한 법률」 제19조 '정년' 조항은 강행규정이다. 이는 굳이 노동부가 나서지 않아도 따를 수밖에 없는 것인데도 불구하고 강행법규의 추진을 위해 또 다른 강행법규인 「근로기준법」상의 규정을 위반한 것으로, 그에 정함이 있는 노동자의 권리를 침해하면서까지 '지침'을 고집하였었다는 점은 쉽게 이해할 수 없다.

우리나라 「헌법」은 사회적 법치국가의 원리를 투영하고 있다. 법치주의는 전제군주국가에서의 군주의 자의에 의한 국민의 자유와 권리의 침해에 대한 반성에서 비롯된 관념으로 특히 행정권에 대한 국민의 권리와 자유의 보호가 중요한 목적으로 대두된 것이다.[286] 따라서 본 사례에 있어 그 의미를 되새겨 볼 필요가 있고, '법은 공포되기 전에는 의무를 지우지 않는다.'는 법언 역시 유념해야 할 것이다.

또한 정부가 '취업규칙 해석 및 운영지침'을 내세우며 노동시장을 유연화 시켜 일자리를 늘리고 경제를 살리겠다고 했던 점 역시, 우리 「헌법」이 의미하고 있는 법치주의는 경제정책을 실현하는 과정에서도 예외 없이 적용되어야 한다는 점에 위배되므로 어떠한 시각으로 보아도 위법하다고 보지 않을 수 없다.

정부는 정책적으로 국민의 기본권 보장을 실현해야할 의무를 가진다. 특히 노동정책을 담당하고 있는 노동부는 「헌법」과 그로부터 노동자의 권리 보호를 목적으로 하여 파생된 노동관계법령들에 따라, 노동자들의 노동기본권 보장을 실질적으로 실현하기 위해 노력해야하고 노동의 가치를 지켜야할 의무가 있다. 그러므로 그러한 의무를 지고 있는 노동부 정책담당자들은 더 많고 더 좋은 일자리를 촉진하기 위한 정책을 수립하고 추진해야 한다.[287] 다만, 이러한 경우에도 기존 일자리의 질을 떨어트리며 새로운 일자리를 창출하는 것은 지양되어야 한다.

---

286)강의중 외, 앞의 책, 50-51면.
287)한국고용정보원(2016), 『2016 KEIS 노동시장 분석』 기본연구 2016-02, 2면.

우리가 인간 생활의 전반에 걸쳐 중요한 토대가 되는 노동자의 기본권적 지위를 어느 수준과 범위에서 이해하여야 할 것인지 판단할 때에는 기본권의 최대보장의 정신에 입각해 해석해야할 것이며, 그때야 비로소 우리 「헌법」이 담고 있는 '인간의 존엄과 가치'가 노동의 각 영역에서도 실질적으로 역할을 다해주게 될 것이다.[288]

이 같은 점을 종합하여 볼 때, 노동부가 주도했었던 '취업규칙 해석 및 운영지침'의 내용과 같은 정책으로는 「헌법」상의 노동의 권리 측면에서 '일할 환경에 관한 권리'의 보장에 대한 기대는 말할 나위 없고 '일할 자리에 대한 권리'를 보장 받는다는 것 마저 사실상 불가능하다는 측면이 있다. 따라서 오히려 그러한 '지침'으로 국민의 기본권을 침해하고 있었던 '취업규칙 해석 및 운영지침'의 폐기는 어쩌면 이미 정해져있던 수순이라고 보인다.

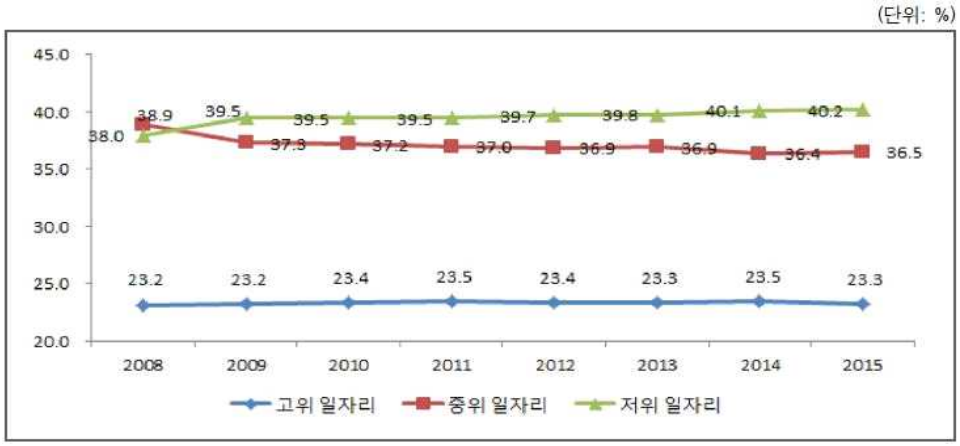
제4절 제언

취업규칙과 관련된 논의는 비단 어제오늘만의 문제는 아니다. 이미 노동법학계에서는 지속적인 논의가 있었음에도 불구하고 여전히 취업규칙의 법적 성격을 명확하게 정립하지 못하고 있다. 취업규칙은 때론 「근로기준법」이 표방하고 있는 근로조건대등결정원칙에 정면으로 반하는 제도라는 비판을 받기도 한다. 그러한 연유로 사법기관도 아닌 행정기관인 노동부가 현행법과 판례가 말하고 있는 '불이익'과 '사회통념상 합리성'이라는 개념과 법리는 그 추상성으로 인해 법 적용과 해석을 둘러싼 불확실성이 존재한다며, 법 적용과 해석을 둘러싼 불확실성을 해소하겠다고 '지침'까지 들고 나오게 된 빌미가 제공된 것이 아닌 가 미루어 생각해 본다.

현재 전 세계는 유례없는 경기 침체를 겪고 있다. 우리나라 역시 그것을 비켜가지 못하고 곧바로 내수가 침체에 빠지는 등의 사회경제적 현상을 나타나고 있으며, 그 영향을 받아 노동시장에 양극화 현상이 발생해 노동자들의 일자리 질적 수준이 저하되어가고 있다. 이러한 현상은 시간이 지날수록 나날이 격차가 더욱 심화되어 가고 있는 양상을 보인다. 이는 '일자리 질적 수준별 고용구조 추이'를 통해서도 확인해

288)김진곤, 앞의 논문, 47면.

볼 수 있는데, 사회적으로 그나마 어느 정도 '일할 환경에 관한 권리' 측면에서의 보장이 갖추어져 있을 것이라 기대해볼 수 있는 '중위 일자리'는 지속적으로 감소해가고 있는 반면, 보다 열악한 처우일 것이라는 것이 예상되는 '저위 일자리'가 그 빈자리를 대체해 잠식해가며 전체적인 일자리의 질이 떨어져가고 있음을 알 수 있다.



<그림 5> 일자리 질적 수준별 고용구조 추이

출처 : 2016 KEIS 노동시장 분석 참조.

따라서 이제는 우리의 노사관계를 보다 합리적으로 규율하고 노사대등결정원칙을 보다 진정성 있게 반영해, 실질적으로 노동자들의 노동기본권을 구체화하여 실현할 수 있는 대안과 제도가 필요하다.

먼저 생각해볼 수 있는 문제는 현행 취업규칙 제도의 개선이다. 판례가 추구하고 있는 사회통념상 합리성 이론이 반드시 필요한 것이라고 한다면, 「헌법」의 기본이념 그리고 이미 기존에 구성되어 있는 노동관계 법령들과의 관계에 있어서 상충된다거나 대립되지 않도록 하여 합리적인 방법으로 융화될 수 있도록 입법적 개선으로서 해결해야 할 것이다. 더 이상 현재와 같이 추상적인 개념에 불과한 사회통념상의 합리성 이론을 들어 「헌법」적 가치와 「근로기준법」의 강행적 효력규정을 부정하면서까지 사회통념상의 합리성 이론의 입장을 고수해 진부한 논의를 이어갈 이유와 필요가 없다.

또 다른 측면에서 접근하자면 취업규칙이 편무성과 일방성으로 인해 문제가 지속

적으로 발생하고 있는 부분의 개선을 요하는 것으로 취업규칙의 작성과 변경에 관련된 전 단계에 걸쳐 내용상 불이익 여부와 관계없이 노동자 과반수의 동의를 얻도록 하여 실질적 측면에서 노사가 공동으로 취업규칙을 작성하도록 「근로기준법」 제94조 제1항을 개정하는 것을 검토해 볼 수 있겠다.

물론 이 같은 경우에는 단체협약의 그것과 성격이 비슷해진다는 점에서 의견이 있을 수는 있겠으나, 단체협약은 노동3권상 노동자 집합체의 쟁의권 등이 보장되어 그 실질적 보장 측면에서 취업규칙보다 우위를 선점할 수 있다는 점과 그로 인해 권리 실현이 보다 용이하다는 점, 그리고 노동조합 조직률이 10%대에 불과하고 그마저도 노동자 과반수로 이루어진 노동조합은 더욱 적을 것이 예상되는 현실 속에서 취업규칙이 대다수 노동자에 대해 직접적으로 구속력을 발휘하고 있는 바, 보다 실질적 측면에서 노동자의 권리 구제와 보장이 절대적으로 필요하다는 점 등을 들어 논란을 해소할 수 있을 것이라 생각한다. 하지만 사용자가 최초 사업 개시 전 이미 취업규칙을 작성하고 확보한 상태로 노동자를 채용하는 경우에 있어서는 여전히 일방성과 편무성 문제가 발생할 것이 예상된다. 또 그 외에도 노동자가 무조건적으로 동의를 하지 않고 버티려하여 법원의 판단이 필요하게 될 경우 법원은 여전히 사회통념상 합리성을 들어 판단하려할 수 있다는 것은 고려의 대상이 되어야 할 것이다.

다음으로는 노동법원의 신설이다. 노동문제는 행정의 측면으로 접근해 해결할 대상이 아니다. 노동문제는 생존권의 측면으로서 노동자의 실질적 노동기본권 보장을 전제하여 보다 전문적으로 판단해야만 한다. 현재 노동과 관련된 권리구제는 지방노동위원회를 거치고 중앙노동위원회를 거쳐 그에 불복할 경우 행정소송 등에 이르게 되기에 사실상 5심제로 이루어진다. 이로 인해 시간과 비용은 물론이고 실질적 권리구제에 이르기까지 소모되는 시간이 너무 오래 걸려 사안의 쟁점 이외의 부분에서도 본이 아니게 2차 · 3차적 피해를 가져오게 된다는 단점이 있다.

현재는 법원이 노동문제를 판단함에 있어 여전히 신의성실의 원칙을 재판의 판단기준으로 적용하는 등 「민법」상의 원리를 차용하는 측면으로 접근하는 경우가 있다. 하지만 본래 「민법」은 상호 대등한 당사자가 자유로운 의사에 따라 맺은 계약을 최대한 존중해야 한다는 사적 자치의 원칙이나 계약 자유의 원칙을 기초로 하는

것이므로, 재판에서 「민법」의 관점으로 노동자와 사용자의 관계를 판단하게 될 경우에는 노동자가 사용자와 실질적으로 대등하지 못한 관계에 서있어 노동자의 진실한 의사표현이 제한될 것이 예상된다. 따라서 이러한 노동자를 보호하기 위해 생겨난 것이 노동법이므로 현재 대법원의 판례처럼 「민법」의 관점이 노동문제의 재판규범으로 작용하고 있는 것을 방지하기 위해서라도 노동법원의 필요성이 요구된다.

또한 구구한 논의의 대상이 되는 취업규칙과 관련된 문제 역시 노동법원이 신설돼 노동문제에 대한 해박한 지식과 경험을 갖춘 법관이 전문성을 가지고 개별 사안에 집중하여 판단하게 된다면 더 이상 추상적 개념에 불과하고 우리의 법현실과 무관한 '사회통념상 합리성 이론'을 끌어들여 판단하는 오류를 범하지 않게 될 것이라고 기대할 수 있다.

궁극적으로는 독일의 '공동결정법'과 '사업조직법' 등과 같이 노동자의 경영참여제도를 고려해보는 것 역시 바람직해 보인다. 다만 이 같은 대안은 정책의 실현과 입법 이전에 충분히 공론화하여 사회적 인식의 개선을 바탕으로 하여야 할 것이며, 실질적인 필요성을 도출해내 사용자와 노동자 사이에 있어서 신뢰와 배려를 바탕으로 추진되어야 할 것이다. 최근 들어 주목 받고 있는 사례는 독일의 사례로 노동자를 더 이상 단순히 보호의 대상으로 삼거나 통제의 대상으로만 여기는 것이 아닌 소통과 협력의 노사관계를 기반으로 하는 공평한 권리와 책임의 주체로 인정하는 것이다. 이는 경제주체 간의 조화를 통해 경제활동에 대한 의사결정 방식이 민주적 방식으로 행하여져 국가와 기업 그리고 노동자간에 힘의 균형이 이루어져야 한다는 것을 의미한다. 경제민주화의 대상을 「헌법」상의 권력분립 이론에 따라 국민의 기본권에 영향을 미치는 국가권력으로만 한정하여 볼 것이 아니라 경제와 사회의 권력까지도 포함시켜야 하는 것이 오늘날 현대 헌법의 과제라고 본다면, 노동자의 경영참가나 노동이사제 등은 보다 자연스러운 추세라고 보아야 한다.[289]

다만 노동이사제를 마냥 만병통치약의 개념으로만 접근해 과도한 환상을 가질 수 있다는 점에서는 경계해야할 필요성도 있다. 오랜 시간 지속되어온 노사대치문화가 노동이사제가 도입된다고 해서 한순간 노사협치와 화합의 문화로 변경되지는 않을

289)강경선, 앞의 책, 에피스테메, 209면.

것이라는 점은 어렵지 않게 예상되기 때문이다. 그러나 노동이사제가 사회적 대타협의 결과물로써 진행되어 지고 사업장에 적용할 수 있는 노사공동결정제도 등과 같이 상호 보강적인 제도들과 함께 진행되며 자리 잡아 간다면 불가능한 이야기만은 아니다.[290] 이 같은 제도들이 자리한다면 우리 사회의 전근대적인 노사관계의 잔존과 노동기본권에 대한 억압적인 상황을 극복할 수 있을 것이라 기대되고,[291] 그로 인해 노동자들의 노동기본권이 한층 신장하게 되는 계기가 되어 줄 것이라고 판단한다.

290)곽노현, 「근로자이사제, 경제민주화의 새 모델」, 『허핑턴포스트』, 2016. 06. 07., <http://www.huffingtonpost.kr/korean-agenda/story_b_10330712.html> 참조.

291)김선수(2015), 「한국의 노동기본권 현실과 국제노동기준에 부합하는 노동법 개정」, "국제노동기준에 비춰본 한국의 노동기본권 -결사의 자유를 중심으로-", ILO가입 25주년, OECD가입 20주년, 국제심포지움, 35면.

제5장 결론

우리 「헌법」은 근대적 기본권 국가의 자성적 목소리를 담아 자유권적 기본권과 사회권적 기본권을 고루 담아내고 있다. 이러한 기본권의 측면에서 볼 때 「헌법」상의 노동 이념을 실현하기 위한 「근로기준법」은 그 존재 가치가 상당하다. 노동은 인간이 자연과 관계하면서 자신을 지속적으로 발전시켜 나가는 과정이며 생존을 위한 조건에 해당하는 것이다. 따라서 우리 「헌법」이 담아내고 있는 노동의 기본 이념과 그 추구하는 가치를 훼손시키는 것은 더 이상 용인되어서는 안된다.

하지만 노동부는 최근까지도 노동자들의 노동기본권 침해요소가 상존해 있던 '양대 지침'의 입장을 고수한 바 있으며, 2017년 09월 25일에 이르러서야 이를 공식적으로 폐기시킨 바 있다. 정부의 이러한 정책적 결정은 '양대 지침'으로 인해 침해받던 노동기본권에 대해 어느 정도 회복을 불러올 것으로 보인다. 그러나 정책적 혼선으로 인해 개별 사업 또는 사업장에서 이미 취업규칙 변경을 완료돼버린 경우에는 권리 침해부분이 사실상 곧바로 효력을 잃게 되는 것이 아니므로 '양대 지침'이 폐기된 지금까지도 기본권의 침해 우려는 여전히 상존한다. 그러므로 앞으로는 보다 체계화된 정책을 바탕으로 국민의 기본권에 대해서 신중하게 접근할 필요가 있다.

따라서 본고의 논의는 우리 노동현실 속 자본과 노동이 균형을 잃어 자본의 측면으로 균형점이 치우쳐져 있는 상황 속에서, 우리 「헌법」의 이념과 기본권의 객관적 가치 측면으로 현실의 노동 문제에 접근하여 현재의 불균형을 수정하고 자본과 노동의 균형점이 조금이나마 중앙으로 위치할 수 있도록 하려 노력했다.

본고가 주장하고자 했던 주된 논의의 요지는 어떠한 경우에 있어서도 취업규칙을 불이익하게 변경해서는 안된다고 주장하는 것은 아니다. 사용자가 기업을 경영하다 보면 필연적으로 취업규칙의 내용을 변경해야만 하는 사정이 발생할 수 있다는 점이 그리 어렵지 않게 유추되기 때문이다. 다만 이러한 경영상의 이유나 정부의 정책적 결정 등에 의해 취업규칙의 작성과 변경 사유가 발생하게 될지라도 그 내용이 취업규칙을 적용을 받게 될 노동자들에게 불이익하게 변경되는 결과를 가져온다면, 우리 「헌법」이 내포하고 있는 노동이념과 그러한 노동이념을 표방하고 있는 개별 노동

관계법령들이 미리 정하여둔 기준에 따라 성실하고 합리적인 절차에 맞추어 변경이 진행되어야 한다는 것을 강조하고자 했다. 이는 노동자들의 노동기본권과 직접적으로 관계된 것인 만큼 방침에 불과한 '지침' 등의 것으로는 이를 제한하거나 예외를 둘 수 없다는 점을 밝힌 것이다.

또, 사안에 따라 추상적 개념인 사회통념상 합리성에 대해서 판단해야 할 필요성이 요구된다면 이는 입법적인 방법으로 해결되어야 할 것으로, 더 이상 우리의 입법현실과도 맞지 않는 사회통념상 합리성 이론을 차용해 법관의 재량이나 행정기관의 자의적 판단을 통해서 우리 「헌법」이 가지고 있는 가치관과 노동이념을 배척하여 노동기본권이 침해되어서는 안된다는 것을 분명히 했다.

현재 4차 산업사회를 목전에 두고 있는 현대사회에서의 노동현실은 하루가 다르게 급변해가고 있다. 보다 다변화된 노동구조가 생겨나게 되었으며 보다 복잡한 다면적 노동관계가 형성되기도 한다. 우리는 이럴 때일수록 개별 실정법적 노동법제의 측면으로만 접근해 노동문제를 해결하려들 것이 아닌, 우리「헌법」이 가지고 있는 노동의 이념적 의미와 객관적 가치에 기초하여 노동문제를 이해하려고 노력해야한다. 또한 그러한 움직임들로부터 시작해 노동기본권이 노동자의 인간으로서의 존엄과 가치, 노동자의 시민적 기본권, 인간다운 노동조건의 권리 등으로 풀이되기를 바라며, 궁극적으로는 노동기본권이 보다 보편적 개념으로 자리 잡아 우리의 노동현실 전반에 걸쳐 고루 투영되어 노동과 자본의 균형점이 보다 합리적인 자리에 위치하게 될 수 있기를 기대해본다.

참고문헌

【단행본】

고용노동부(2016), 『공정인사 · 취업규칙 지침 설명자료』.

_____(2016), 『근로기준법 질의회시집』 2013.1.-2015.12..

_____(2016), 『취업규칙 해석 및 운영 지침』.

강경선(2017), 『헌법 전문 주해』, 에피스테메.

_____(2017), 『헌법의 기초』, KNOU PRESS.

_____ · 서경석 · 이경주(2005), 『헌법Ⅰ』, 한국방송통신대학교출판부.

강의중 외(2008), 『행정법』, 교학연구사.

김남진 · 김연태(2007), 『행정법Ⅰ』, 법문사.

김엘림 · 윤애림(2016), 『근로보호법』, KNOU PRESS.

_____(2005), 『노동법Ⅰ』, 한국방송통신대학교출판부.

김철수(2016), 『헌법과 법률이 지배하는 사회』, 진원사.

_____(2012), 『헌법정치의 이상과 현실』, 소명출판.

_____(2007), 『헌법학개론』, 박영사.

김형배(2016), 『새로 쓴 노동법』, 박영사.

곽노현(2005), 『노동법Ⅱ』,한국방송통신대학교출판부.

권영성(2011), 『헌법학원론』, 법문사.

노동법실무연구회(2010), 『근로기준법주해Ⅲ』, 박영사.

이상영 · 이재승(2005), 『법사상사』, 한국방송통신대학교출판부.

이상윤(2007), 『노동법』, 법문사.

이병태(2005), 『노동법』, 중앙경제.

이철주 · 강경선 · 김민배(2006), 『행정법Ⅰ』, 한국방송통신대학교출판부.

이홍재 · 남효순(2002), 『노동법강의 - 기업구조조정과 노동법의 중요과제』 서울대학교 법과대학 전문분야 연구과정 제7권, 법문사.

인권법교재발간위원회(2007), 『인권법』, 아카넷.
임종률(2017), 『노동법』, 박영사.
성낙인(2017), 『헌법학』, 법문사.
신인령(1999), 『노동인권과 노동법』, 도서출판 녹두.
차병직 · 윤재왕 · 윤지영(2016), 『지금 다시, 헌법』, 로고폴리스.
하갑래(2017), 『근로기준법』, 중앙경제.
허 영(2017), 『한국헌법론』, 박영사.
홍천용 외(2000), 『시민생활과 법』, 박영사.

【논문 등】

고용노동부(2015), 「취업규칙 변경의 합리적 기준과 절차 공청회 발제문」.
강선희(2015), 「임금피크제 도입을 위한 취업규칙 불이익 변경 시 동의방법과 사회통념상 합리성」, 『노동리뷰』 통권 제128호, 한국노동연구원.
강성태(2015), 「915노사정 대타협과 법적 쟁점」, 노동법 3개 학회 공동 토론회, 2015. 10. 14.
강희원(2000), 「노동3권의 법적 성격과 노동단체법」, 헌법실무연구회 월례발표회, 2000. 04. 07.
김 훈 · 박종희 · 김정우(2011), 「종업원대표제도 개선방안 연구」, 『정책연구』 2011-01, 한국노동연구원.
김선수(2015), 「한국의 노동기본권 현실과 국제노동기준에 부합하는 노동법 개정」, “국제노동기준에 비춰본 한국의 노동기본권 -결사의 자유를 중심으로-”, ILO가입 25주년, OECD가입 20주년, 국제심포지움.
김성진(2015), 「근로조건 대등결정의 원리」, 『노동법학』 제54호, 한국노동법학회.
김진곤(2012), 「노동복지의 헌법적 기초로서 노동기본권 -근로의 권리와 노동3권을 중심으로-」, 『헌법학연구』 제18권 제3호, 한국헌법학회.
고영국(2015), <노사정위 ‘2대 지침’ 논의의 주요 쟁점과 제언>, 민주정책연구원 이

슈브리핑, 2015-35호.
노호창(2011), 「헌법상 근로권의 내용과 성격에 대한 재해석」, 『노동법 연구』 제30호, 서울대노동법연구회.
민주사회를 위한 변호사모임(2016), 「'지침'에 의한 쉬운 해고, 취업규칙 변경의 문제점」, 『노동개악 저지를 위한 민변 자료집2』.
민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회, 법률원(2015), 「노사정 위원회 '합의안'의 문제점에 대한 법률적 검토 의견서」.
박종희(2015), 「임금피크제와 취업규칙 변경절차에 관한 법적 검토」, 『노동법포럼』 제15호, 노동법이론실무학회.
_____(2015), 「지정토론문」, 『노동시장 구조개선을 위한 사회적 대화, 진단과 대안』, 대통령소속경제사회발전노사정위원회.
방준식(2016), 「임금피크제의 도입에 따른 법적 문제」, 『법학연구』 제24권 제2호, 한국노동법학회.
배규식(2016), 「2015년 노사관계 평가와 2016 노사관계 전망」, 『노동리뷰』 통권 제130호, 한국노동연구원.
이광선(2016), <취업규칙과 단체협약과의 관계>, 법무법인 지평 노동 뉴스레터, 2016-4월 제1호.
이승재(2004), 「근로자 동의 없는 취업규칙 불이익 변경의 효력」, 『노동법률』 Vol 159, ㈜중앙경제.
이 정(2015), 「임금피크제의 도입과 취업규칙의 불이익 변경」, 『노동시장 개혁의 주요 쟁점 점검 -해고제도, 취업규칙변경을 중심으로-』, 한국경제연구원.
_____ · 박종희 · 하갑래(2009), 「취업규칙 분석 및 제도개선 방안 연구」, 『노동부 정책연구사업 보고서』.
이준일(2004), 「사회적 기본권」, 『헌법학연구』 제10권 제1호, 한국헌법학회.
이홍재(1999), 「노동기본권과 사회보장수급권의 실효성」, 『서울대학교 법학』제39권 제4호, 서울대학교 법학연구소.

이희성(2007), 「사용자의 경영권과 근로자의 노동3권의 충돌에 관한 연구」, 『산업관계연구』 제17권 제1호, 한국고용노사관계학회.

오세웅(2016), 「취업규칙 불이익변경의 사회통념상 합리성 여부」, 『노동판례리뷰 2015』, 한국노동연구원.

장진나(2008), 「취업규칙 불이익 변경시 사회통념상 합리성에 관한 연구」, 석사학위논문, 고려대학교.

장홍근(2017), 「노동개혁 정책과 평가」, "[구조개혁 정책세미나] 지난 4년간의 구조개혁, 성과와 반성", 한국개발연구원 (KDI), 2017. 04. 04.

전형진(2015), <노사정 대타협 논의의 주요쟁점>, 국회입법조사처 이슈와 논점, 제978호.

정인섭(2004), 「취업규칙의 불이익변경과 집단적 동의의 방법」, 『노동법연구』 제17호, 서울대학교 노동법연구회.

정영훈(2009), 「취업규칙의 불이익변경에 관한 일고찰 -절차심사와 내용심사의 보강의 당위성과 가능성을 중심으로-」, "한국노동법학회 · 울산대학교 사회과학연구소 공동 학술 세미나".

정지원(2016), 「취업규칙 변경의 합리적 기준과 절차」, 고용노동부.

정진경(2002), 「근로조건의 불이익변경 - 취업규칙과 단체협약에 의한 근로조건의 불이익변경에 관한 대법원판례를 중심으로」, 『노동법연구』 제13호, 서울대 노동법 연구회.

조경배(2003), 「취업규칙 불이익변경의 유효요건인 집단적 동의 : 대법원 2003. 4. 11 선고, 2002다71832 판결에 대한 분석과 평가를 중심으로」, 『사회과학연구 논문집』 제9권 제1호, 순천향대학교사회과학연구소.

_____(2008), 「신자유주의, 자본권력의 강화와 노동인권의 위기」, 『민주법학』 38권, 민주주의법학연구회.

_____(2012), 「국제 노동기준에 비춰본 한국 노동자의 노동기본권 보장 실태」, "[국제 정책 세미나] 국제기준에 비춰 본 한국의 노동기본권과 ILO 협약 비준 확대 방안".

조득주(2008), 「취업규칙제도에 관한 연구」, 박사학위논문, 고려대학교.

최영호(1993), 「취업규칙의 불이익변경」, 『노동법연구』 제3호, 서울대학교 노동법연구회.

최규환(2014), 「사회적 기본권의 사법심사 가능성」, 박사학위논문, 고려대학교.

최은실(2015), 「취업규칙 불이익 변경요건과 노동자 대표성 문제」, "노동시장 구조개혁 및 비정규직 종합대책(안)에 대한 법률단체 토론회".

하갑래(2009), 「취업규칙 불이익변경에 있어 사회통념상 합리성」, 『법학논총』 제33권 제2호, 단국대학교 법학연구소.

한국고용정보원(2016), 『2016 KEIS 노동시장 분석』 기본연구 2016-02.

한국경영자총협회(2016), 「공정인사 지침에 대한 기업 인식 및 대응조사」, 노동정책본부 법제1팀.

홍 성(2016), 「성과연봉제 확대도입과 사회통념상 합리성 이론」, 『노동법률』 Vol 302, ㈜중앙경제.

홍석한(2015), 「사회적 기본권의 법적 성격에 대한 고찰」, 『법학연구』 제23권 제4호, 경상대학교 법학연구소.

황현순(2004), 「취업규칙의 변경에 따른 문제점에 관한 小考 -불이익변경의 문제점을 중심으로-」, 『법학연구』 제20집, 원광대학교 법학연구소.

【인터넷 자료 등】

- 기획재정부 경제정책방향 <http://www.mosf.go.kr/>
- 국가기록원 기록물 <http://theme.archives.go.kr/>
- 국가법령정보센터 <http://www.law.go.kr/>
- 국립국어원 표준국어대사전 <http://stdweb2.korean.go.kr/>
- 국회정보시스템 <http://likms.assembly.go.kr/>
- 대한민국 법원 종합법률정보 <http://glaw.scourt.go.kr/>
- 법제처 <http://www.moleg.go.kr/>

- 행정자치부 관보 <http://www.moi.go.kr/>
- e-나라지표 <http://www.index.go.kr/>
- 곽노현, 「근로자이사제, 경제민주화의 새 모델」, 『허핑턴포스트』, 2016. 06. 07., <http://www.huffingtonpost.kr/korean-agenda/story_b_10330712.html>
- 「9.13 노사정 합의는 노동기본권을 유린하는 위험천만한 합의」, 『국회의원 300인 모니터링 뉴스』, 2015. 09. 15. <http://news300.kr/>
- 「헌법에 보장된 권리 노동3권을 생각하자」, 『시사IN』, 2014. 10. 29. <http://www.sisain.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=21561>
- 「'쉬운 해고' 양대지침 오늘 폐기…정부 "대화 복원 기대"」, 『뉴스1』, 2017. 09. 25., <http://news1.kr/articles/?3109871>
- 「양대지침(저성과자 일반해고·취업규칙 요건 완화) 피해자 대책 시급」, 『내일신문』, 2017. 11. 01., <http://www.naeil.com/news_view/?id_art=255068>

【표, 그림 자료 등】

<표 1> 판례가 제시하고 있는 사회통념상 합리성의 판단 기준
<표 2> 일본 최고재판소의 사회통념상 합리성 판단 기준
<그림 1> 양대 지침에 대한 임금 노동자의 우려도 비교
<그림 2> 노동조합 조직률 변화 추이
<그림 3> 지침으로 인해 사용자가 임의대로 취업규칙을 변경할 수 있다는 우려도
<그림 4> 시간 흐름에 따른 관심도 변화
<그림 5> 일자리 질적 수준별 고용구조 추이

【법령 등】

「헌법」
「헌법재판소법」
「민법」

「국가인권위원회법」

「근로기준법」

「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」

「노동조합 및 노동관계조정법」

「경제적 사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약」 -(조약 제1006호)

A B S T R A C T

A Study On the Rules of Employment In View of Constitutional Basic Rights

by

Jung, In-Tak

Department of Law
Graduate School
Korea National Open University

Supervised by Professor : Kang, Kyong-Son

This article noticed the fact that the research on labor sector in our society is mainly focused on labor substantive law-oriented labor law, and it began stating that it is necessary to solve labor research and labor issues in the future with constitutional norms. Based on this, this is the research which examined the problems related to the employment rule system among the 'two guidelines', which was the most important issue of the labor problems that face our society, by relying on the constitution. In particular, the purpose of this study is to review problems and present an institutional alternative in that the

fundamental rights of workers are easily violated if the employment rule system, which is directly applied to majority of workers, is relaxed carelessly to the unprofitable requirements of change.

The Labor Standards Act, which regulates the rules of employment, is the basic law of basic labor rights for the realization of the basic right on the Constitution for the Constitution and the labor issues of which the essential sign is the guarantee of citizens' basic rights. The basic right of labor is rooted in the basic right structure of the Weimar Constitution of 1919. Domestic 「Constitution」, which referred to the Japanese Imperial Constitution and the German Weimar Constitution at the time of legislation of the founding Constitution, also specifies in Article 32 and 33 that basic right to work is citizens' basic rights. Article 32 is a social basic right prepared with the civil liberties and social rights in the aspect of practical guarantee, and demands the right to claim for work opportunities and the duty to promote the employment of the state, limit of unlimited fire, guarantee of proper wage and legal principle on the standard of labor condition. Article 33 clarifies that the right of organization, the right of collective bargaining, and the right of strike, which are so called 'three labor rights', should be guaranteed as realistic and specific rights.

Though this is a system based on citizens' basic rights that is plainly guaranteed in 「Constitution」, the government has tried to regulate the labor market not with revision of law through citizens' understanding and social consensus, but with 'two guidelines' that is

mere an 'administrative guideline'. Therefore, the standing committee of the National Human Rights Commission (NHRC) concluded that the Ministry of Employment and Labor actively promoted the use of the "Two Guidelines" and ordered appropriate agencies to use it, which is nothing but a simple guidebook without legal effect. Accordingly, the committee expressed the concern that it may be necessary to take measures to prevent the labor rights of the people from being weakened, and the government's guidelines might virtually regulate the rights of citizens.

In the reality that capital and labor is unbalanced and the equilibrium point is inclined to capital, this study suggests that the unbalance between capital and labor should be corrected by approaching the realistic issue of labor from the aspect of the ideal of the Constitution and the objective value of basic rights. This study also emphasizes that the balance of capital and labor should be located closer to the center.

Keywords : Constitution, Social fundamental rights, Basic labor rights, Employment regulation system, Social conventional rationality.

감사의 글

정신없이 논문연구 일련의 과정들을 지나 본고 논의를 마무리 짓고 어렵사리 논문심사를 통과한 후 돌아보니, 심사 통과 전에는 미처 느끼지 못했던 부족한 부분들이 쉴 새 없이 눈에 들어오며 논문의 완성도에 대한 아쉬움과 부끄러움이 더해져 나의 능력이 부족하였음을 여실히 느낀다. 그러나 나의 대학원 생활을 마무리 지음에 있어 무언가 하나 결실을 맺을 수 있었다는 점이 더 없이 행복하고 또 감사함으로 남아 본 지면을 빌어 이 논문이 나오기까지 도움을 주신 많은 분들께 감사를 표하고자 한다.

먼저 논문연구 시작부터 논문심사 통과의 순간까지 항상 배려해주시고 마음써 주시며 때로는 부드럽게 또 때로는 강하게 이끌어 주셨던 강경선 지도교수님께 진심을 다해 고개 숙여 감사를 드린다. 또 헌법연구회의 박경순 박사님, 여경수 박사님, 우기택 박사님, 김효영 박사님, 소영환 선배님, 임호풍 선배님, 주정수 선배님께도 후학들을 위해 언제나 지도와 조언을 아끼지 않아주신 점 마음 깊이 감사의 말씀을 전해드린다. 그리고 늘 항상 함께여서 서로 힘이 돼주었던 우리 원우 동기들과 특히 헌신적으로 원우들을 챙겨주신 여채식 원우회장님, 박동욱 부회장님, 원선미 부회장님께도 진심으로 고마운 마음을 전한다.

또한 대학원 과정 내내 항상 지지해주신 장인어른과 장모님께 감사의 뜻을 전해 드리고, 늘 믿어주고 힘이 되어준 매형과 누님에게도 고마움을 표시하며, 언제나 응원해준 나의 오랜 친구 김수희, 김태우, 김태호, 남호성, 박지만, 안창일, 임은영, 최효종에게도 고맙다는 말을 전하고 탈고의 기쁨을 같이 나누고 싶다.

마지막으로 그동안 연년생 꼬꼬마 아기들을 키우며 묵묵히 고생해준 사랑하는 아내 혜진이와 “아빠, 공부 책 봐요?”를 연발하며 “아빠~ 힘내세요~”를 불러준 나의 배터리 선우 왕자님, 그리고 “아빠! 안아~”하며 품에 폭 안겨주었던 쪼꼬만 귀요미 아린 공주님에게도 한없이 감사함과 고마움을 표하며, 일생을 자식들을 위해 살아오신 존경하는 아버지와 사랑하는 어머니께 이 논문을 바친다.